

**I. 법원의 의의**

- 법원(法源)이란 법의 존재 형식 또는 인식 근거를 의미하며, 법으로서의 효력을 가지고 재판의 기준이 되는 것을 말한다. 노동법의 법원은 노동 관계를 규율하는 규범으로서 작용하는 모든 근거를 포함한다. 일반적인 법의 법원 외에 노사 간의 자치 규범이 중요한 위치를 차지하는 것이 특징이다.

**II. 법원의 종류**

**1. 실정노동법**

- 실정노동법은 국가 기관이 제정한 법규범으로서, 헌법을 최상위로 하여 법률, 명령, 조례 등으로 구성된다.

**(1) 헌법**

- 헌법은 노동법의 최고 법원으로서, 근로의 권리와 의무, 최저 임금제, 여성 및 연소자의 특별 보호, 근로 3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권) 등 노동 기본권에 관한 기본 원칙을 규정하고 있다.

**(2) 법률 및 명령**

- 국회가 제정하는 노동 관계 법률(근로기준법, 노동조합 및 노동관계조정법 등)과 대통령령, 총리령, 부령 등의 명령이 주요한 실정노동법을 구성한다. 이들은 헌법의 정신에 따라 구체적인 근로 조건 및 노사 관계를 규율한다.

**(3) 자치 법규(조례)**

- 지방자치단체가 법령의 범위 내에서 제정하는 자치 법규(조례)도 해당 지방자치단체 내의 노동 관계에 적용될 수 있는 법원이 될 수 있다.

**(4) 국제 조약 및 국제 법규**

- 국가가 체결·비준한 국제 조약(ILO 협약)과 일반적으로 승인된 국제 법규는 국내법과 같은 효력을 가지며 노동 관계의 법원이 된다.

**2. 노사자치규범**

- 노사자치규범은 국가의 개입 없이 노동 관계 당사자인 사용자와 근로자(대표)가 자율적인 의사로 제정한 규범으로서, 노동법의 특수성을 반영하는 중요한 법원이다.

**(1) 단체협약**

- 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 단체교섭을 통해 합의하여 체결한 서면 문서이다. 단체협약 중 규범적 부분은 근로 조건이나 근로자와 사용자 간의 노동 관계를 규율하는 법규범으로서 강력한 효력을 가진다.

**(2) 취업규칙**

- 사용자가 사업장의 근로 조건이나 복무 규율에 관하여 일반적으로 작성한 규정이다. 근로기준법에 따라 제정 및 변경되어야 하며, 법률이나 단체협약에 위반되어서는 안 된다. 근로 조건의 최저 기준을 정하는 법규범으로서의 효력을 가진다.

**(3) 근로계약**

- 근로자와 사용자가 개별적으로 체결하는 계약으로서, 당사자 간의 노동 관계를 규율하는 가장 기본적인 규범이다. 근로계약에서 정한 근로 조건이 법률, 단체협약, 취업규칙이 정한 기준에 미달할 경우, 그 미달하는 부분은 무효가 되고 상위 규범이 정한 기준이 적용된다.

**3. 노동관습법**

- 노동관습법은 특정 사업장이나 지역, 직종에서 오랜 기간에 걸쳐 반복된 관행이 노사 쌍방에게 법적 확신으로 승인되어 법규범으로 작용하는 것을 말한다.

**(1) 노동관행의 존재**

- 일정한 행위나 사실 상태가 장기간에 걸쳐 반복되거나 계속되어 노동 관행이 성립되어 있어야 한다.

**(2) 법적 확신**

- 단순한 관행을 넘어 노사 당사자 모두가 그 관행에 구속되어야 한다는 법적 확신을 가지고 있어야 법원성이 인정된다. 판례는 노동 관행이 근로 조건을 규율하는 노동관습법으로 인정되기 위해서는 사회 일반의 상식에 비추어 규범적 사실로 승인될 정도에 이르러야 한다고 본다.

**4. 부정례**

- 부정례는 법의 형식은 아니지만 사실상 노동 관계에 영향을 미치거나 법적 분쟁 해결의 기준으로 원용되는 재판 기관의 판례나 행정 기관의 해석 등을 의미한다.

**(1) 판례**

- 법원의 재판을 통해 축적된 사법적 판단이다. 법적 구속력은 없지만, 사실상 하급심에 영향을 미친다. 노동법의 내용을 구체화하나, 원칙적으로 법원으로 인정되지 않는다.

**(2) 행정 해석**

- 노동 행정 기관(고용노동부, 노동위원회 등)의 법 해석이다. 이는 법원의 판단과는 달리 직접적인 법적 구속력은 없으나, 실제 행정에서 기준으로 작용하여 노사 관계에 사실상 강력한 영향력을 행사한다.

**III. 결론**

- 노동법의 법원은 헌법과 노동 관계 법률 같은 실정노동법 외에, 노사의 자율적인 의사로 형성되는 단체협약과 취업규칙 같은 노사자치규범이 중요한 위치를 차지한다. 또한, 오랜 관행이 법적 확신을 얻은 노동관습법도 법원의 역할을 수행한다. 이러한 다양한 법원들 사이에서는 상위 법 우선의 원칙, 신법 우선의 원칙 등이 적용되며, 근로 조건에 대해서는 유리한 조건 우선의 원칙이 노사자치규범 간의 효력 관계에 특수하게 적용될 수 있다.

## I. 서설

- 노동법의 법원은 헌법, 법률 등의 실정노동법부터 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등의 노사자치규범에 이르기까지 다양한 형태로 존재한다. 하나의 노동 관계를 규율하는 데 있어 여러 법원이 동시에 적용될 수 있는데, 이때 각 법원이 정하고 있는 근로 조건이 서로 상이하여 충돌하는 경우를 법원의 경합이라 한다. 법원의 경합이 발생했을 때 어떤 규범이 우선적으로 적용되어야 하는지를 정하는 규범 상호 간의 효력 관계 원칙이 필요하며, 일반 법원칙 외에 노동법의 특수성을 반영하는 유리성의 원칙이 중요하게 다루어진다.

## II. 유리성의 원칙

### 1. 의의

- 유리성의 원칙이란 하나의 노동 관계에 여러 개의 법원이 동시에 적용될 때, 근로자에게 가장 유리한 근로 조건을 규정하고 있는 규범이 우선적으로 적용되어야 한다는 원칙이다. 이는 노동법의 존재 목적인 근로자 보호를 강화하기 위해 근로 조건의 최저 기준을 확보하고자 하는 노동법 특유의 특성을 반영한다. 이 원칙은 일반적인 법원칙인 상위 법 우선의 원칙과 신법 우선의 원칙에 대한 예외로서 노동법의 특수한 효력 관계를 정립한다.

### 2. 관련 조문[근기법 제3조, 제15조, 제97조]

- 유리성의 원칙이 직접적 또는 간접적으로 적용되는 근로기준법 상의 주요 조문은 다음과 같다.

#### (1) 근로기준법 제3조 (근로조건의 기준)

- 근로기준법 제3조는 이 법에서 정하는 근로조건은 최저기준이므로 근로 관계 당사자는 이 기준을 이유로 근로조건을 낮출 수 없다.고 규정한다. 이는 근로기준법이 최저 기준을 설정함으로써 근로자에게 유리하게 더 높은 기준을 설정하는 것을 허용한다는 원칙을 천명한다.

#### (2) 근로기준법 제15조 (이 법을 위반한 근로계약)

- 근로기준법 제15조 제1항은 이 법에서 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한정하여 무효로 한다.고 규정하고 있다. 이는 근로계약이 근로기준법이 정한 최저 기준에 미달할 경우 미달 부분이 무효가 되고, 그 무효로 된 부분은 근로기준법에서 정한 기준에 따르도록 하는 보충적 효력을 규정한다. 이는 강행규정성과 직접적으로 관련되며 근로 조건을 저하시키는 근로계약을 배제하는 최저 기준의 원칙을 명시한다.

#### (3) 근로기준법 제97조 (위반의 효력)

- 근로기준법 제97조는 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 따른다.고 규정한다. 이 조문과 관련된 판례는 근로기준법 제97조를 반대해석하면, 취업규칙에서 정한 기준보다 유리한 근로조건을 정한 개별 근로계약 부분은 유효하고 취업규칙에서 정한 기준에 우선하여 적용된다고 판시한다.

### 3. 법원 간의 적용 관계

- 유리성의 원칙은 노동법의 모든 법원 간에 획일적으로 적용되는 것이 아니라, 그 성격에 따라 적용 범위가 제한된다.

#### (1) 법률과 노사자치규범 간의 관계

- 법률(강행규정)은 근로 조건의 최저 기준을 설정하는 상위 규범이므로, 단체협약이나 취업규칙이 법률보다 불리한 조건을 정할 수 없다. 이는 근로기준법 제15조와 제97조에 따라 최저 기준 준수의 원칙이 관철되는 것이다. 다만, 노사자치규범이 법률보다 근로자에게 유리한 조건을 정하는 것은 허용된다.

#### (2) 단체협약과 취업규칙 간의 관계

- 근로기준법 제96조 제1항에 따라 취업규칙은 단체협약과 어긋나서는 아니 된다. 따라서 취업규칙이 단체협약보다 근로자에게 불리하게 근로 조건을 정한 경우, 취업규칙은 무효가 되고 단체협약의 내용이 적용된다(상위 규범 우선의 원칙). 다만, 취업규칙이 단체협약보다 근로자에게 유리하게 근로 조건을 정한 경우 유리성의 원칙을 적용할지 문제된다. 판례는 단체협약의 개정에도 불구하고 종전의 단체협약과 동일한 내용의 취업규칙이 그대로 적용된다면 단체협약의 개정은 그 목적을 달성할 수 없으므로 개정된 단체협약에는 당연히 취업규칙상의 유리한 조건의 적용을 배제하고 개정된 단체협약이 우선적으로 적용된다는 내용의 합의가 포함된 것이라고 봄이 당사자의 의사에 합치한다고 판시하여 유리성의 원칙을 부정한다.

#### (3) 취업규칙과 근로계약 간의 관계

- 근로기준법에는 취업규칙과 근로계약 간의 직접적인 효력 관계를 규정하는 조문이 없으나, 판례는 취업규칙이 근로계약보다 근로자에게 불리하게 근로 조건을 정한 경우 취업규칙이 적용되지 않으며 근로계약이 유효하다고 본다(유리성의 원칙 적용). 다만, 취업규칙이 근로계약보다 유리한 근로 조건을 정한 경우, 근로자는 취업규칙에 따른 유리한 근로 조건의 적용을 주장할 수 있다.

#### (4) 유리성의 원칙 적용 대상 (개별 항목 단위 vs 규범 전체)

- 유리성의 원칙을 적용할 때 비교 대상이 되는 규범의 유리성 판단을 개별적인 항목별로 할 것인지(항목별 유리성의 원칙), 아니면 전체를 종합적으로 평가할 것인지(전체적 유리성의 원칙)에 대해 견해가 대립한다. 판례는 근로 조건의 각 항목을 개별적으로 비교하여 근로자에게 유리한 규정이 우선적으로 적용된다는 항목별 유리성의 원칙을 원칙적으로 채택하고 있다.

## III. 결론

- 노동법의 법원 경합은 다양한 규범의 효력을 조정하는 문제이며, 이때 근로자 보호를 위한 최저 기준 확보의 관점에서 유리성의 원칙이 중요한 역할을 수행한다. 근로기준법의 관련 조문들은 근로 조건을 저하시키는 하위 규범을 배제하고 상위 규범의 기준을 보충한다. 유리성의 판단은 판례에 따라 개별 항목별로 이루어지는 것이 원칙이며, 이는 근로자의 실질적인 이익을 최대화하기 위함이다.

**I. 전부적용**

**1. 상시 5인 이상의 근로자의 사용**

**(1) 상시 근로자 수 산정의 원칙**

- 근로기준법은 원칙적으로 상시 5인 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 전부 적용된다. 여기서 상시라 함은 상태를 의미하며, 근로자 수가 때때로 5인 미만인 되더라도 상태적으로 보아 5인 이상이면 족하다. 산정 방법은 법 적용 사유 발생일 전 1개월 동안 사용한 근로자의 연인원을 같은 기간 중의 가동 일수로 나누어 산정한다.

**(2) 근로자의 범위**

- 상시 근로자 수 산정 시 포함되는 근로자는 근로계약의 형식과 관계없이 실질적으로 근로기준법상 근로자에 해당하는 모든 인원을 포함한다. 따라서 기간제 근로자, 단시간 근로자, 일용직 근로자 등 고용 형태를 불문하며, 외국인 근로자나 불법 체류 근로자도 산정 인원에 포함된다. 다만, 사용자의 동거 가족만을 사용하는 경우나 가사 사용인은 적용 제외 대상이므로 산정 인원에서 제외된다.

**2. 사업 또는 사업장**

**(1) 사업의 정의**

- 사업이란 일정한 목적을 위하여 유기적인 조직 하에 지속적으로 행해지는 경제적·사회적 활동의 단위를 의미한다. 영리 목적 여부는 불문하며, 비영리 재단법인, 종교단체, 교육기관 등도 근로자를 사용하여 사업을 영위한다면 근로기준법의 적용 대상이 된다.

**(2) 사업장의 장소적 관념**

- 사업장은 사업이 행해지는 구체적인 장소를 의미한다. 하나의 사업이 장소적으로 분리되어 있는 경우 원칙적으로는 각 사업장별로 상시 근로자 수를 산정하여 법 적용 여부를 결정한다. 다만, 장소적으로 분리되어 있더라도 인사·회계·노무관리 등이 본사에서 통합적으로 관리되어 독립성이 없는 경우에는 전체를 하나의 사업으로 보아 합산 산정한다.

**3. 구체적 사례 : 근로기준법 적용 여부**

**(1) 국가 및 지방자치단체**

- 국가나 지방자치단체도 근로자를 사용하는 사업주로서 근로기준법의 적용을 받는다. 소속 공무원은 국가공무원법 등 특별법의 우선 적용을 받으나, 공무원이 아닌 신분의 헌법 근로자나 기간제 근로자 등은 근로기준법의 전면적인 적용 대상이다.

**(2) 법인격이 없는 단체**

- 친목 도모를 위한 모임이나 법인 등록이 되지 않은 단체라 하더라도, 실질적으로 노무를 제공받고 임금을 지급하는 종속적인 근로관계가 형성되어 있다면 근로기준법상 사업주로서 의무를 진다.

**II. 일부적용**

**1. 상시 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 적용되는 규정**

**(1) 일부 적용의 법적 근거**

- 근로기준법 제11조 제2항 및 동법 시행령 별표 1에 따라 상시 4인 이하의 근로자를 사용하는 사업장에는 법의 일부 규정만이 적용된다. 이는 소규모 사업장의 영세성과 행정적 부담을 고려한 예외적인 조치이다.

**(2) 주요 적용 규정**

- 소규모 사업장이라 하더라도 근로자의 기본적인 생존권 보호를 위해 다음과 같은 핵심 규정은 적용된다. 근로조건의 명시 및 서면 교부 의무, 임금 지급의 4대 원칙(통화불·직접불·전액불·정기불), 해고예고 제도, 퇴직급여 보장법에 따른 퇴직금 제도, 출산전후휴가 및 육아휴직 등 모성보호 관련 규정, 재해보상 규정 등이 이에 해당한다.

**(3) 주요 미적용 규정**

- 반면, 소규모 사업장의 비용 부담이 큰 규정들은 적용에서 제외된다. 대표적으로 정당한 이유 없는 해고 등을 제한하는 규정, 부당해고 구제신청 규정, 연장·야간·휴일근로에 대한 가산수당 지급 의무, 주휴일을 제외한 연차유급휴가 규정, 근로시간의 제한(주 52시간제) 등이 적용되지 않는다.

**2. 관련 판례**

**(1) 해고의 정당성과 절차**

- 판례는 4인 이하 사업장의 경우 근로기준법 제23조 제1항의 해고 제한 규정이 적용되지 않으므로, 사용자가 정당한 이유 없이 근로자를 해고하더라도 그것이 민법상 신의칙 위반이나 권리남용에 해당하지 않는 한 유효하다고 본다. 따라서 노동위원회에 부당해고 구제신청을 할 수 없으며, 해고의 서면 통지 의무도 적용되지 않는다.

**(2) 휴직 기간 중의 임금**

- 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 지급하는 휴업수당 규정도 4인 이하 사업장에는 적용되지 않는다. 판례는 이러한 예외가 헌법상 평등권이나 근로의 권리를 본질적으로 침해하는 것은 아니라고 보아 합헌성을 유지하고 있다.

**III. 적용제외**

**1. 근로기준법상의 예외**

**(1) 동거의 친족만을 사용하는 사업**

- 사용자와 생계를 같이 하는 동거의 친족만을 사용하는 사업장에는 근로기준법이 전혀 적용되지 않는다. 이는 가족 간의 유대 관계를 고려하여 법이 가정 내의 사적인 영역에 개입하지 않으려는 취지이다. 다만, 동거하지 않는 친족이나 친족이 아닌 근로자가 단 1명이라도 포함되어 있다면 그 인원을 포함하여 상시 근로자 수를 산정하고 법이 적용된다.

**(2) 가사 사용인**

- 가정부, 유모, 집사 등 가구 내의 가사 업무에 종사하는 가사 사용인에게에는 근로기준법이 적용되지 않는다. 가사 업무는 근로 장소와 주거 장소가 혼재되어 근로시간과 휴게시간의 구분이 모호하고 감독이 어렵기 때문이다. 다만, 최근 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률이 제정되어 인증기관에 고용된 가사 근로자에게는 별도의 보호 체계가 마련되었다.

**2. 특별법상의 예외**

**(1) 선원법의 적용을 받는 선원**

- 선원법의 적용을 받는 선원에게는 근로기준법의 근로시간, 휴게, 휴일 등에 관한 규정이 적용되지 않고 선원법이 우선 적용된다. 해상 노동의 특수성을 고려하여 선원법에서 별도의 근로조건을 규율하고 있기 때문이다.

**(2) 기타 공무원 및 교원**

- 공무원은 **국가공무원법** 및 **지방공무원법**, 사립학교 교원은 **사립학교법** 등이 우선 적용된다. 이들에게 **근로기준법**은 특별법에 규정이 없는 경우에 한하여 보충적으로 적용되거나 적용이 완전히 배제되기도 한다.

#### **IV. 결론**

- 근로기준법의 적용범위는 상시 근로자 5인을 기준으로 전부 적용과 일부 적용으로 구분되며, 동거 친족이나 가사 사용인과 같은 특수한 경우에는 적용이 완전히 제외된다. 법의 실효성을 확보하기 위해서는 형식적인 사업장 구분보다는 실질적인 노무 관리의 독립성과 근로자의 종속성을 면밀히 검토하여야 한다. 특히, 소규모 사업장의 경우 일부 규정의 미적용으로 인해 근로자 보호의 사각지대가 발생할 수 있으므로, 판례와 행정해석은 근로자의 생존권 보장을 최우선으로 하여 법을 해석하고 적용하여야 한다. 사업주는 자신이 운영하는 사업의 상시 근로자 수를 정확히 파악하여 법적 의무 이행에 차질이 없도록 해야 하며, 노사 양측은 법의 테두리 안에서 신뢰와 협력을 바탕으로 합리적인 근로관계를 형성해 나가야 한다.

**I. 의의[근기법 제2조 제1항 제1호]**

- 근로기준법 제2조 제1항 제1호는 근로자를 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자라고 정의한다. 이 정의는 근로기준법을 포함한 개별적 근로관계법의 적용 대상을 규정하는 가장 기본적인 개념이며, 근로자가 아닌 자에게는 근로기준법상의 보호가 적용되지 않는다.

**II. 취지**

- 근로기준법상 근로자 개념의 취지는 사용자의 지휘·감독 아래 종속적인 관계에서 근로를 제공하고 그 대가로 임금을 받아 생활하는 경제적 약자를 보호하는 데 있다. 근로기준법은 대등한 당사자 간의 계약을 전제로 하지 않고, 사용자와 근로자의 실질적인 불평등 관계를 개선하여 근로 조건의 최저 기준을 보장함으로써 근로자의 인간다운 생활을 보장하고자 하는 목적을 가진다.

**III. 근로기준법상 근로자의 개념**

**1. 직업의 종류 무관**

- 근로자의 개념은 육체 노동자인지 정신 노동자인지, 정규직인지 비정규직인지, 상시직인지 임시직인지 등 직업의 종류나 고용 형태와 상관없이 실질적인 근로 관계에 따라 판단된다. 이는 형식적인 계약 명칭에 구애받지 않고 실질에 따라 보호를 확대하려는 취지이다.

**2. 임금을 목적으로**

- 임금을 목적으로 한다는 것은 근로의 대가로 반대 급부(임금)를 받는 것을 의미한다. 임금은 근로의 대가로서 주된 목적이어야 하며, 순수하게 자원봉사나 직업 훈련 등을 주된 목적으로 하는 경우에는 근로자로 인정되지 않을 수 있다.

**3. 사업 또는 사업장에서 근로를 제공하는 자**

- 사업 또는 사업장은 노동력이 현실적으로 제공되고 사용자가 존재하는 장소적 범위를 의미하며, 근로를 제공한다는 것은 단순한 노무의 제공을 넘어 사용자의 지휘·감독 아래 종속적인 관계에서 노무를 제공하는 것을 의미한다.

**IV. 대법원의 근로자성 판단기준**

**1. 사용종속관계의 인정**

- 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 민법상 고용계약인지 도급계약인지에 관계없이, 그 실질에 있어 사용자에게 노무를 제공하고 그 대가로 임금을 받는 사용종속관계가 존재하는지에 따라 판단된다.

**2. 판단기준★**

**(1) 업무 내용의 사용자에 의한 지정 여부**

- 업무 내용을 사용자가 구체적으로 지정하고 수행 방법에 대해 상당한 지휘·감독을 하는지 여부가 핵심 기준이다.

**(2) 근무 시간과 장소의 구속성**

- 근무 시간과 장소가 사용자에 의해 구속되는지 여부이다. 구속성이 높을수록 종속성이 인정된다.

**(3) 대체 근로 가능성**

- 근로자가 스스로 제3자를 고용하여 업무를 대신하게 할 수 있는지 여부이다. 사용자의 승낙이 필요한 경우 종속성이 인정된다.

**(4) 독자적인 사업자로서의 이익 창출 및 손해 부담 여부**

- 근로자가 독자적인 사업자로서 자신의 계산으로 이익을 창출하거나 손실을 감수하는지 여부이다. 독자적인 이익 창출 및 손실 부담이 없을수록 종속성이 인정된다.

**(5) 비품, 원자재, 작업 장소 등의 사용자 제공 여부**

- 근로를 수행하는 데 필요한 설비나 비품 등을 사용자가 제공하는지 여부이다. 사용자가 설비나 비품 등을 제공하는 경우 종속성이 인정된다.

**(6) 기본급이나 고정급의 존재 여부와 임금의 성격**

- 기본급이나 고정급이 정해져 있고, 보수가 근로 자체의 대가인지 여부이다. 임금의 성격이 근로자체의 대가인 경우 종속성이 인정된다.

**(7) 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성**

- 근로 제공이 계속적이고 특정 사용자에게 전속되어 다른 업무의 겸직이 제한되는지 여부이다. 계속적이고 전속적인 업무를 수행하는 경우 종속성이 인정된다.

**(8) 사회보장제도 적용 및 근로소득세 원천징수 여부**

- 4대 보험 등 사회보장제도에 근로자로서 가입되어 있는지와 근로소득세를 원천징수하는지 여부이다. 사회보장제도에 가입되었거나 근로소득세를 원천징수하는 경우 종속성이 인정된다. 다만, 사용자가 경제적 우위를 이용하여 임의로 정할 소지가 있어 보조적 요소로 참작된다.

**3. 검토**

- 판례는 위의 판단 기준들을 종합적으로 고려하되, 특히 사용자가 업무 내용을 지휘·감독하고 근무 시간 및 장소를 구속하는 등 노무를 제공하는 사람이 사업자로서의 독립성 없이 사용자에게 실질적으로 종속되어 있는지 여부를 가장 중요하게 판단한다.

**V. 임원의 근로자성 인정 여부**

**1. 사용종속관계의 인정**

- 회사의 임원(이사, 감사 등)은 원칙적으로 회사와의 관계가 위임 계약에 따른 사무 처리에 해당하며, 근로기준법상 근로자로 인정되지 않는다. 이는 임원이 회사 경영에 참여하고 위임받은 사무를 처리하는 지위에 있기 때문이다.

**2. 위임사무의 처리**

- 임원이라 하더라도 회사 경영의 실질적인 의사결정에 참여하지 않고, 이사라는 형식적인 직함만 가졌을 뿐 일반 근로자와 동일하게 사용자의 구체적인 지휘·감독을 받으며 정해진 근로 시간과 장소에서 노무를 제공하고 그 대가로 보수를 받는다면, 예외적으로 근로기준법상 근로자로 인정될 수 있다.

**VI. 특수형태근로종사자의 근로자성(2022.06.10 삭제)**

**1. 의의[산재법 제125조 제1항]**

- 특수형태근로종사자는 계약 형식이 위임이나 도급이더라도 실질적으로는 종속성을 가지고 노무를 제공하며 주로 하나의 사업에 전속되어 생계를 유지하는 사람들을 말한다. 근로기준법상 근로자에는 해당하지 않는 경우가 많지만, 경제적 약자로서 보호가 필요하다는 사회적 공감대에 따라 산재보험법 제125조 제1항 등에서 산재보험의 적용을 특례적으로 받는다.

**2. 산재법상 특례의 적용**

- **산업재해보상보험법**은 근로기준법상 근로자가 아님에도 불구하고 업무상 재해로부터 보호할 필요성이 있는 특수형태근로종사자의 직종을 법률로 명시하고, 이들에게도 산재보험을 적용하는 특례 규정을 두고 있다. 이는 근로기준법의 좁은 근로자 개념이 보장하지 못하는 영역을 사회보장법을 통해 보완하는 조치이다.

#### **Ⅵ. 불법채류외국인의 근로자성**

- 불법채류외국인이라 하더라도 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부는 외국인의 국적이나 취업의 적법성과는 관계없이, 실질적인 사용종속관계가 있는지에 따라 판단된다. **판례**는 불법채류를 이유로 근로자에게 근로기준법상의 권리를 부정할 수 없다고 보아, 불법채류외국인도 근로기준법상 근로자로 인정받을 수 있으며, 임금 및 퇴직금 등의 권리를 보호받을 수 있다는 입장이다.

#### **Ⅶ. 소사장(도급제사원)의 근로자성**

- 소사장(도급제사원)은 외형상 특정 업무를 도급받아 자율적으로 처리하는 형태를 띠지만, 그 실질에 있어 사용자로부터 지휘·감독을 받고, 자신의 계산이 아닌 회사의 계산으로 업무를 수행하며, 독자적인 사업 경영의 능력이나 위험 부담이 없는 경우가 있다. 소사장의 근로자성 역시 대법원의 사용종속성 판단 기준에 따라 개별적이고 종합적으로 판단되며, 실질적으로 사용종속관계가 인정되면 근로기준법상 근로자로 보호받을 수 있다.

#### **Ⅷ. 결론**

- 근로기준법상 근로자는 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사용자에게 근로를 제공하는 경제적 약자를 보호하기 위한 개념이다. 대법원은 계약의 형식이 아닌 실질적인 사용종속관계를 핵심 판단 기준으로 삼아 근로자성을 종합적으로 판단한다. 임원은 원칙적으로 위임 관계이나 예외적으로 근로자성이 인정될 수 있고, 특수형태근로종사자 및 불법채류외국인도 실질적인 종속성이 인정되면 근로기준법상 근로자로 보호받으며, 특수형태근로종사자는 산재보험의 특례를 통해 사회보장적 보호를 추가적으로 받는다. 이처럼 근로자성 판단은 노동법의 적용 범위를 결정하는 가장 중요하고 실무적인 쟁점이다.

## I. 의의[노조법 제2조 제1항]

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제2조 제1항은 근로자를 직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자라고 정의한다. 이 노조법상 근로자 개념은 개별적 근로관계법인 근로기준법상 근로자 개념보다 더 넓은 범위의 노무 제공자를 포함하는 특징을 가진다. 이는 노동 3권을 보장하고 근로자의 단결권을 실질적으로 확대하기 위한 입법적 특수성 때문이다.

## II. 입법목적

- 노조법의 근로자 개념은 헌법이 보장하는 근로 3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권)을 보호하고 실현하는 것을 주된 목적으로 한다. 개별 근로계약의 보호에 초점을 맞추는 근로기준법과는 달리, 노동조합을 결성하고 운영하며 단체교섭을 통해 사용자와 대등한 관계를 형성할 수 있는 주체를 정의한다. 따라서 경제적 약자로서 집단적 보호가 필요한 자는 사용자의 지휘·감독 여부와 관계없이 포함시키려는 확대적인 취지를 가진다.

## III. 노조법상 근로자의 개념

### 1. 직업의 종류를 불문

- 근로기준법과 동일하게 육체 노동이든 정신 노동이든, 정규직이든 비정규직이든 고용 형태나 직업의 종류에 구애받지 않고 실질적인 노무 제공 관계에 따라 판단된다. 이는 특정 직업에 대한 차별 없이 단결권을 보장하기 위함이다.

### 2. 임금·급료 기타 이에 준하는 수입

- 노조법의 수입 개념은 근로기준법상 임금보다 광범위하다. 임금이나 급료는 물론, 이에 준하는 수입(예 : 수수료, 용역 대가, 커미션 등)까지 포함한다. 이는 계약 형식이 도급이나 위임이더라도 실질적으로 노무 제공의 대가로서 생활을 유지하는 데 사용되는 모든 경제적 급부를 포괄함으로써 근로자 범위를 확대하는 역할을 한다.

### 3. 그에 의하여 생활하는 자

- 이 요건이 노조법상 근로자의 범위를 확대하는 핵심 근거이다. 특정 사용자에게 전속되어 사용종속관계가 엄격하게 인정되지 않더라도, 노무 제공을 통해 얻는 수입에 주로 의존하여 생활하는 경제적 약자라면 노조법의 보호를 받을 필요가 있다는 관점이 반영된 것이다. 이로써 특수형태근로종사자와 같이 독자적인 사업자로 분류되기 쉽지만, 사용자와 대등한 교섭력이 없는 노무 제공자들도 노조법상 근로자로 포섭할 수 있는 기반이 된다.

## IV. 대법원의 근로자성 판단기준

### 1. 종전 판례

- 종전 대법원 판례는 노조법상 근로자의 판단 기준에 있어서도 근로기준법상의 사용종속성을 주된 기준으로 인용하는 경향을 보였다. 즉, 노무 제공자가 사용자의 상당한 지휘·감독을 받는지, 근무 시간과 장소가 구속되는지 등 인격적 종속성을 중시하였다. 이로 인해 특수형태근로종사자들은 계약 형식이나 업무 수행의 자율성을 이유로 노조법상 근로자로 인정받기 어려운 경우가 많았다.

### 2. 최근 판례★

- 최근 대법원 판례는 노조법의 확대된 입법 목적을 적극적으로 반영하여 판단 기준을 완화하였다. 노조법상 근로자는 근로기준법상 근로자와 달리, 사용종속성의 징표 중 인격적·기술적 종속성보다는 경제적·조직적 종속성을 중심으로 종합적으로 판단해야 한다고 명확히 하였다.

#### (1) 경제적 종속성

- 노무 제공자가 자신의 수입으로 생활하는지, 특정 사용자에게 노무를 제공하는 것이 주된 수입원인지, 독자적으로 사업 경영을 하여 이윤 창출이나 손실 위험을 부담하는지 여부 등 경제적 지위를 중요하게 본다.

#### (2) 조직적 종속성

- 노무 제공자가 특정 사용자의 사업 조직에 실질적으로 편입되어 운영되는지, 사용자가 노무 제공자의 업무를 전체적으로 지배하고 통제하는지 여부 등 조직 차원의 종속성을 중요하게 본다.

#### (3) 단결권 보장 필요성

- 노무 제공자가 사용자와 대등한 교섭력을 갖지 못하여 단결권을 통한 집단적 보호가 절실하게 필요한 지위에 있는지 여부를 판단에 반영한다.

### 3. 검토

- 최근 판례의 태도 변화는 노조법상 근로자 개념이 근로기준법상 근로자 개념과 분리되어 독자적인 의미를 갖는다는 것을 명확히 하였다. 이는 급변하는 노동 시장 환경에서 노무를 제공하는 다양한 근로자들의 단결권을 폭넓게 보호하고 노사 관계의 집단적 균형을 도모하려는 시대적 요구를 수용한 것으로 평가된다.

## V. 구직자·실업자·퇴직자(해고자)의 근로자성

### 1. 문제점

- 노조법상 근로자는 노무 제공을 통해 수입을 얻어 생활하는 자를 원칙으로 하므로, 현재 노무 제공 관계가 종료된 실업자나 퇴직자(해고자), 또는 아직 노무 제공 관계가 시작되지 않은 구직자가 노조법의 보호를 받는 근로자로 인정될 수 있는지 여부가 쟁점이 된다.

### 2. 종래 논의[구 노조법 제2조 제4호 라목 단서]

- 구 노조법 제2조 제4호 라목 단서는 다만, 해고된 자가 노동위원회에 부당노동행위의 구제신청을 한 경우에는 중앙노동위원회의 재심판정이 있을 때까지는 근로자가 아닌 자로 해석하여서는 아니 된다.고 규정하여, 구제 신청이라는 특정 행위를 전제로 근로자성을 제한적으로 인정했기 때문에 단결권의 본질을 침해한다는 비판과 논란이 있었다.

### 3. 검토

- 현행법과 판례는 노조법의 목적이 단결권 보장에 있음을 최우선으로 한다. 따라서 구직자는 근로 관계가 현실화되지 않아 노조법상 근로자로 보기 어렵다는 것이 일반적이다. 그러나 해고자의 경우, 해고가 노조 활동을 이유로 한 부당노동행위로서 다투어지고 있는 경우에는 단결권을 실질적으로 보장하기 위해 해고의 효력이 확정되기 전까지 노조법상 근로자성을 인정한다. 또한, 일반적인 실업자라도 재취업을 위해 결성한 노동조합에 가입하는 등 집단적 노동 관계의 주체로서 활동하는 경우 노조법상 근로자로 인정받을 수 있다. 이는 노동자의 단결권을 확대하는 헌법적 요청에 따른 것이다.

## VI. 불법체류외국인의 근로자성

### 1. 법위반 근로관계의 사법상 효력

- 외국인이 출입국관리법을 위반하여 취업 활동을 하는 경우, 이는 공법상 위법한 행위가 된다. 그러나 판례는 공법상의 위법성이 근로계약의 사법상 효력을 직접적으로 무효로 만들지는 않는다고 본다. 즉, 노무 제공의 대가로서의 임금 청구권 등은 근로기준법에 따라 보호받아야 한다고 본다.

### 2. 노조법상 근로자성

- 노조법은 근로자의 정의에서 국적을 차별하거나 제한하는 규정을 두고 있지 않다. 따라서 불법체류외국인이라 하더라도 노무 제공을 통해 수입을 얻어 생활하는 실질적인 경제적 종속성이 인정된다면, 노조법상 근로자로 인정된다. 이는 단결권이 인간의 기본권으로서 외국인에게도 인정되며, 노동 관계에서의 실질적인 약자를 보호하려는 노조법의 입법 목적에 부합한다. 따라서 불법체류외국인도 노동조합을 결성하거나 가입하고 단체 활동을 할 수 있는 주체가 될 수 있다.

## **VI. 결론**

- 노조법상 근로자는 근로기준법상 근로자보다 넓은 범위를 포괄하며, 이는 근로 3권 보장이라는 노조법의 입법 목적에 기인한다. 대법원의 최근 판례는 사용종속성 판단에서 인격적·기술적 종속성보다는 경제적·조직적 종속성을 중요하게 다루어 단결권을 확대하였다. 또한, 해고자의 경우에도 노조 활동을 이유로 한 부당노동행위와 관련하여 다투어지는 경우에는 근로자성이 인정되어 노조 활동의 주체가 될 수 있다. 불법체류외국인 역시 국적이나 체류 자격의 위법성과 별개로 경제적 종속성에 따라 노조법상 근로자로 인정되어 단결권을 보호받는다. 이처럼 노조법상 근로자 개념은 집단적 노사 관계에서 실질적인 약자를 포섭하여 노동 관계의 자주적 조정을 가능하게 하는 법적 기초가 된다.



## I. 의의[근기법 제2조 제1항 제2호]

- 근로기준법상 사용자란 근로기준법의 적용을 받는 의무의 주체로서, **근로기준법 제2조 제1항 제2호**에서 사용자는 사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자로 규정한다. 이러한 사용자 개념은 민법상 고용주보다 광범위하게 인정되는 것이 특징이다. 이러한 개념은 근로기준법상의 의무 이행을 실질적으로 확보하고 근로자 보호를 목적으로 한다. 즉, 법률적·형식적 지위에 관계없이 근로자에 대한 지휘·명령 및 근로조건 결정에 관여하는 실질적 권한을 가진 자를 포함하도록 사용자 개념을 확장한 것이다. 근로기준법의 모든 규정에 관하여 적용되는 개념이지만, 각 규정의 성격과 보호 목적에 따라 그 적용 범위는 상대적으로 결정될 수 있다.

## II. 사용자의 범위

### 1. 사업주

- 사업주란 근로자를 사용하여 사업을 수행하고 그 경영을 책임지는 주체를 의미한다. 법인인 경우에는 법인 자체가, 개인 기업의 경우에는 그 개인 사업주가 사업주가 된다. 사업주는 근로계약의 당사자이자 근로조건의 최종 결정권한 및 임금 지급 의무 등을 지는 제1차적 사용자로서, 근로기준법상의 모든 의무를 최종적으로 부담한다. 사업주가 근로기준법상 의무를 이행하지 아니한 경우, 위반 행위자가 누구인지와 관계없이 사업주에게 직접적인 민사적·형사적 책임은 물론 벌칙까지 부과될 수 있다.

### 2. 사업경영담당자

- 사업경영담당자란 사업주로부터 사업 경영의 전부 또는 일부에 대하여 포괄적인 위임을 받아 대외적으로 사업을 대표하거나 대리하는 자를 말한다. 여기서 포괄적인 위임이란 사업주가 근로자에 대한 인사, 노무관리 등 사업 경영에 관한 전반적인 사항에 대하여 사실상 책임과 권한을 부여한 상태를 의미한다. **판례**는 지배인 등 법률상 대리권이 있는 자뿐만 아니라, 사업의 주요 부분에 대하여 독자적으로 결정 권한을 가지고 사업주와 거의 대등한 위치에서 경영 전반을 처리하는 자도 사업경영담당자로 본다. 예를 들어 회사의 대표이사, 공장장, 지점장 등 그 직책과 권한의 범위가 넓고 실질적으로 인사에 관한 최종적 또는 주요한 결정 권한을 행사하는 자 등이 이에 해당된다. 단순히 경영 보조자나 기술적 책임자는 여기에 해당하지 아니한다.

### 3. 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자

- 이 개념은 사용자 범위 중 가장 넓은 범위에 해당하며, 사업주 또는 사업경영담당자를 보조하여 근로자에 관한 특정 사항에 대하여 행위하는 모든 자를 포괄한다. 근로자에 관한 사항이란 근로자의 채용, 배치, 해고 등 인사 노무관리뿐만 아니라, 임금, 휴가, 안전보건, 근로시간 등 근로조건에 관련된 일체의 사항을 말한다. 사업주를 위하여 행위하는 자란 근로자에 대한 법적 의무를 자기의 이름으로 이행하는 것이 아니라, 사업주나 사업경영담당자의 의사를 대행하거나 보조하여 그 권한을 행사하는 자를 의미한다. 이들이 가지는 권한은 근로기준법상의 특정 의무를 이행할 수 있는 범위 내로 국한되므로, 그 책임 범위는 협소할 수 있다. 예를 들어 인사부장, 과장, 현장 감독 등 근로자의 근로조건에 관해 구체적인 지휘·감독 권한을 행사하는 자가 이에 해당된다.

## III. 사용자 개념의 상대성 및 양벌규정

### 1. 사용자 개념의 상대성

- 근로기준법상의 사용자 개념은 각 규정의 목적과 성격에 따라 상대적으로 그 범위가 달라질 수 있다. 즉, 특정한 근로기준법상의 의무를 이행하거나 특정 위반 행위에 대한 책임을 질 사용자가 누구인지를 판단할 때, 그 조항이 요구하는 행위의 주체나 책임을 질 수 있는 실질적인 지위와 권한을 가진 자를 사용자로 본다. 예를 들어 임금 지급 의무의 주체로서의 사용자는 주로 사업주에 한정되지만, 직장 내 괴롭힘 예방 및 조치 의무의 주체로서의 사용자는 사업주 외에 사업경영담당자나 인사 관련 행위자도 포함될 수 있다. 이처럼 사용자 개념을 상대적으로 해석하는 것은 근로기준법의 실효성을 확보하고 법적 의무 이행을 실질적으로 보장하기 위함이다.

### 2. 양벌 규정[근기법 제115조]

- 양벌 규정은 근로기준법상의 의무를 위반한 자가 사업주의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원인 경우, 그 행위자를 벌하는 외에 해당 사업주에게도 벌금형을 과하는 규정이다. 이 규정의 목적은 사업주가 선임·감독상의 주의 의무를 다하지 않아 근로기준법 위반 행위를 방지하지 못한 경우, 그 사업주에게도 책임을 물어 법규 준수의 실효성을 높이고 근로자 보호를 강화하는 데 있다. 다만, 사업주가 그 위반 행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 벌금형을 면할 수 있는 면책 규정을 두고 있다. 이는 사업주에게 무과실 책임을 지우는 것이 아니라, 선임 및 감독상의 과실이 있는 경우에 책임을 부과하는 것이다. 이 규정은 형사책임에 관한 것으로, 법인이 사용자인 경우 법인과 위반 행위를 한 대표자 개인 모두에게 처벌이 부과될 수 있다.

## IV. 사용자 개념의 확장

### 1. 의의

- 근로기준법상 사용자 개념은 **근로기준법 제2조 제1항 제2호**에 의해 규정되지만, 복잡해지는 현대의 기업 조직 형태와 고용 구조(예 : 도급, 근로자 파견)로 인해 형식적인 근로계약의 당사자가 아닌 제3자가 근로자에 대한 실질적인 지배력과 영향력을 행사하는 경우가 발생한다. 이러한 경우, 근로자 보호의 필요성에 의해 판례법리와 개별 노동법령에서 사용자 개념을 확장하여 적용하는 개념이 인정된다.

### 2. 판례법리에 의한 사용자 개념의 확장

- **판례**는 원고용주에게 고용되어 제3자의 사업장에서 제3자의 업무에 종사하는 자를 제3자의 근로자라고 할 수 있으려면, 원고용주는 사업주로서의 독자성이 없거나 독립성을 결하여 제3자의 노무대행기관과 동일시 할 수 있는 등 그 존재가 형식적·명목적인 것에 지나지 아니하고, 사실상 당해 피고용인은 제3자와 종속적인 관계에 있으며, 실질적으로 임금을 지급하는 자도 제3자이고, 또 근로제공의 상대방도 제3자이어서 당해 피고용인과 제3자간에 묵시적 근로관계가 성립되어 있다고 평가될 수 있어야 한다고 판시하고 있다.

### 3. 법령상 인정되는 사용자책임의 특례

- 개별 노동법령에서는 근로기준법상 사용자가 아니더라도 특별히 그 책임을 부담하는 특례를 인정한다.

#### (1) 산업재해보상보험법

- 도급 사업의 경우, 원수급인(원청)은 하수급인(하청)이 사용한 근로자의 산업재해에 대하여 하수급인과 함께 사용자로서의 책임을 부담하도록 규정될 수 있다.

#### (2) 파견근로자 보호 등에 관한 법률

- 파견 근로자에 대한 사용자 책임은 근로계약 관계를 맺고 있는 파견 사업주(파견 회사)와 근로자를 직접 지휘·명령하는 사용 사업주(파견 받은 회사)가 부담하도록 되어 있다. 예를 들어 임금 지급 의무는 파견 사업주가, 근로시간·휴게 등 지휘·명령에 관련된 의무는 사용 사업주가 부담하는 식으로 사용자 책임이 이원화된다.

### 4. 관련 판례

#### (1) 사업경영담당자의 인정 요건

- 사업경영담당자로 인정되기 위해서는 사업주로부터 사업 경영의 전부 또는 일부에 대하여 포괄적인 위임을 받아 대외적으로 사업을 대표하거나 대리하는 자여야 한다. 여기서 위임은 명시적일 필요가 없으며, 직책, 업무의 내용, 규모 등에 비추어 볼 때 사업 경영 전반에 걸쳐 상당한 책임과 권한이 부여된 것으로 인정되면 충분하다. 실질적으로 인사·노무에 관한 권한이 인정되는지 여부가 핵심적인 판단 기준이 된다.

## **[2] 근로자에 관한 사항에 대하여 행위하는 자의 범위**

- 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자는 근로기준법상의 의무 이행 또는 위반 행위에 대한 책임을 질 수 있는 실질적인 지위에 있는 자를 의미한다. 예를 들어 특정 임금 체불 건에서 회사의 경리 업무를 전담하고 임금 지급에 관여한 실무 담당자도 해당 임금 체불 조항에 한하여 사용자로 인정될 수 있다. 그 책임의 범위는 그가 담당하는 근로자에 관한 사항에 국한된다.

## **[3] 노조법상 사용자 개념의 확장**

- 노조법상 사용자는 근로계약 체결의 당사자가 아니더라도 근로자의 기본적인 노동조건에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 정도 담당하고 있다고 볼 만큼 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자를 포함한다. 이러한 법리는 특히 원청업체가 하청업체 근로자들의 작업 환경, 배치, 근로시간 등 주요 근로조건을 실질적으로 좌우하는 경우에 원청업체를 단체교섭의 의무가 있는 사용자로 인정하는 근거가 된다. 이는 노사관계의 실태에 맞추어 단체교섭의 대상을 명확히 하고 근로자들의 단결권을 실효적으로 보장하기 위한 법리이다.

## **V. 결론**

- 근로기준법상의 사용자 개념은 사업주, 사업경영담당자, 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자라는 세 가지 범주로 광범위하게 규정된다. 이 개념은 근로기준법의 실효성을 확보하고 근로자를 실질적으로 보호하기 위한 노동법적 특수성을 반영하며, 그 범위는 각 법 조항이 규정하는 의무의 성격에 따라 상대적으로 결정된다. 특히 판례법리에 의해서는 복잡한 고용 구조 속에서 근로조건에 대한 실질적인 지배력을 행사하는 자에게까지 사용자 책임(노조법상 교섭 의무 등)을 확장하여 적용함으로써, 근로자들의 집단적 권리를 실효적으로 보장하는 데 그 중요성이 크다.

**I. 의의[노조법 제2조 제2호]**

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제2조 제2호는 사용자를 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다.라고 정의한다. 이 노조법상 사용자 개념은 개별적 근로관계법인 근로기준법상 사용자 개념과 문언적으로는 동일하나, 그 해석과 적용에 있어 현격한 차이가 있다. 노조법은 근로 3권을 보장하고 집단적 노사 관계의 자주적 조정을 목적으로 하므로, 노조법상 사용자는 단체교섭의 당사자로서의 의무와 부당노동행위 금지의 수급자로서의 책임을 부담하는 주체라는 특수성을 가진다. 따라서 노조법상 사용자의 개념은 근로자의 단결권을 실질적으로 보장하기 위해 근로 조건에 실질적인 영향력을 행사하는 주체에게까지 확장되어 해석된다.

**II. 사용자의 범위**

- 노조법상 사용자는 근로기준법과 마찬가지로 법문에 따라 세 가지 유형으로 구성되며, 이들은 집단적 노사 관계에서 책임을 부담하는 주체들이다.

**1. 사업주**

- 사업주는 사업을 법률상 경영하는 주체로서, 근로자가 소속된 사업장의 최종적인 법적 책임자이다. 법인의 경우 법인 그 자체가 사업주에 해당하며, 개인 사업의 경우 개인 경영주가 사업주가 된다. 노조법상 사업주는 단체교섭의 주요 당사자이자 노조 활동과 관련된 모든 법적 의무의 궁극적 부담자이다. 단체협약을 체결할 책임과 체결된 협약의 이행 책임이 귀속되는 주체이기도 하다.

**2. 사업의 경영담당자**

- 사업의 경영담당자는 사업주로부터 사업 경영에 관한 포괄적인 권한을 위임받아 대외적으로 사업을 대표하거나 경영하는 자이다. 법인의 대표이사, 공장장, 지사장 등 직위나 명칭에 관계없이 사업의 운영과 인사 노무에 관한 중요 사항을 결정하고 책임지는 자가 여기에 포함된다. 이들은 사업주를 대신하여 노동 관계를 실질적으로 운영하며, 부당노동행위 금지의 수급자일 뿐만 아니라, 단체교섭에 직접 참여하여 의사 결정을 하는 주체가 된다.

**3. 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자**

- 이 유형은 사업주나 사업의 경영담당자로부터 근로 조건이나 인사 관리에 관한 특정 권한을 부여받아 행사하는 자이다. 인사·노무 담당 부서장, 현장 감독자 등 실무적으로 근로자에게 지휘·명령을 행사하고 근로 조건에 영향을 미치는 행위를 수행하는 자가 포함된다. 이들이 노조 활동에 부정적인 영향을 미치거나 간섭하는 행위는 사업주의 행위로 간주되어 부당노동행위로 평가될 수 있으며, 이들 자신도 부당노동행위 금지의 수급자로서 책임을 진다.

**III. 사용자 개념의 확장**

- 노조법상 사용자 개념의 확장은 근로기준법과 달리, 근로계약상의 직접 당사자가 아닌 제3자(원청 등)에게 단체교섭 의무와 부당노동행위 금지 의무를 부과함으로써 노조법의 집단적 자치 확보 목적을 달성하려는 판례의 법리이다. 이는 고용 형태의 복잡화와 형식적 도급 등을 통한 책임 회피에 대응하기 위함이다.

**1. 단체교섭의 당사자**

- 단체교섭은 근로자의 근로 조건을 실질적으로 결정하고 변경할 수 있는 지위에 있는 자와 이루어져야 한다. 판례는 노조법상 사용자를 판단함에 있어, 근로계약의 당사자가 아니더라도 하청 등 소속 근로자의 근로 조건에 대하여 그들을 고용한 사용자와 함께 또는 그를 넘어 실질적인 지배력과 결정권을 행사하는 지위에 있는 자를 단체교섭의 당사자인 노조법상 사용자로 확장하여 인정한다.

**(1) 실질적 지배력과 결정권**

- 실질적 지배력과 결정권이 인정되기 위해서는 원청(도급인)이 하청 근로자의 임금, 작업 시간, 복무 규율 등 주요 근로 조건에 관하여 구체적으로 관여하거나 그 결정에 중대한 영향력을 행사해야 한다. 특히 하청 근로자의 근로 조건이 사실상 원청의 경영 방침이나 재정 지원 등에 의해 좌우되는 경우에 확장된 사용자성이 인정될 가능성이 높다.

**(2) 단체교섭 의무의 범위**

- 확장된 사용자의 단체교섭 의무는 원청이 실질적으로 지배하거나 결정할 수 있는 범위의 근로 조건에 한정된다. 예를 들어, 원청이 단가 결정을 통해 하청 근로자의 임금에 결정적인 영향을 미치는 경우, 임금에 관한 사항에 대해서는 단체교섭 의무를 부담하지만, 하청 내부의 징계와 같은 사항에 대해서는 의무가 인정되기 어렵다.

**2. 부당노동행위 금지의 수급자**

- 부당노동행위 금지 의무는 근로자의 단결권을 보호하기 위한 가장 중요한 의무이다. 노조법상 사용자는 노조 활동에 대한 차별, 노조 조직 및 운영에의 지배·개입 등을 금지한다.

**(1) 행위자로서의 책임**

- 사업주, 경영담당자, 행동하는 자 모두 부당노동행위를 실제로 한 행위자로서 책임을 진다. 이들의 행위는 노동위원회의 구제 명령 및 형사 처벌의 대상이 된다.

**(2) 확장된 사용자의 책임**

- 단체교섭 당사자로서 사용자성이 확장된 원청은 하청 근로자의 노조 활동에 대하여 부당노동행위 금지 의무의 수급자가 된다. 예를 들어, 원청이 하청 노조의 설립이나 활동을 방해하거나, 하청 사용자에게 압력을 가하여 노조 활동을 위축시키는 경우, 원청은 부당노동행위의 책임을 부담한다. 이는 실질적인 권력 관계에 따라 노조 활동이 침해되는 것을 방지하기 위함이다.

**IV. 결론**

- 노조법상 사용자는 근로기준법상의 개별적 계약 당사자를 넘어, 근로 3권을 실질적으로 보장하고 집단적 노사 관계를 대등하게 유지해야 할 공법상 의무를 부담하는 주체이다. 사용자 개념은 사업주, 경영담당자, 행동하는 자 모두를 포함하며, 특히 하청 근로자의 근로 조건에 실질적인 지배력을 행사하는 원청에게까지 확장된다. 이러한 확장 법리는 노동 환경의 변화 속에서 노동자의 단결권이 형해화되는 것을 방지하고, 노동법의 입법 목적인 노동의 인간화와 노사 관계의 민주적 발전을 추구하는 핵심적인 법적 장치이다.

## I. 균등한 처우 원칙

### 1. 의의[근기법 제6조]

- 근로기준법 제6조는 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性)을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.라고 규정한다. 이는 헌법의 평등권을 개별적 근로 관계에서 구체화하여 근로자의 인권을 보장하고 근로 조건의 공정성을 확보하는 데 가장 기본적인 원칙이 된다. 노동법이 근로자를 경제적 약자로 보고 보호하는 취지를 관철하는 구간을 제공한다.

### 2. 차별적 처우

- 차별적 처우란 특정 근로자나 근로자 집단을 합리적인 이유 없이 불리하게 대우하는 것을 의미한다. 여기에는 직접적인 차별뿐만 아니라, 외견상 중립적인 기준을 적용하였더라도 특정 금지 사유를 가진 근로자 집단에게 불리한 결과를 초래하는 간접 차별 역시 포함된다. 차별의 존재 여부는 비교 대상 집단과의 대우 차이를 통해 판단하며, 차별적 대우가 불리한 것인지 여부는 근로자의 경제적·인격적 측면에서 종합적으로 평가한다.

### 3. 차별금지사유

- 근로기준법 제6조가 명시하는 차별금지사유는 성별, 국적, 신앙, 사회적 신분이다. 국적은 대한민국 국민인지 외국인인지를 의미하며, 신앙은 특정 종교를 믿거나 믿지 않는 자유를 포함한다. 가장 논란이 되는 사회적 신분은 근로자가 가지고 있는 특정 지위나 상태를 의미하며, 판례는 사회에서 장기간 점하는 지위로서 일정한 사회적 평가를 수반하는 것이라고 판시한다. 예컨대, 성별은 고용평등법에 별도로 규정되어 있으나, 비정규직이나 계약직과 같은 고용 형태는 사회적 신분에 해당될 가능성이 있다.

### 4. 차별금지영역

- 차별이 금지되는 영역은 근로 조건 전반이다. 이는 채용, 임금, 승진, 배치, 교육, 훈련, 해고 등 근로자의 노동 생활에 영향을 미치는 모든 사항에 대해 적용된다. 특히, 근로 조건의 핵심인 임금이나 근로시간에 대한 차별은 근로기준법의 규정을 직접 위반하는 것으로 간주되어 엄격하게 금지된다.

### 5. 합리적 이유

- 차별적 처우가 존재하더라도 그 처우에 합리적인 이유가 있는 경우에는 근로기준법 제6조 위반이 아니다. 합리적 이유란 업무의 성격, 난이도, 근로자의 능력, 숙련도, 근속 연수 등 실질적인 노동력의 차이나 생산성 향상 등 사용자의 정당한 경영상 필요에 근거한 사유를 의미한다. 단순히 특정 집단에 대한 편견이나 자의적인 판단에 근거한 차별은 합리성을 인정받을 수 없다. 판례는 차별이 발생한 목적과 수단의 정당성, 그리고 차별 대상 근로자의 지위 등을 종합적으로 고려하여 합리성 여부를 매우 엄격하게 심사한다.

### 6. 입증책임[고평법 제30조]

- 균등한 처우 원칙의 위반으로 다툼이 발생했을 때, 차별적 처우를 주장하는 근로자에게 입증책임이 원칙적으로 부과된다. 그러나 근로 조건에 대한 정보가 사용자에게 편중되어 있어 근로자가 차별의 존재와 관련성을 입증하기 어렵다는 문제점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률(이하 '고평법') 제30조와 같은 개별 법령에서는 입증책임의 특례를 규정한다. 고평법 제30조는 사업주에게 차별에 합리적인 이유가 있음을 입증하도록 하여, 근로자의 입증 부담을 완화하고 실질적인 구제를 도모한다.

## II. 중간착취의 배제 원칙

### 1. 의의[근기법 제9조]

- 근로기준법 제9조는 누구든지 법률에 따르지 아니하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 취득하지 못한다.고 규정한다. 이 원칙은 근로자와 사용자 사이에 제3자가 개입하여 근로자의 노동력을 착취하거나 부당한 이익을 취득하는 것을 금지함으로써, 근로자의 인격적 자유를 보호하고 근로 조건에 대한 부당한 개입을 방지하는 데 취지가 있다.

### 2. 중간착취의 요건

- 중간착취의 배제 원칙을 위반하는 행위가 성립하기 위해서는 다음과 같은 요건이 필요하다. ❶ 영리를 목적으로 할 것이다. ❷ 타인의 취업에 개입하거나 업무의 수행에 관련하여 행위할 것이다. ❸ 법률에 따르지 아니하고 이익을 취득할 것이다. 여기서 타인의 취업에 개입하는 행위는 근로자 모집, 알선, 근로 조건 설정 등 근로 관계 형성과 유지에 매개 역할을 하는 것을 의미하며, 이익은 금전뿐만 아니라 경제적 가치를 가지는 모든 형태의 이익을 포괄한다.

### 3. 법률에 의하여 허용되는 경우

- 중간착취의 배제 원칙은 타인의 취업에 개입하는 행위 자체를 전면적으로 금지하는 것은 아니다. 직업안정법에 따른 유·무료 직업소개사업이나 근로자 파견사업 등 법률에 의해 허가를 받거나 규정된 적법한 노동 매개 행위는 중간착취에서 제외된다. 이러한 사업들은 노동 시장의 효율성을 높이고, 동시에 법적 규제를 통해 근로자 보호 장치를 갖추고 있어 근로자의 자유를 침해하거나 부당한 착취를 하지 않는다고 본다.

### 4. 위반의 효과[근기법 제107조]

- 근로기준법 제9조를 위반하여 중간착취를 한 자는 근로기준법 제107조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하는 형사 처벌을 받는다. 이 규정은 중간착취 행위가 근로자의 인간적 존엄성을 훼손하고 자유로운 노동력 처분을 방해하는 중대한 범죄 행위로 간주됨을 보여준다. 따라서, 근로계약의 사법상 효력과 별개로 행위자에 대해 공법상의 제재를 가하여 원칙의 실효성을 확보한다.

## III. 공민권 행사의 보장 원칙

### 1. 의의[근기법 제10조]

- 근로기준법 제10조는 사용자는 근로자가 근로시간 중에 선거권, 그 밖의 공민권 행사 또는 공의 직무를 집행하기 위하여 필요한 시간을 청구하면 거부하지 못한다. 다만, 그 권리 행사나 공의 직무를 수행하는 데에 지장이 없으면 청구한 시간을 변경할 수 있다.고 규정한다.

### 2. 취지

- 공민권 행사의 보장 원칙은 근로자가 직업인으로서의 지위와 별개로 국민으로서 가지는 참정권, 공무 담임권 등 공법상의 권리를 자유롭게 행사할 수 있도록 보장하는 데 취지가 있다. 이는 근로자의 노동이 국민으로서의 권리 행사를 제약하는 요인이 되어서는 안 된다는 헌법적 이념을 근로관계에 투영한 것이다.

### 3. 공민권 행사의 요건

- 공민권 행사는 법령에 근거하여 국민에게 주어진 권리 행사를 의미하며, 선거 투표, 법원 증인 출석, 예비군 소집 등이 포함된다. 공민권 행사 보장을 받기 위해서는, 근로자는 공민권을 행사하기 위하여 근로시간 중에 시간이 필요함을 사용자에게 청구해야 한다. 여기서 필요한 시간이란 공민권 행사에 필수적으로 소요되는 시간을 의미한다.

### 4. 공민권 행사의 효과

- 사용자가 공민권 행사 시간을 부여하면 근로자는 해당 시간 동안 근로 제공 의무를 면제받는다. 사용자는 이를 이유로 근로자에게 징계나 임금 공제 등 불이익을 줄 수 없다. 다만, 공민권 행사 시간에 대해 유급으로 처리할지 무급으로 처리할지에 대한 규정은 근로기준법에 없으므로, 단체협약, 취업규칙 또는 당사자 간의 별도 합의에 따른다.

## 5. 공민권 행사와 근로관계

- 공민권 행사 원칙은 사용자에게 시간 부여의 의무를 부과한다. 다만, 권리 행사에 지장이 없는 범위에서 시간을 변경할 수 있는 권한을 함께 부여한다. 이 단서 규정은 근로자의 공민권 보장과 사용자의 사업 운영 간의 조화를 꾀하기 위함이다. 사용자는 사업 운영에 막대한 지장이 발생하는 경우 등 합리적인 이유가 있는 경우에 한하여 시간 변경권을 행사할 수 있으며, 시간 변경이 사실상 공민권 행사를 불가능하게 하는 경우에는 위법하다.

## IV. 결론

- 근로기준법의 기본원칙인 균등한 처우 원칙, 중간착취의 배제 원칙, 공민권 행사의 보장 원칙은 근로자의 인간다운 삶과 기본권을 보장하기 위한 핵심 규정들이다. 균등한 처우는 근로 조건 설정 및 적용에 있어 차별을 금지하여 공정성을 확보하고, 중간착취의 배제는 제3자의 부당한 개입으로부터 근로자의 인격적 자유와 경제적 이익을 보호한다. 공민권 행사의 보장은 근로자가 직업 유지와 별개로 국민으로서의 권리를 온전히 행사할 수 있도록 국가적 책무를 근로관계에 관철한다. 이러한 원칙들은 개별적 근로관계의 성립과 유지를 지배하는 최상위 규범으로서 근로기준법의 근본 이념을 대변한다.

**I. 근로계약의 의의 및 법적 성질**

**1. 의의**

- 근로계약이란 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고, 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말한다. 근로기준법상 근로자와 사용자가 체결하는 계약으로서, 근로자가 사용자의 지휘·명령 하에 노무를 제공하는 종속 관계를 형성하는 법률 행위이다. 근로계약의 체결은 개별적 근로 관계 성립의 가장 핵심적인 요소가 된다.

**2. 근로계약의 법적 성질**

- 근로계약은 다음과 같은 법적 성질을 가진다.

**(1) 쌍무·유상계약**

- 근로자의 노무 제공 의무와 사용자의 임금 지급 의무가 서로 대등한 대가 관계에 있으므로 쌍무계약이다. 임금이 지급되는 대가성을 가지므로 유상계약이다.

**(2) 낙성계약**

- 당사자 간의 의사 합치만으로 성립하며, 실제 근로 제공이나 임금 지급 등의 급부 제공을 요건으로 하지 않는 낙성계약이다.

**(3) 계속적 계약**

- 일시적인 노무 제공이 아니라, 일정 기간 동안 계속적으로 근로 관계를 유지하는 것을 목적으로 하는 계속적 계약의 성질을 가진다. 이러한 계속성은 근로기준법상 해고 제한 등 다양한 보호 규정의 근거가 된다.

**3. 근로계약 체결의 자유 및 법적 제한**

- 근로계약의 체결은 사법의 대원칙인 계약 자유의 원칙에 따라 당사자의 자유로운 의사에 의해 결정된다. 그러나 근로자가 경제적 약자라는 특수성 때문에, 근로기준법을 비롯한 각종 노동 관계 법령에 의해 그 자유가 강력하게 제한된다. 균등 처우의 원칙(차별금지), 강제 근로 금지, 최저 근로 조건 보장 등의 규정이 대표적인 법적 제한이다. 이러한 제한은 근로자의 인간다운 생활을 보장하기 위한 강행 법규로서 계약 자유에 우선한다.

**II. 근로계약 체결의 당사자·형식·의무**

**1. 근로계약의 당사자**

- 근로계약의 당사자는 근로자와 사용자이다.

**(1) 근로자**

- 노무를 제공하는 주체로서 원칙적으로 자연인에 한정된다. 근로기준법상 근로자 개념은 직업의 종류와 관계없이 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 근로를 제공하는 자를 의미한다.

**(2) 사용자**

- 근로자에게 임금을 지급하고 지휘·명령 권한을 행사하는 주체이다. 근로기준법상 사업주, 사업경영담당자, 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자(사업주 제외) 사용자는 위임 필요)를 포괄하는 광범위한 개념이다.

**2. 근로계약의 형식**

- 근로계약은 원칙적으로 불요식 계약으로서, 구두나 묵시적인 합의로도 유효하게 체결될 수 있다. 그러나 **근로기준법 제17조**는 근로 조건을 명확히 규정하고, 사용자에게 임금, 소정 근로시간, 휴일, 연차 유급 휴가 등 주요 근로 조건을 명시하고 서면으로 교부할 의무를 부과한다. 이러한 서면 교부 의무는 계약의 유효성 요건은 아니지만, 근로자의 권익 보호를 위한 사용자의 강행적 의무이다.

**3. 근로계약의 의무**

- 근로계약의 체결로 인해 당사자는 주된 의무와 부수적 의무를 부담한다.

**(1) 근로자의 의무**

- 주된 의무는 노무 제공 의무로서, 계약에 따라 정해진 시간과 장소에서 사용자의 지휘 명령에 따라 성실하게 근로를 제공해야 한다. 부수적 의무로는 사용자의 이익을 해치지 않을 성실 의무, 업무상 알게 된 비밀을 누설하지 않을 비밀 유지 의무 등이 있다.

**(2) 사용자의 의무**

- 주된 의무는 임금 지급 의무이다. 부수적 의무로는 근로자가 안전하고 건강한 환경에서 근무할 수 있도록 배려할 안전 배려 의무, 근로자의 인격을 존중하고 침해하지 않을 의무, 근로 조건을 명시할 의무 등이 있다.

**III. 금지되는 근로조건**

**1. 의의**

- 금지되는 근로 조건이란 근로기준법이 정하는 기준에 미치지 못하는 근로 조건을 의미하며, **근로기준법 제15조**에 따라 법정 기준에 미달하는 부분에 한하여 무효로 규정된다. 이는 근로기준법이 최저 근로 조건을 규정한 강행 법규의 성격을 가지기 때문에 발생하는 것으로, 근로 조건의 하향 평준화를 방지하고 근로자 보호를 위한 최소한의 기준을 확보한다.

**2. 유형**

- 근로기준법에서 금지하는 근로 조건은 크게 두 가지 유형으로 나뉜다. ❶ 근로기준법이 정하는 최저 기준(예 : 최저임금법상 최저 임금, 근로기준법상 법정 근로시간 및 연장 근로 한도)에 미달하는 조건이다. ❷ 근로자의 인격적 자유나 기본권을 침해하는 조건이다. 예를 들어, 강제 근로를 금지하는 **근로기준법 제7조**, 폭행을 금지하는 **근로기준법 제8조**의 위반 등이 있다. 특히, **근로기준법 제20조**의 위약금이나 손해배상액의 예정을 금지하는 규정 역시 근로자의 퇴직 자유를 보장하기 위한 금지 조건에 해당한다.

**3. 위반의 효과**

- 근로 조건이 근로기준법이 정하는 기준에 미치지 못하는 경우, **근로기준법 제15조 제1항**에 따라 그 부분에 한하여 무효가 되며, 무효로 된 부분은 **제2항**에 따라 근로기준법이 정하는 기준에 자동적으로 따르게 된다. 이러한 효과를 강행 법규의 보충적 효력이라고 한다. 또한 **근로기준법 제20조**를 위반하여 위약금이나 손해배상을 예정하는 계약을 체결한 사용자에게는 500만원 이하의 벌금이 부과된다.

**IV. 사이닝보너스**

**1. 사이닝보너스의 의의**

- 사이닝보너스(Signing Bonus)란 특정 근로자를 영입하거나 핵심 인력을 확보하기 위하여, 근로계약 체결 시점에 일시금 형태로 지급되는 금전을 의미한다. 이는 일반적인 근로 대가로서의 임금이 아니라, 주로 입사 유인 또는 일정 기간 이상의 근속을 조건으로 지급된다.

**2. 사이닝보너스 계약의 해석방법**

- 사이닝보너스 관련 계약의 해석은 그 금전의 지급 목적, 반환 조건의 명시성, 실제 노무 제공과의 연관성 등 당사자 사이의 약정 내용을 종합적으로 고려하여 실질적으로 이루어져야 한다. 특히, 근속 기간을 조건으로 반환 약정을 두는 경우, 그 약정이 근로자의 퇴직 자유를 부당하게 제한하는지 여부에 초점을 맞춰 해석한다.

### 3. 사이닝보너스의 법적 성격

- 사이닝보너스의 법적 성격은 주로 두 가지 측면에서 검토된다.

#### (1) 임금성

- 사이닝보너스가 근로기준법상 임금에 해당하는지 여부는 노무 제공의 대가로서 지급되었는지 여부에 따라 결정된다. 판례는 통상적인 근무에 대한 대가라기보다는 입사 유인 또는 일정 기간 근속을 조건으로 지급되는 것이므로, 노무 제공 자체의 대가가 아닌 경우 임금으로 보지 않는 경향이 있다. 다만, 구체적인 계약 내용에 따라 달라질 수 있다.

#### (2) 위약 예정 금지와의 관계

- 근로자가 약정 근속 기간을 채우지 못하고 퇴직할 경우 사이닝보너스를 반환하도록 하는 약정이 근로기준법 제20조(위약 예정의 금지)에 위반되는지 여부가 쟁점이 된다.

### 4. 사이닝보너스반환약정의 유효성

- 사이닝보너스반환약정이 근로기준법 제20조를 위반하는지 여부에 대하여 판례는 다음과 같이 판단한다. 사이닝보너스가 단순히 근로계약 불이행에 대한 위약금이나 손해배상액의 예정의 성격을 가진다면 근로기준법 제20조에 위반되어 무효이다. 그러나 대부분의 경우 사이닝보너스는 계약 체결이나 근속을 유도하기 위한 일종의 조건부 증여나 근속 장려금 성격을 가지므로, 약정 근속 기간 미달 시 반환하도록 하는 약정은 조건의 미성취에 따른 정산 개념으로 보아 유효하다고 판단한다.

### 5. 사이닝보너스의 반환의무

- 사이닝보너스의 반환 의무는 근로자가 약정된 최소 근속 기간을 충족하지 못하고 퇴직할 때 발생한다. 반환 범위에 있어서는 근속 약정 기간을 기준으로 남은 기간에 비례하여 반환하는 것이 일반적이다. 예를 들어, 2년 근속 약정 하에 사이닝보너스를 수령하고 1년 후 퇴직하면 잔여 1년에 해당하는 금액을 반환하게 된다. 반환 조건과 범위는 근로계약서나 별도의 약정에 명확하게 규정되어야 한다.

## V. 결론

- 근로계약의 체결은 근로 관계 성립의 가장 중요한 요소이며, 당사자의 자유로운 의사에 따라 체결되는 낙성·쌍무계약의 성질을 가진다. 그러나 근로기준법은 균등처우 원칙과 금지되는 근로 조건 규정을 통해 계약 자유를 제한하여 근로자를 보호한다. 특히, 근로 조건을 법정 기준에 미달하게 정한 경우 그 부분은 무효가 되고 법정 기준으로 보충되는 효과를 낳는다. 사이닝보너스 약정은 근로자 영입 수단으로 사용되지만, 반환 약정이 근로기준법상 위약 예정 금지에 위반되지 않으려면 순수한 조건부 근속 장려금의 성격을 가져야 하며, 퇴직 자유를 부당하게 제한해서는 안 된다. 결국 근로계약은 사적 자치와 국가 개입의 조화 속에서 근로자의 보호를 최우선으로 하는 법률 행위라고 할 수 있다.



## I. 근로관계의 의의

- 근로관계란 근로자가 사용자에게 노무를 제공하고 사용자는 그 대가로 임금을 지급하는 것을 내용으로 하는 법률 관계를 의미한다. 근로관계는 단순히 노동력을 거래하는 민사 관계를 넘어, 사용자의 지휘·명령권과 근로자의 종속 관계가 형성되는 특수성을 가진다. 근로관계의 성립은 개별적 근로관계법인 근로기준법을 비롯한 모든 노동법적 보호의 기초가 된다. 근로관계는 근로계약을 통해 발생하며, 계약의 내용대로 근로가 현실적으로 제공되는 상태를 포괄하는 개념이다.

## II. 근로계약과 근로관계

- 근로계약과 근로관계는 서로 밀접하게 연관되어 있으나, 그 개념과 발생 시점에는 차이가 있다.

### 1. 근로계약

- 근로계약은 당사자 간의 합의에 의해 장래 근로관계를 발생시키는 것을 목적으로 하는 법률 행위이다. 이는 낙성계약으로서 당사자 간의 의사 합치만으로 성립하며, 근로 제공이 현실적으로 이루어지기 전에 성립할 수 있다. 근로계약은 근로관계의 내용을 규정하는 기준이 되지만, 근로기준법 등 강행 법규에 의해 그 내용의 자유가 제한된다.

### 2. 근로관계

- 근로관계는 근로계약의 체결과 더불어 근로 제공이 현실적으로 시작되어 근로자가 사용자의 지휘·명령 하에 종속되어 있는 계속적 사실 관계이자 법률 관계이다. 근로관계가 성립해야 비로소 해고 제한, 휴가 부여, 퇴직금 지급 등 근로기준법상 모든 권리와 의무가 현실적으로 발생한다. 따라서, 근로관계는 근로계약을 기초로 하지만, 실제 노무 제공이라는 사실을 통해 구체화되고 지속되는 법적 상태를 의미한다.

### 3. 양자의 관계

- 근로계약은 근로관계를 발생시키는 원인 행위이고, 근로관계는 근로계약에 따라 발생하고 유지되는 결과 상태이다. 근로계약이 무효나 취소로 효력을 잃더라도, 이미 제공된 노무에 대해서는 사실상 근로관계가 존재했던 것으로 보아 임금 등의 법적 보호를 받을 수 있다. 근로관계의 존부는 근로계약의 형식보다 실질적인 사용종속관계를 통해 판단된다.

### 4. 통설과 판례

- 유효한 근로계약이 체결되면 이와 동시에 근로관계가 성립한다는 견해(계약설)와 유효한 근로계약 이외에 근로자의 작업개시 또는 경영체계의로의 편입이라는 사실적 요소가 필요하다는 견해(편입설)가 있으나, **판례**는 근로관계가 성립하기 위하여는 양 당사자 사이에 명시적 또는 묵시적으로 체결된 계약이 있거나, 기타의 법적 근거가 있어야 한다고 하여 계약설의 입장을 취하고 있다.

## III. 비전형적 근로관계

- 비전형적 근로관계란 정규직 근로계약처럼 확정적이고 완전한 근로관계가 아닌, 장래 본 계약 체결을 예정하거나, 본격적인 근로관계 성립 전 일정한 평가기간을 두는 등 특수한 형태로 성립되는 근로관계를 의미한다. 대표적으로 채용내정과 시용이 있다.

### 1. 채용내정

#### (1) 의의

- 채용내정은 사용자가 근로자에게 장래 일정한 시점(주로 졸업 후)에 근로계약을 체결할 것을 약속하고, 근로자가 이를 승낙함으로써 성립되는 관계이다. 주로 신입 채용에서 발생하며, 내정 통보 후 입사 전까지의 기간 동안 일반적인 근로관계는 아니지만 특정 법적 효력을 가지는 상태를 말한다.

#### (2) 법적 성격

- **판례**는 채용내정을 해약권이 유보된 근로계약으로 본다. 즉, 내정 통보와 승낙이 있을 때 이미 근로계약은 성립하지만, 사용자가 일정한 사유(졸업 요건 미달 등)가 발생하면 일반적으로 계약을 해지(해약)할 수 있는 권한을 유보한 것으로 해석한다.

#### (3) 해약권의 행사

- 사용자의 해약권 행사는 일반적인 근로계약의 해지와 동일하게 취급되어, 근로기준법상 해고 제한 법리가 유추 적용된다. 즉, 사용자가 채용내정을 취소(해약권 행사)하기 위해서는 정당한 이유가 있어야 하며, 채용내정 당시 유보된 취소 사유라 할지라도 그 사유가 사회통념상 합리적인 것이어야 한다. 정당한 이유 없이 취소하면 부당해고와 마찬가지로 무효가 될 수 있다.

### 2. 시용

#### (1) 의의

- 시용(試用)은 본 채용 전, 근로자의 업무 적격성, 능력, 인성 등을 평가하기 위하여 일정 기간 동안 시험적으로 근로를 제공하는 것을 의미한다. 시용 기간 동안 근로자는 사용자의 지휘·명령 하에 실질적인 노무를 제공한다.

#### (2) 법적 성격

- 시용은 해약권이 유보된 근로계약이라는 점에서 채용내정과 동일한 성격을 가진다. 다만, 채용내정은 노무 제공 개시 전의 상태인 반면, 시용은 실제 노무 제공이 시작된 상태라는 차이가 있다. 따라서, 시용 기간 중에는 근로기준법이 적용되며, 시용 근로자도 근로기준법상 근로자로서 보호받는다.

#### (3) 본 채용 거부(해약권 행사)

- 시용 기간이 종료된 후 사용자가 본 채용을 거부하는 것(시용 계약의 해지) 역시 해약권 행사로 간주되며, 근로기준법상 해고 제한 법리가 유추 적용된다. 다만, 시용은 근로자의 적격성 평가라는 목적이 있으므로, 정규 채용 근로자에 대한 해고 사유보다는 더 넓게 정당성을 인정한다. **판례**는 본 채용 거부가 객관적이고 합리적인 이유에 근거하고, 사회통념상 상당하다고 인정되는 경우에 한하여 정당성이 인정된다고 판시한다. 단순히 마음에 들지 않는다고 같은 주관적인 이유는 정당한 이유가 될 수 없다.

#### (4) 시용 기간 중의 해고

- 시용 기간 중에 사용자가 근로자를 해고하는 경우, 이는 해약권 행사가 아니라 일반적인 해고에 해당하며, **근로기준법 제23조**의 정당한 이유가 요구된다. 다만, 시용 기간이 3개월 이내인 경우에는 **근로기준법 제26조**에 따른 해고 예고 의무가 적용되지 않는다.

## IV. 결론

- 근로계약은 근로관계의 발생을 목적으로 하는 원인 행위이며, 근로관계는 계약을 기초로 실제 노무 제공을 통해 발생하고 지속되는 사용종속적 결과 상태이다. 채용내정과 시용은 근로관계 성립의 과도기적인 형태인 비전형적 근로관계로서, **판례**는 두 가지 모두 해약권이 유보된 근로계약으로 본다. 채용내정 취소나 시용 기간 종료 후 본 채용 거부는 근로기준법상 해고 제한 법리가 유추 적용되어 정당한 이유가 있어야 효력이 인정된다. 이는 근로자의 계속 근로에 대한 기대권을 보호하고 사용자의 자의적 계약 해지를 방지하여 노동법적 안정성을 확보하기 위함이다.



## I. 의의

- 근로계약은 근로자의 노무 제공 의무와 사용자의 임금 지급 의무를 주된 내용으로 하는 쌍무 계약이다. 근로계약의 체결은 당사자 간에 근로관계를 형성하며, 이에 따라 각각 상대방에 대하여 주된 권리와 의무를 부담할 뿐만 아니라, 신의성실의 원칙 등 민법의 일반 원칙에 기초한 종된 권리와 의무 역시 발생한다. 이러한 권리와 의무의 법적 내용은 근로관계의 본질을 이루며, 노동법의 규제를 통해 근로자 보호와 사업 운영 간의 균형을 도모한다.

## II. 근로자의 권리

### 1. 주된 권리-임금청구권

- 근로자의 주된 권리는 근로 제공의 대가로서 사용자에게 임금을 청구할 수 있는 임금청구권이다. 임금은 근로자의 생존권을 보장하는 핵심 요소이므로, 근로기준법은 임금의 정지, 지급 방법, 최저임금 등을 강력하게 규율하여 임금청구권의 실질적 보장을 도모한다. 임금청구권은 근로계약이 유효하게 존속하는 한, 약정된 근로를 제공했거나 사용자의 책임 있는 사유로 노무 제공이 불가능했던 경우 발생한다. 특히 근로기준법은 임금 전액 지급, 통화 지급, 매월 1회 이상 정기적 지급 등의 원칙을 규정하여 임금 체불을 방지하고 근로자의 경제적 안정을 강화한다.

### 2. 종된 권리-취업청구권

- 취업청구권은 근로자가 사용자에게 노무를 제공할 수 있도록 사용자가 일감을 제공하거나 근무 장소에 출입할 수 있도록 허용해 줄 것을 청구하는 권리이다. 임금이 주로 노무 제공의 대가인 만큼 취업청구권은 원칙적으로 인정되지 않는다고 보는 것이 통설적 견해이다. 그러나 근로자가 근로를 통해 얻는 숙련도 향상, 명예 등 비경제적 이익이나 성과급, 능력급 등 실적에 따라 임금이 변동되는 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 취업청구권이 인정될 수 있다는 것이 판례의 태도이다. 이러한 경우 취업청구권은 단순한 노무 수령 채권을 넘어 근로자의 인격적 이익 보호 측면에서 종된 권리로 인정된다.

## III. 근로자의 의무

### 1. 근로제공의무

- 근로제공의무는 근로계약의 가장 주된 의무로서, 사용자의 지휘·명령 하에 근로계약에서 정한 내용대로 성실하게 노무를 제공해야 할 의무를 말한다. 이는 단순한 노동력 제공을 넘어, 사용자의 업무상 합리적인 지시와 규율을 따를 의무(복종 의무)를 포함한다. 근로자가 정당한 이유 없이 근로 제공을 거부하거나 태만히 하는 경우에는 채무 불이행에 해당하여 사용자에게 징계나 해고의 정당한 사유가 될 수 있다.

### 2. 충실의무

- 충실의무는 근로관계의 신뢰 관계를 바탕으로 근로자가 사용자의 이익을 배려하고 손해를 가하지 않도록 성실하게 행동해야 할 부수적 의무이다. 이 의무는 근로계약 기간 중에 발생하며, 사용자의 기업 비밀 보호, 명예 훼손 금지, 사내 규율 준수 등 광범위한 내용을 포함한다. 근로자가 충실 의무를 위반하여 사용자에게 손해를 입힌 경우 민사상 손해배상 책임을 지거나, 징계 사유가 될 수 있다.

### 3. 경업금지의무

- 경업금지의무는 근로자가 근로계약 기간 중 사용자의 동의 없이 사용자의 사업과 경쟁 관계에 있는 사업을 영위하거나 경쟁 업체에 취업해서는 안 되는 의무이다. 이는 충실의무의 특수한 형태로서 사용자의 영업 비밀과 이익을 보호하기 위한 것이다. 다만, 퇴직 후의 경업 금지 약정은 직업 선택의 자유를 제한하므로, 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 직업 선택 자유 침해 정도, 대가 제공 여부, 기간 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 범위 내에서만 유효성이 인정된다.

### 4. 비밀유지의무

- 비밀유지의무는 근로자가 근로 기간 중 업무 수행 과정에서 알게 된 사용자의 영업상 또는 기술상 비밀을 누설하거나 부당하게 이용해서는 안 되는 의무이다. 이 의무는 근로계약의 존속 중은 물론, 퇴직 후에도 경업 금지 약정 등을 통해 계속될 수 있다. 보호 대상이 되는 비밀은 공공연하게 알려지지 않은 것으로서 독립된 경제적 가치를 가지며, 사용자가 비밀로 관리해온 정보를 말한다. 비밀유지 의무 위반 시 민사상 손해배상 책임뿐만 아니라, 부정경쟁방지법 등에 따라 형사 처벌을 받을 수 있다.

### 5. 진실고지의무

- 진실고지의무는 근로자가 근로계약 체결이나 근로관계 유지와 관련하여 사용자의 합리적인 경영 판단에 영향을 미치는 중요한 정보(예 : 학력, 경력, 건강 상태, 징계 기록)에 대하여 진실을 고지해야 할 의무이다. 이는 근로계약 체결 과정에서의 신의칙 상 파생되는 의무이며, 사용자의 인사권 행사의 기초가 된다. 다만, 근로자의 사생활 영역에 속하거나 업무와 무관한 사항에 대해서는 고지 의무가 인정되지 않는다. 중요한 정보를 허위로 고지하거나 은폐한 경우 이는 징계나 해고의 정당한 사유가 될 수 있다.

## IV. 근로자의 책임

### 1. 위험작업에서의 책임제한

- 근로자가 근로 제공 과정에서 사용자에게 손해를 입힌 경우 민법상 채무 불이행 또는 불법 행위에 따라 손해배상 책임을 진다. 그러나 근로 행위는 본질적으로 사용자의 지시와 규율 하에 이루어지며, 근로자는 사용자와 달리 위험 분산 능력이 없다는 특수성을 고려하여 그 책임이 제한된다. 판례는 위험이 수반되는 작업에서 근로자에게 손해배상 책임을 물을 때, 사용자의 지휘·감독 정도, 시설 관리 소홀 여부, 근로자의 과실 정도 등을 종합적으로 고려하여 책임의 범위를 상당히 경감하는 책임 제한 법리를 적용한다.

### 2. 결손책임

- 결손책임이란 근로자가 업무상 재산 관리 등의 사무를 처리하면서 발생시킨 재정적 손해(결손)에 대하여 사용자에게 책임을 지는 것을 의미한다. 대표적으로 판매원의 상품 손실, 회계 담당자의 착오 등이 있다. 이러한 결손에 대하여 근로자의 고의 또는 중대한 과실이 있을 때 책임을 지는 것이 원칙이다. 다만, 사용자가 미리 손해배상액을 예정하거나 근로자에게 일방적으로 책임을 전가하는 약정은 근로기준법 제20조의 위약 예정 금지 규정에 위반되어 무효이다.

## V. 사용자의 권리

### 1. 주된 권리-근로수령채권

- 사용자의 주된 권리는 근로계약에서 정한 내용에 따라 근로자로부터 노무를 제공받을 수 있는 권리인 근로수령채권(노무 수령 채권)이다. 이 권리는 근로자의 근로제공의무에 대응하는 주된 권리로서, 사용자가 사업 목적을 달성하기 위한 가장 핵심적인 권능이다. 사용자는 정당한 이유 없이 근로 수령을 거부해서는 안 되며, 거부 시 근로자에게 임금 지급 의무(휴업 수당 등)를 지게 된다.

### 2. 종된 권리-지휘명령권·시설관리권

- 사용자의 종된 권리는 근로 제공의 효율성과 질서 유지를 위하여 근로자에게 업무 수행에 관한 지시를 내릴 수 있는 권리인 지휘명령권과 사업장 시설 및 재산을 관리하고 규율할 수 있는 권리인 시설관리권이다. 지휘명령권은 근로자의 복종 의무에 대응하며, 사용자가 구체적인 노무 제공 방식, 근로시간, 장소 등을 정할 수 있는 권한이다. 다만, 이러한 권리 행사는 근로계약의 범위 내에서 정당하고 합리적인 이유가 있어야 하며, 근로자의 인권이나 사생활을 침해해서는 안 된다.

## **VI. 사용자의 의무**

### **1. 임금지급의무**

- 사용자의 가장 주된 의무는 근로자에게 근로의 대가로서 약정된 임금을 지급할 의무인 임금지급의무이다. 이 의무는 근로자의 임금청구권에 대응하며, 근로기준법이 정하는 최저 기준 이상으로 이행되어야 한다. 임금지급의무는 근로 제공이 완료된 후 발생하는 것이 원칙이지만, 사용자의 귀책사유로 휴업한 경우 휴업 수당을 지급해야 할 의무(**근기법 제46조**) 등 근로 제공이 없더라도 발생하는 특별한 의무도 존재한다. 임금 미지급은 근로기준법 위반으로 형사 처벌의 대상이 된다.

### **2. 근로수령의무**

- 근로수령의무는 사용자가 근로자의 노무 제공을 정당한 이유 없이 거부하지 않고 수령해야 할 의무이다. 이는 근로자에게 취업청구권이 인정되는 경우 중된 의무로서 의미를 가질 수 있다. 사용자가 근로수령을 거부하는 행위는 근로자에게 실질적인 불이익을 초래할 수 있으므로, 사용자의 귀책사유로 인해 근로수령이 불가능해진 경우에는 민법의 채권자 지체 책임 또는 근로기준법상 휴업 수당 지급 책임을 부담한다.

### **3. 안전배려의무**

- 안전배려의무는 사용자가 근로계약 상 또는 신의칙 상 가지는 부수적 의무로서 근로자가 안전하고 건강한 환경에서 근로를 제공할 수 있도록 물적·인적 보호 조치를 취할 의무이다. 이는 **산업안전보건법** 등 공법상 의무로도 강화되어 있으나, 근로계약 자체에서 파생되는 사법상 의무이기도 하다. 사용자가 안전배려의무를 위반하여 근로자가 산업재해를 입은 경우, 산재보험 외에 별도로 민사상 손해배상 책임을 부담할 수 있다.

### **4. 균등대우의무**

- 균등대우의무는 **근로기준법 제6조**에 명시된 균등처우의 원칙에 따라 사용자가 근로자를 국적, 신앙, 사회적 신분 등을 이유로 근로 조건에 대하여 차별해서는 안 되는 의무이다. 이는 근로자의 인격 존중과 평등권 보장을 위한 강행적 의무이며, 차별 여부는 합리적인 이유의 존재 여부를 통해 엄격하게 판단된다. 합리적인 이유 없는 차별은 무효가 되며, 법적 제재를 받을 수 있다.

### **5. 공법상의 의무**

- 사용자는 **근로기준법**, **산업안전보건법**, **고용보험법** 등 각종 노동관계법에 따라 다양한 공법상의 의무를 부담한다. 예를 들어 근로계약 서면 명시 의무(**근기법 제17조**), 해고 예고 의무(**근기법 제26조**), 퇴직금 지급 의무(**근로자퇴직급여보장법**), 4대 보험 가입 및 납부 의무 등이 있다. 이러한 의무들은 국가가 근로자의 보호를 위하여 사용자에게 강제하는 것으로서, 위반 시 과태료나 형사 처벌 등의 공법상 제재를 받게 된다.

## **VI. 결론**

- 근로계약의 체결로 발생하는 당사자의 권리와 의무는 단순히 노무와 임금이라는 대가 관계를 넘어, 사용종속관계와 인격적 요소가 강하게 작용하는 노동법적 특징을 가진다. 근로자는 임금청구권을 주된 권리로 가지고 근로제공의무 등을 이행하며, 사용자는 근로수령채권을 주된 권리로 가지고 임금지급의무, 안전배려의무 등을 부담한다. 특히 근로자의 충실의무는 사용자의 이익을 보호하지만, 퇴직 후 경업금지의무 등은 직업 선택의 자유를 고려하여 제한적으로 인정된다. 결국, 이러한 권리와 의무의 법적 규율은 근로관계의 안정적 유지와 근로자의 인간다운 삶 보장이라는 노동법의 최종 목표를 실현하는 근간이 된다.

## <제03장 임금.제01절 임금의 의의.01>

### I. 개념[근기법 제2조 제1항 제5호]

- 근로기준법 제2조 제1항 제5호는 임금에 대하여 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.라고 규정한다. 이 정의를 통해 임금이 성립하기 위해서는 세 가지 요소를 충족해야 한다. ❶ 사용자가 지급하는 물품이어야 한다. 여기서 사용자는 근로계약의 당사자인 사업주를 비롯하여 사업경영담당자, 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 모두 포함한다. ❷ 명칭을 불문해야 한다. 임금이라는 용어를 사용하지 않더라도, 예를 들어 수당, 상여금, 퇴직금 등 어떤 명칭을 쓰든 실질적으로 근로의 대가라면 모두 임금에 포함된다. 이러한 명칭 불문의 원칙은 사용자가 임의로 명칭을 변경하여 법의 규율을 회피하는 것을 방지하기 위함이다. ❸ 가장 핵심적인 요소로서 근로의 대가로 지급되어야 한다. 근로의 대가성은 임금과 다른 금품(예 : 복리 후생비, 은혜적 급부)을 구별하는 결정적 기준이 된다. 근로기준법상 임금으로 인정되어야 비로소 통화 지급, 직접 지급, 전액 지급, 정기 지급 등 근로기준법상 엄격한 임금 보호 규정의 적용을 받을 수 있다.

### II. 법적 성질

#### 1. 학설

- 임금의 법적 성질에 관하여는 크게 두 가지 견해가 대립된다.

##### (1) 대가설(임금일원설)

- 임금을 근로자가 제공한 노무의 대등한 대가로 파악한다. 즉, 임금은 근로계약상 주된 채무인 노무 제공 의무에 대응하는 사용자의 반대 채무로서 그 본질을 이해한다. 이는 임금 결정의 경제적 측면을 강조하며, 근로자의 노동력 가치와 업무 성과에 초점을 맞춘다.

##### (2) 생계비설

- 임금을 근로자 및 그 가족의 생계를 유지하기 위한 사회적 비용으로 파악한다. 이 견해는 임금의 사회적 기능과 근로자의 인간다운 생활 보장이라는 측면을 강조하며, 최저임금 제도 등 사회 정책적 규제의 법적 근거를 제공한다.

##### (3) 혼합설

- 현대 노동관계법에서는 임금 총액에 대해서는 대가설을 주된 법적 성질로 보면서도, 최저임금 등 일정 부분에 대해서는 생계비설의 입장을 반영하는 혼합적 태도를 취한다.

#### 2. 판례

- 판례는 임금의 법적 성질에 대하여 명확하게 대가설(임금일원설)의 입장을 취하고 있다. 어떤 금품이 임금에 해당하는지 여부를 판단할 때, 그 명칭이나 지급 형태가 아닌 근로의 대가로 지급되는지를 실질적 기준으로 삼는다. 구체적으로, 근로자가 근로 제공과 관련하여 사용자에게 지급 의무가 있고, 그것이 계속적·정기적으로 지급되거나 단체협약, 취업규칙 등에 의해 사용자에게 지급 의무가 지워진 경우에 한하여 임금으로 인정한다. 따라서, 사용자의 호의나 은혜적 차원에서 일회적으로 지급되는 금품, 또는 근로 제공과 직접적인 관련이 없는 경조사비 등은 임금으로 보지 않는다. 이는 근로 제공이라는 계약상 반대급부 성격을 임금의 본질로 확인한 것이다.

#### 3. 검토

- 근로기준법 제2조의 정의 규정과 판례의 일관된 태도를 종합할 때, 임금의 주된 법적 성질은 대가설에 기초한다고 보는 것이 타당하다. 임금은 근로자의 노동력 제공에 대한 사용자의 경제적 보상이라는 본질적 기능을 가지며, 이는 근로계약의 가장 핵심적인 내용이기 때문이다. 물론, 최저임금제 등 노동법의 보호 규정은 생계비 보전이라는 사회 정책적 목적을 내포하고 있으나, 이는 대가설을 부정하는 것이 아니라, 임금 계약의 자유를 공공 질서의 측면에서 제한하는 것으로 이해해야 한다. 따라서, 개별 근로관계법상 임금의 정의는 노무 제공의 대가로서의 성격을 최우선으로 한다.

### III. 구체적 내용

#### 1. 사용자가 근로자에게 지급하는 물품

##### (1) 지급 주체

- 지급 주체는 원칙적으로 근로계약을 체결한 사용자여야 한다. 제3자가 지급하는 금품(예 : 고객의 팁, 복지 재단이 별도로 지급하는 지원금)은 사용자의 지배 관리 하에 운영되거나 단체협약 등에 따라 사용자의 지급 의무가 명시되지 않는 한 원칙적으로 임금으로 보지 않는다. 다만, 사용자가 실질적으로 제3자에게 지급을 위임하거나 보조금을 지급하는 등 간접적 개입이 있는 경우에는 개별적 판단이 필요하다.

##### (2) 지급 물품의 형태

- 근로기준법상 임금은 원칙적으로 통화로 지급되어야 한다(통화 지급 원칙). 따라서, 현물 또는 물품의 형태로 지급되는 것은 예외적으로만 인정된다. 근로기준법 제43조는 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 통화 외의 것으로 지급할 수 있도록 제한하고 있다. 이러한 현물 지급 제한은 근로자가 임금을 자유롭게 사용할 수 있도록 그 가치의 안정성과 확실성을 보장하기 위함이다.

#### 2. 근로의 대가

- 임금의 정의에서 가장 중요한 요소는 그 금품이 근로의 대가로 지급되어야 한다는 점이다. 대가성 판단은 임금 인정 여부의 핵심이다.

##### (1) 대가성의 의미

- 대가성이란 근로자가 노무를 제공한 것에 대한 보상 또는 그 노무 제공을 전제로 사용자가 지급할 의무를 지는 것을 의미한다. 이는 반드시 노동력의 양이나 질에 정비례하여 지급되는 것을 요구하지는 않는다. 오히려 사용자가 그 지급에 관하여 의무를 지고 있는지 여부가 중요하다. 계속적이고 정기적인 지급 관행, 단체협약이나 취업규칙 등에 명시된 지급 의무 등은 대가성을 뒷받침하는 주요 징표가 된다.

##### (2) 대가성이 부정되는 경우

- 다음과 같은 금품은 원칙적으로 근로의 대가성이 부정되어 임금으로 보지 않는다.

###### ① 사용자의 은혜적 급부

- 근로자의 특정 노무 제공과 직접적인 관련 없이 사용자의 호의 또는 경영상 재량으로 일시적으로 지급하는 금품이다. 예를 들어 경영 성과에 따라 일시적으로 지급하는 격려금 중 노사 간의 지급 의무 약정이 없는 경우가 여기에 해당한다.

###### ② 복리후생적 급부

- 근로자의 실비 변상 또는 근로자의 생활 편의 및 복지 증진을 목적으로 지급하는 금품이다. 예를 들어 숙직비 중 실비 변상적 성격의 금품, 경조사비, 출장비 등이 이에 해당한다. 이러한 금품은 노동력 제공의 반대 급부가 아니라 근로관계 존속에 따른 부수적 지원 성격이 강하다.

###### ③ 실비변상액

- 근로자가 업무 수행을 위하여 지출한 비용을 보전해 주는 금품이다. 식대, 교통비, 통신비 등의 명목으로 지급되더라도 그 실질이 실비 변상 성격이 강하다면 임금으로 보지 않는다. 다만, 그 금액이 실비 변상액을 훨씬 초과하여 실질적으로 근로의 대가를 포함하고 있다면 그 초과분은 임금으로 볼 수 있다.

### IV. 결론

- 임금은 근로기준법상 근로자 보호의 핵심 대상으로서, 그 개념은 사용자가 근로의 대가로 지급하는 일체의 금품이라는 세 가지 요소로 구성된다. 이 중 가장 중요한 법적 성질은 근로 제공에 대한 대가라는 대가설적 성격이며, 판례 역시 지급의 의무성과 대가성을 중시하여 임금 여부를 판단한다. 복리후생적 금품이나 은혜적 급부 등은 대가성이 부정되어 임금 보호 규정의 적용을 받지 않으므로, 개별 금품의 실질적 대가성을 판단하는 것이 노동법적 쟁점의 핵심이다. 이러한 임금의 법적 성질 규정은 근로자의 생존권 확보를 위한 최소한의 제도적 장치로 기능한다.

**I. 평균임금의 개념 및 취지**

**1. 개념[근기법 제2조 제1항 제6호]**

- 근로기준법 제2조 제1항 제6호는 평균임금에 대하여 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.라고 규정한다. 평균임금은 근로자가 통상적으로 제공한 근로의 가치에 대한 보상을 평균하여 산정하는 것으로, 근로자의 일상적인 생활 수준을 반영하는 것을 목적으로 한다. 여기서 임금의 총액에는 근로의 대가로 지급된 모든 금품이 포함되며, 산정 사유 발생일은 퇴직일이나 사고 발생일 등 평균임금 산정의 기준이 되는 날을 말한다. 이는 하루 평균 임금액을 산출하는 개념으로서, 실질적인 근로자의 임금 수준을 가장 잘 나타내도록 설계되었다.

**2. 취지**

- 평균임금 제도의 취지는 근로관계의 종료나 재해 발생 등 특별한 사유가 발생했을 때, 근로자가 직전에 영위했던 통상적인 생활 수준을 보장하는 데 있다. 특히 퇴직금, 휴업수당, 연차수당, 재해보상금, 감급액 등은 근로자의 생계와 직결되는 중요한 금품이므로, 이들을 산정할 때 근로자가 현실적으로 받아왔던 임금을 기초로 공정하게 산정하여 근로자를 보호하고자 한다. 평균임금은 일시적인 사정이나 변동에 좌우되지 않고, 일정 기간의 임금을 평균함으로써 근로자가 실제로 누렸던 경제적 지위를 충실히 반영하려는 목적을 가진다. 따라서 이는 법정 수당 및 보상금 산정의 공정성을 확보하는 기능을 수행한다.

**II. 평균임금을 기초로 산정하여야 할 경우[근기법 제34조(근퇴법 제8조 제1항), 제46조, 제79조 내지 제85조, 제95조]**

- 평균임금을 기초로 하여 산정해야 하는 경우는 근로기준법 및 관련 법령에 명확히 규정되어 있다. 주된 적용 사례는 다음과 같다. ① 근로자퇴직급여 보장법 제8조 제1항에 따른 퇴직급여(퇴직금) 산정의 기초가 된다. 퇴직금은 계속 근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 지급해야 한다. ② 근로기준법 제46조에 따른 휴업수당 산정 시 적용된다. 사용자 귀책사유로 휴업하는 경우 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급해야 한다. ③ 근로기준법 제79조부터 제85조에 규정된 재해보상금 산정의 기초가 된다. 구체적으로 요양보상, 휴업보상, 장해보상, 유족보상, 장례비 등 각종 재해보상금은 평균임금을 기준으로 하여 지급일수나 비율이 결정된다. ④ 근로기준법 제95조에 따른 감급액 산정 기준이 될 수도 있다. 이 외에도 평균임금 산정이 필요한 다양한 경우에 적용되어 근로자의 권리 보호에 중요한 역할을 수행한다.

**III. 평균임금에 산입되는 임금의 범위**

**1. 의의**

- 평균임금에 산입되는 임금의 범위는 근로의 대가로 지급된 임금의 총액을 의미한다. 근로기준법상 임금은 그 명칭에 관계없이 사용자가 근로자에게 근로의 대가로 지급하는 일체의 금품을 포함하므로, 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액 역시 그 실질이 근로의 대가인 모든 금품을 포함한다. 따라서 정기적이고 일률적으로 지급되는 기본급, 각종 수당뿐만 아니라, 근로의 대가성이 인정되는 상여금이나 연차 유급휴가 미사용 수당 등도 포함된다. 다만, 근로의 대가성이 없거나 산정 기간과 관계없이 지급된 금품은 제외된다.

**2. 평균임금에 산입되는 임금인지 여부**

- 어떤 금품이 평균임금 산정에 포함되는지는 그 금품이 근로기준법상 임금에 해당하는지 여부, 그리고 산정 사유 발생일 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급되었는지 여부에 따라 결정된다.

**(1) 포함되는 주요 임금**

**① 정기적 고정적 임금**

- 기본급, 직책수당, 기술수당 등 근로의 대가로서 정기적·일률적으로 지급되는 모든 고정적인 임금은 당연히 포함된다.

**② 변동적 임금**

- 연장·야간·휴일근로 수당, 연차 유급휴가 미사용 수당 등 근로 실적에 따라 변동적으로 지급되는 임금이라도 근로의 대가성이 인정되는 한 포함된다. 다만, 연차 유급휴가 미사용 수당 중 퇴직 전에 이미 발생한 휴가 일수에 대한 보상은 산입되지만, 퇴직으로 인해 비로소 지급 사유가 발생한 미사용 휴가 수당은 산입되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

**③ 상여금 등 비정기적 임금**

- 단체협약이나 취업규칙 등에 지급 기준이 명시되어 있고 계속적·정기적으로 지급되는 상여금은 근로의 대가성이 인정되어 임금 총액에 포함된다. 다만, 산정 방식이 다소 특수하여, 지급된 총액 중 산정 기간 3개월에 해당하는 금액만을 산입해야 한다.

**(2) 제외되는 금품**

**① 복리후생적 금품**

- 근로자의 복리 증진을 위한 경조금, 학자금, 작업복 등 실비 변상 또는 은혜적 성격의 금품은 근로의 대가성이 없어 제외된다.

**② 퇴직금**

- 퇴직금은 근로의 대가가 아니라 퇴직이라는 근로관계 종료를 요건으로 지급되는 것이므로, 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에 포함되지 않는다.

**③ 은혜적 금품**

- 사용자의 일방적인 호의로 지급되는 위로금, 격려금 등 지급 의무가 없는 금품은 임금성이 부정되어 제외된다.

**IV. 평균임금의 산정방법**

**1. 의의**

- 평균임금의 산정은 산정 사유 발생일 이전 3개월 동안 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나누어 1일 평균액을 산출하는 방식이다. 여기서 지급된 임금의 총액이라 함은 실제로 지급된 임금뿐만 아니라, 근로의 대가성이 인정되어 마땅히 지급되었어야 할 임금까지 포함하는 개념이다. 또한 그 기간의 총일수는 역일(曆日)에 따라 3개월간의 일수를 모두 합산하며, 통상 최소 89일, 최대 91일이 된다.

**2. 평균임금 산정에서 제외되는 기간과 임금**

- 평균임금의 공정한 산정을 저해할 우려가 있는 기간에 대해서는 그 기간과 그 기간 동안에 지급된 임금을 임금 총액 및 총일수 산정에서 모두 제외한다.

**(1) 제외되는 기간**

- ① 수습 사용 기간. ② 사용자의 귀책사유로 인한 휴업 기간. ③ 산전후휴가 및 육아휴직 기간. ④ 쟁의행위 기간. ⑤ 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴업 기간. ⑥ 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에 따른 가족 돌봄 휴직 기간

**(2) 제외 기간의 특성**

- 이러한 기간은 근로자가 정상적인 근로를 제공하지 못했거나, 사용자의 경영 상황 악화 등 특별한 사정으로 인해 임금 수준이 현저히 낮아졌을 가능성이 있는 기간이므로, 이를 포함하여 평균을 내면 근로자의 통상적 생활 수준을 반영하지 못하게 된다. 따라서 이 기간과 그에 상응하는 임금은 산정에서 제외하여 나머지 기간을 기준으로 평균임금을 산정한다.

### 3. 통상임금보다 적은 경우

- 평균임금은 근로자의 통상적인 생활 수준을 보장하는 것이 목적인데, 만약 산정된 평균임금액이 그 근로자의 통상임금보다 낮을 경우에는 근로기준법의 보호 원칙에 따라 그 통상임금액을 평균임금으로 본다. 통상임금은 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정해진 금액으로서, 법이 보장하는 최소한의 임금 수준을 의미한다. 따라서, 평균임금이 통상임금에 미달하는 경우에는 통상임금을 하한선으로 보장함으로써 근로자의 불이익을 방지하고 평균임금 제도의 취지를 달성한다.

### 4. 평균임금을 산정할 수 없는 특별한 경우의 평균임금

- 평균임금은 원칙적으로 산정 사유 발생일 이전 3개월간의 임금 총액을 기초로 산정하지만, 근로 기간이 3개월 미만인 경우와 같이 특별한 사정이 있어 산정이 곤란한 경우가 발생할 수 있다. 근로 기간이 3개월 미만인 근로자에 대해서는 그 근로 기간 동안 지급된 임금 총액을 그 기간의 총일수로 나누어 산정한다. 또한, 일용직 근로자 등 임금 계산 방식이 특이하거나 기타 사유로 평균임금 산정이 현실적으로 어려운 경우에는 고용노동부장관이 정하는 기준에 따라 산정할 수 있다. 이는 법의 보호 대상에서 제외되는 근로자가 없도록 보호 공백을 메우기 위한 예외적 규정이다.

### V. 결론

- 평균임금은 근로자의 통상적인 생활 수준을 보장하기 위하여 퇴직금, 휴업수당, 연차수당, 재해보상금, 감급액 등 중요한 법정 급여를 산정하는 데 기초가 되는 금액이다. 이는 산정 사유 발생일 이전 3개월간 지급된 임금 총액을 총일수로 나눈 금액으로 정의되며, 그 산정에는 근로의 대가성이 인정되는 모든 임금이 포함된다. 다만, 사용자 귀책사유로 인한 휴업 기간 등 평균임금의 공정한 산정을 저해하는 특별한 기간과 임금은 제외된다. 특히 산정된 평균임금이 통상임금보다 적은 경우에는 통상임금액을 평균임금으로 간주하여 근로자의 권익을 보호하고, 산정이 불가능한 경우에는 고용노동부장관이 정하는 기준에 따르도록 하여 모든 근로자에 대한 보호를 실현한다.

**I. 통상임금의 개념[근기법 시행령 제6조]**

- 근로기준법 시행령 제6조는 통상임금에 대하여 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.라고 정의한다. 통상임금은 근로자가 정상적인 근로시간에 제공하는 근로의 대가로서, 그 금액이 사전에 확정되어 근로자에게 안정적이고 계속적으로 지급될 것이 예정된 임금을 말한다. 여기서 정기적, 일률적, 고정적이라는 개념적 징표가 중요하게 작용하며, 이는 해고예고수당, 가산수당(연장·야간·휴일근로수당), 출산전후휴가급여, 유급휴일수당, 연차수당 등의 산정 기초가 된다. 통상임금은 근로의 양이나 질과 관계없이, 근로계약이나 취업규칙 등에 따라 근로자에게 당연히 지급될 것이 보장된 임금으로 이해된다.

**II. 통상임금을 기초로 산정하여야 할 경우[근기법 제26조, 제56조, 제74조]**

- 통상임금을 기초로 하여 산정해야 하는 경우는 근로기준법 및 관련 법령에 규정된 가산수당 및 법정 급여 산정 시이다. ❶ 근로기준법 제26조에 따른 해고예고수당 산정 시 적용된다. 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고해야 하며, 30일 전에 예고를 하지 않았을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 지급해야 한다. ❷ 근로기준법 제56조에 따른 가산수당 산정 시 적용된다. 연장근로, 야간근로, 휴일근로에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 한다. ❸ 근로기준법 제74조에 따른 출산전후휴가급여 중 일부 산정 시 적용된다. 최초 60일(다태아의 경우 75일)을 초과하는 기간에 대한 급여를 산정하는 데 통상임금이 기초가 될 수 있다. 이 외에도 유급휴일수당, 연차수당 등 근로기준법상 유급으로 처리되는 각종 수당의 산정 기준으로 통상임금이 활용된다.

**III. 통상임금의 판단기준**

**1. 원칙**

- 통상임금은 근로의 대가로 지급되는 임금이어야 하며, 그 금액이 정기적, 일률적, 고정적으로 지급될 것이 확정되어 있어야 한다. 그 판단은 명칭이나 형식이 아니라, 지급 의무가 근로자에게 정기적이고 일률적으로 지급될 것을 사용자가 미리 확정하고 있는지 여부에 따라 결정된다. 지급 요건이 충족되면 사용자의 추가적인 의사 표시나 별도의 지급 행위 없이 당연히 지급될 것이 확정되어 있어야 한다.

**2. 소정근로의 대가**

- 통상임금은 근로자가 소정 근로 시간에 제공하는 근로의 대가로 지급되는 금품을 의미한다. 소정 근로란 법정 근로 시간 범위 내에서 근로계약으로 정한 근로 시간을 말한다. 통상임금은 이러한 소정 근로의 가치를 평가한 금액이어야 하며, 근로 제공 여부나 성과에 따라 좌우되는 변동적 임금과는 구별된다. 다만, 소정 근로 대가의 범위를 넘어서, 전체 근로에 대하여 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 금품도 통상임금에 포함된다.

**3. 통상임금의 개념적 징표 - 정기성·일률성·고정성**

- 통상임금으로 인정되기 위해서는 다음 세 가지 개념적 징표를 모두 갖추어야 한다.

**(1) 정기성**

- 정기성이란 금품이 일정 간격을 두고 계속적·반복적으로 지급되는 성질을 의미한다. 반드시 매월 지급될 필요는 없으며, 2개월, 3개월, 6개월 등의 주기로 지급되더라도 미리 정해진 주기에 따라 지급되면 정기성이 인정되지만, 일회적이거나 비정기적으로 발생하는 사유에 따라 지급되는 금품은 정기성이 부정된다.

**(2) 일률성**

- 일률성이란 금품이 모든 근로자 또는 특정 조건을 충족하는 전체 근로자에게 일률적으로 지급되는 성질을 의미한다. 여기서 특정 조건은 업무 특성(직책, 직급, 기술)이나 근속 기간 등 소정 근로와 관련된 조건이어야 하며, 개인의 실적이거나 성과 등 불확정적인 조건이 아니어야 한다. 일률성은 근로자 집단에 대한 일반적 지급 가능성을 기준으로 판단한다.

**(3) 고정성**

- 고정성이란 근로자가 소정근로를 제공하기만 하면 지급 여부나 금액이 사전에 확정되는 성질을 의미한다. 근로자가 소정 근로를 제공하면 지급 여부나 지급 액수가 달리 변동될 여지 없이 확정되어 있어야 하며, 근무 실적이거나 성과 평가 등 추가적인 조건에 따라 달라지는 임금은 고정성이 부정된다. 특히, 판례는 특정 시점에 재직 중일 것을 요건으로 하는 임금은 재직 여부라는 추가 조건 성취가 필요하므로 원칙적으로 고정성이 부정된다고 판시한다.

**IV. 통상임금성 인정 여부가 문제되는 사례**

**1. 복리후생비**

- 복리후생비는 원칙적으로 근로의 대가가 아닌 근로자의 생활 편의 및 복지 증진을 목적으로 지급되므로 통상임금성이 부정된다. 다만, 그 명칭이 복리후생비라 할지라도, 예외적으로 실제 모든 근로자에게 일률적으로 지급되고 근로 제공 외의 다른 조건이 없이 고정적으로 지급되는 경우에는 통상임금으로 인정될 수 있다. 판례는 식대, 교통비 등에 대하여 대가성과 고정성 여부를 엄격하게 판단한다.

**2. 일할계산하여 지급하는 정기상여금**

- 정기적이고 일률적으로 지급되는 상여금은 원칙적으로 통상임금에 포함된다. 또한, 지급 시점이 도래하기 전 퇴직한 근로자에게 근로 기간에 비례하여 일할계산하여 지급하는 상여금은 고정성이 인정되어 통상임금으로 인정된다. 이는 근로의 대가로서의 성격이 강하고, 퇴직 등 추가 조건에 의해 지급이 배제되지 않기 때문이다.

**3. 특정 시점에 재직 중일 것을 조건으로 하는 임금**

- 특정 시점(예 : 지급일)에 재직 중일 것을 조건으로 지급하는 임금(예 : 상여금)은 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 재직 조건은 소정 근로 제공 외의 추가적인 조건에 해당하므로, 고정성을 결여한 것으로 본다. 다만, 예외적으로 퇴직자에게도 일할계산하여 지급하도록 약정되어 있다면 고정성이 인정되어 통상임금으로 인정될 수 있다.

**4. 근속기간에 연동하는 임금**

- 근속기간에 따라 지급 액수가 달라지는 임금(예 : 근속수당)은 통상임금성이 인정된다. 근속기간은 근로자가 선택할 수 없는 객관적이고 일률적인 조건이며, 해당 기간을 충족하면 지급이 확정되므로 일률성과 고정성이 인정되기 때문이다.

**5. 근무일수에 연동하는 임금**

- 근무일수에 연동하여 지급되는 임금(예 : 만근수당)은 원칙적으로 고정성이 부정되어 통상임금성이 부정된다. 이는 결근 여부에 따라 지급 액수가 달라지므로 근로 제공 외의 추가적인 조건 성취가 필요하다고 보기 때문이다. 다만, 예외적으로 소정 근로일수 전부를 근무해야 받을 수 있는 것이 아니라 일정 기준을 충족하면 고정적으로 지급되는 경우에는 통상임금으로 인정될 수 있다.

**6. 근무실적에 연동하는 임금**

- 개인의 근무실적, 노력 정도, 성과 평가 등 불확정적인 조건에 따라 지급 여부나 액수가 달라지는 임금(예 : 성과급)은 고정성이 결여되어 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 다만, 예외적으로 최소지급이 보장되어 있다면 인정될 수 있다.

**7. 특수한 기술·경력 등을 조건으로 하는 임금**



- 특수한 기술이나 경력, 면허 등을 조건으로 하여 지급되는 수당(예 : 자격수당, 기술수당)은 통상임금성이 인정된다. 해당 기술 보유 여부는 기왕에 확정된 사실로서 소정 근로 제공과 관련된 일률적 조건이며, 그 조건 성취 후에는 지급이 확정되므로 일률성과 고정성을 모두 충족한다고 본다.

#### 8. 단체협약 등에 의하여 지급이 제한되는 임금

- 단체협약 등에 지급 기준이 명시되어 있더라도, 지급 정지나 제한 조건(예 : 징계, 휴직)이 구체적으로 명시되어 있고 그 조건이 합리적인 경우에도 원칙적으로 통상임금성이 인정된다. 왜냐하면 이러한 조건은 일반적으로 지급이 확정된 후 발생하는 사후적 조건에 불과하여 고정성을 부정하는 본질적인 조건으로 보지 않기 때문이다.

#### 9. 근무일마다 실비변상 명목으로 지급되는 임금

- 근무일마다 지급되는 일당 형태의 실비변상액(예 : 일비, 교통비)은 근로의 대가가 아닌 업무 수행에 필요한 비용의 보전이므로 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 다만, 예외적으로 실비 변상액이라는 명목 하에 실질적으로 근로 제공에 대한 대가의 일부로 지급되는 경우에는 통상임금으로 인정될 수 있다.

#### 10. 재직조건이 부가된 정기상여금 및 보전수당

- 앞선 3.의 내용과 마찬가지로, 특정 시점에 재직 중일 것을 부가 조건으로 하는 정기상여금은 고정성이 부정되어 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 퇴직자에게 일할계산하여 지급하지 않는 한, 지급 시점까지의 근무 여부가 지급 여부를 결정하므로 불확정적인 조건으로 본다.

#### 11. 선택적 복지제도 시행과 관련된 복지포인트

- 선택적 복지제도에 따라 부여되는 복지포인트는 현금 지급이 아니고, 근로 대가성이 부정되며, 사용자가 지급 의무를 지는 임금으로 보기 어려우므로 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 다만, 현금 지급 가능성, 근로 대가성 등 실질적 임금 성격이 강하게 인정되는 경우에는 예외적 검토가 필요하다.

#### 12. 야간교대수당

- 야간교대 근무 등 특정 형태의 근로에 대하여 지급되는 수당 중 근로기준법상 가산수당 범위를 넘어 추가적으로 지급되는 부분은 그 지급이 정기적 · 일률적 · 고정적이면 통상임금성이 인정될 수 있다. 다만, 근로기준법 제56조의 가산수당은 통상임금을 기초로 산정된 결과물이므로 통상임금 자체는 아니다.

#### 13. 단체협약에 따른 임금인상 소급분

- 단체협약 등에 의해 임금이 소급하여 인상되었을 때 지급되는 소급분은 인상된 임금액이 소급하여 지급된 것이므로, 인상된 기본 임금 등이 통상임금 요건을 충족하는 한 소급분도 통상임금 산정에 포함되어야 한다.

#### 14. 고정 O/T 수당

- 실제 연장 근로 시간과 상관없이 매월 일정액을 고정적으로 지급하기로 정해진 연장 근로 수당(고정 OT 수당)은 원칙적으로 통상임금성이 부정된다. 이는 연장 근로 제공이라는 추가 조건에 대한 대가이고, 근로 대가의 일부를 포괄하여 지급하는 것이므로 고정성이 결여된 것으로 본다. 다만, 예외적으로 실제 연장 근로 시간 등이 근로 제공과 무관하게 정액으로 확정되어 있다면 그 부분은 통상임금으로 인정될 가능성이 있다.

### V. 통상임금의 산정방법

#### 1. 원칙

- 통상임금은 근로자에게 정기적으로 지급되는 임금의 총액을 산정 기간의 소정 근로 시간 또는 총 근로 시간으로 나누어 산정한다. 월급제 근로자의 경우, 월급 총액을 월 소정 근로 시간(주 40시간 근무의 경우 209시간)으로 나누어 시간급 통상임금을 산정하는 것이 원칙이다. 일급 또는 주급 근로자는 각각의 임금 액수를 해당 기간의 소정 근로 시간으로 나누어 산정한다.

#### 2. 시간급으로의 환산

- 통상임금을 일급, 주급, 월급 등 어떤 형태로 산정하더라도, 근로기준법상 가산임금 산정 등을 위해서는 시간급 통상임금으로의 환산이 필수적이다. 월급제 근로자의 시간급 통상임금은 다음과 같이 계산한다.

- 시간급 통상임금 = 월 통상임금 총액 / 월의 소정근로시간 수

- 이때 월의 소정근로시간 수는 1일 소정 근로시간 × 주당 평균 근로일수 × 52주 ÷ 12개월 등의 방식으로 계산되며, 일반적으로 주 40시간 근무제 하에서는 209시간이 적용된다.

### VI. 통상임금 배제합의

#### 1. 문제점

- 통상임금 범위에 포함되어야 할 임금(예 : 정기상여금)을 노사 간의 합의(단체협약, 취업규칙 등)를 통해 통상임금 산정에서 제외하기로 합의(통상임금 배제합의)한 경우 그 효력이 문제된다. 이러한 합의는 법정 수당 산정 기초를 낮춤으로써 근로자에게 불이익을 초래할 수 있다.

#### 2. 효력

- 판례는 노사 간의 통상임금 배제합의에 대하여 원칙적으로 무효라고 본다. 통상임금은 근로기준법상 가산임금 등을 산정하기 위한 강행 법규적 기준이므로, 노사 합의로 법이 정한 기준 이하로 근로자에게 불리하게 변경하는 것은 근로기준법 제15조(이 법을 위반한 근로계약)에 위반되어 무효이다. 다만, 최근 판례는 신의칙 위반 여부를 판단하여, 통상임금 재산정으로 인한 추가 법정 수당 청구가 기업의 중대한 경영 위기를 초래하거나 공동의 이익을 위한 합의를 정면으로 위반하는 경우 예외적으로 청구를 제한할 수 있다고 본다.

#### 3. 차액 임금의 청구

- 통상임금 배제합의가 무효로 판단되면, 근로자는 기존에 받았던 법정 수당 등의 금액과 재산정된 통상임금을 기초로 산정된 정당한 법정 수당 금액과의 차액을 사용자에게 청구할 수 있다. 이러한 차액 청구권은 임금채권의 소멸시효(3년) 범위 내에서 인정된다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 신의칙 위반 여부가 쟁점이 될 수 있다.

### VI. 결론

- 통상임금은 근로기준법 시행령 제6조에 따라 정기성, 일률성, 고정성을 모두 갖춘 임금으로서, 근로 제공의 대가를 미리 확정된 금품이다. 이는 연장 근로 가산수당이나 해고예고수당 등 근로자의 권익 보장을 위한 법정 수당 산정의 핵심 기준이 된다. 특히 재직 조건이 부가된 정기상여금 등은 고정성 충족 여부가 주요 쟁점이다. 노사 간의 통상임금 배제합의는 근로기준법 위반으로 원칙적으로 무효이며, 근로자는 재산정된 통상임금을 기초로 한 차액 임금을 청구할 권리가 인정된다. 다만, 신의칙 위반 법리의 적용으로 예외적인 제한이 있을 수 있다.

<제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙.01>

I. 서설

1. 의의

- 임금지급의 원칙이란 근로기준법 제43조 이하에 규정된 사용자가 근로자에게 임금을 지급할 때 반드시 준수해야 할 방법적 규율을 말한다. 이는 통화불, 직접불, 전액불, 정기불의 네 가지 원칙으로 구성된다. 이 원칙들은 근로계약이나 노사 합의를 통해서도 함부로 배제하거나 근로자에게 불리하게 변경할 수 없는 강행규정적 성격을 갖는다.

2. 취지

- 임금지급의 원칙은 근로자의 생존권 보장과 경제적 생활의 안정을 도모하는 데 주된 취지가 있다. 임금은 근로자 및 그 가족의 생계를 유지하는 유일한 수단인 경우가 많으므로, 임금이 확실하고 안정적이며 적절한 방법으로 지급되도록 법이 개입하는 것이다. 구체적으로, 통화불의 원칙은 임금 가치의 안정성을 보장하고, 직접불 및 전액불의 원칙은 중간 착취 및 임금 남용으로부터 근로자를 보호하며, 정기불의 원칙은 근로자 생활의 계획성을 확보하게 한다. 결론적으로, 이 원칙들은 근로자의 임금채권 보호라는 공법적 목적을 갖는다.

II. 임금지급의 방법

1. 통화불의 원칙

- 통화불의 원칙은 임금은 반드시 대한민국에서 강제 통용력이 있는 통화(현금)로 지급되어야 한다는 원칙이다.

(1) 의의

- 이 원칙은 현물, 어음, 주식, 상품권 등 통화 외의 것으로 임금을 지급하는 것을 금지한다. 이는 근로자에게 임금의 가치를 확실하게 보장하고, 사용자가 자신의 생산품 등으로 임금을 대신하여 지급함으로써 근로자의 생활을 침해하는 것을 방지하기 위함이다.

(2) 예외

- 통화불의 원칙은 다음의 두 가지 경우에 한하여 예외가 인정된다. ❶ 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 통화 외의 것으로 지급할 수 있다. ❷ 임금 전액이 아닌 일부 공제의 경우에는 법령 또는 단체협약의 규정이 있는 경우 예외가 인정된다. 다만, 근로자의 동의만으로는 통화불의 원칙 예외가 될 수 없다. 또한, 근로자의 요청이 있고 근로자의 자유로운 사용이 보장되는 경우에는 예외적으로 근로자의 예금계좌로 임금을 이체하는 것(계좌이체)은 통화불의 원칙에 위배되지 않는다고 본다.

2. 직접불의 원칙

- 직접불의 원칙은 임금은 반드시 근로자 본인에게 직접 지급되어야 한다는 원칙이다.

(1) 의의

- 이 원칙은 근로자 본인이 아닌 대리인, 근로자의 친족, 채권자 등 제3자에게 임금을 지급하는 것을 금지한다. 이는 중간 착취를 방지하고, 근로자가 자신의 임금을 자유롭게 처분할 권리를 보장하며, 임금의 지급 확실성을 확보하기 위함이다.

(2) 예외

- 직접불의 원칙에는 원칙적으로 예외가 없다. 근로자가 임금 채권을 타인에게 양도하거나, 임금 지급을 위임하는 경우에도 사용자는 근로자 본인에게 지급해야 하며, 제3자에게 지급하더라도 이는 유효한 임금 지급으로 볼 수 없다는 것이 판례의 태도이다. 다만, 근로자가 사망하여 임금 채권이 상속인에게 승계된 경우 상속인에게 지급하는 것은 예외로 본다.

3. 전액불의 원칙

- 전액불의 원칙은 사용자가 근로자에게 임금의 전액을 지급해야 하며, 임금의 일부를 공제하는 것은 원칙적으로 금지된다는 원칙이다.

(1) 의의

- 이 원칙은 사용자가 임금에서 각종 채무액이나 손해배상액 등을 상계하거나 공제하는 것을 금지하여, 근로자의 실질적인 임금 수령액을 보호하고 사용자의 일방적인 임금 감액 행위를 막기 위함이다.

(2) 예외

- 전액불의 원칙에 대한 예외는 다음의 두 가지 경우에 한하여 엄격하게 인정된다. ❶ 4대 보험료 등 세금 및 공과금과 같이 법령에 의하여 공제하도록 규정된 경우이다. ❷ 노동조합비와 같이 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 일부 공제할 수 있다. 마찬가지로, 근로자의 개별적인 동의만으로는 임금 공제의 정당한 사유가 될 수 없다. 판례는 사용자가 근로자에게 가질 수 있는 채권(대여금 채권)을 임금채권과 상계하는 것은 전액불의 원칙에 위반되어 무효라고 본다.

4. 정기불의 원칙

- 정기불의 원칙은 임금은 매월 1회 이상 일정한 기일을 정하여 지급되어야 한다는 원칙이다.

(1) 의의

- 이 원칙은 근로자의 생활 안정성과 계획성을 보장하기 위함이다. 임금 지급 주기가 너무 길면 근로자가 경제적으로 어려움을 겪을 수 있고, 지급 기일이 불규칙하면 생활 계획을 세우기 어렵다. 따라서, 법은 월 1회 이상의 지급 횟수와 일정한 기일의 지급 시점 모두를 강제한다.

(2) 예외

- 정기불의 원칙에는 두 가지 예외가 있다. ❶ 임시로 지급되는 임금, 수당(비상시 지급하는 임금) 또는 그 밖의 이에 준하는 것에 대하여는 매월 1회 이상의 원칙이 적용되지 않는다. ❷ 상여금, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 1개월을 초과하는 일정 기간마다 지급하는 임금에 대하여도 매월 1회 이상의 원칙이 적용되지 않는다(3개월마다 지급되는 분기 상여금, 6개월마다 지급되는 정기 상여금). 다만, 이러한 예외적인 임금도 지급 주기 내에서는 일정한 기일을 정하여 지급해야 한다.

III. 임금지급의무 위반

1. 벌칙[근기법 제43조, 제109조 제1항·제2항]

- 사용자가 정당한 이유 없이 임금 지급 원칙(제43조)을 위반하여 임금 지급 의무를 이행하지 않는 경우, 근로기준법에 따른 형사 처벌을 받을 수 있다. 근로기준법 제109조 제1항은 임금 지급 원칙을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정한다. 이는 임금 체불 행위에 대해 강력한 처벌을 통해 근로자를 보호하려는 취지이다. 또한, 제109조 제2항에 따라 임금체불죄는 피해자(근로자)의 명시적인 처벌 희망 의사가 있어야 공소 제기가 가능한 반의사불벌죄에 해당한다. 다만, 사용자가 체불된 임금 등을 청산하기 위한 노력을 하지 않거나 상습적인 경우에는 가중 처벌될 수 있다.

2. 지연이자

- 사용자가 정당한 사유 없이 임금 전액을 지급 기일로부터 지급하지 않는 경우, 근로기준법 제37조에 따라 지연이자 지급 의무가 발생한다. 사용자는 임금 지급 사유가 발생한 날(퇴직일 등)부터 14일 이내에 지급해야 하며, 이 기간이 경과된 후 미지급된 임금에 대하여는 그 다음날부터 지급 하는 날까지 지연일수

에 대하여 연 20%의 지연이자를 지급해야 한다. 이는 임금 체불을 억제하고 신속한 임금 지급을 강제하기 위한 제도이다. 다만, 천재지변 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 지연이자 지급 의무가 면제된다.

### 3. 체불사업주의 명단공개 등[근기법 제43조의2 제1항, 제43조의3 제1항]

- 정부는 상습적으로 임금을 체불하는 사업주에 대하여 명단 공개 및 신용제재 등의 행정적 조치를 취함으로써 임금체불을 예방하고 근로자 보호를 강화한다.

#### (1) 체불사업주 명단 공개[근기법 제43조의2 제1항]

- 근로기준법 제43조의2 제1항은 체불사업주의 명단 공개 제도를 규정한다. 명단 공개 대상은 일정 기준(명단 공개 기준일 이전 3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 명단 공개 기준일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 3천만원 이상인 경우)에 해당하는 사업주 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족한 사업주이다. 명단 공개는 신원을 확인할 수 있는 사항과 체불액의 내용을 관보 및 고용노동부 홈페이지 등에 게시하는 방식으로 이루어지며, 이는 사용자에게 불명예를 부여하여 임금체불을 억제하는 효과를 가져온다.

#### (2) 체불자료 제공[근기법 제43조의3 제1항]

- 근로기준법 제43조의3 제1항은 체불사업주에 대한 신용제재를 위해 체불자료 제공 제도를 규정한다. 일정 기준(임금등 체불자료 제공일 이전 3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 임금등 체불자료 제공일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 2천만원 이상)을 충족한 체불사업주에 대하여 신용정보집중기관에 체불자료를 제공함으로써 은행 등 금융기관과의 거래에 있어 제한을 받도록 한다. 이는 명단 공개보다 더욱 실질적인 경제적 불이익을 가하여 임금체불을 방지하기 위한 강력한 행정 제재 수단이다.

## Ⅳ. 결론

- 임금지급의 원칙은 통화불, 직접불, 전액불, 정기불의 원칙으로 구성되며, 이는 근로자의 임금채권 보호 및 생존권 확보라는 공익적 목적을 위한 강행규정이다. 각 원칙은 엄격한 준수를 요구하며, 예외는 법령 또는 단체협약에 규정된 경우에 한하여 제한적으로 인정된다. 사용자가 이러한 임금지급 의무를 위반하여 임금 체불을 하는 경우, 형사처벌(징역 또는 벌금) 및 지연이자 지급 의무가 발생한다. 나아가, 상습적인 체불사업주에 대해서는 명단 공개 및 신용제재 등 행정적 제재를 가함으로써 국가적 차원에서 근로자 보호 조치가 이루어진다.

## I. 서설

### 1. 의의[근기법 제46조 제1항]

- 휴업수당은 **근로기준법 제46조 제1항**에 규정된 바와 같이, 사용자의 귀책사유로 인하여 근로자가 휴업하는 경우에 사용자가 해당 근로자에게 지급해야 하는 임금 보전 금액을 말한다. 이는 근로자가 근로 제공 의사와 능력을 갖추고 있음에도 불구하고, 전적으로 사용자 측의 책임으로 근로를 제공하지 못하게 된 기간에 대하여 생계 유지를 위해 지급하는 것이다. 휴업수당은 근로의 대가로서의 임금이 아니라, 법정된 특수한 금품이다.

### 2. 취지

- 휴업수당 제도의 취지는 사용자의 경영 위험을 일부 분담시켜 근로자의 생계를 보장하고, 사용자의 자의적인 휴업을 억제하는 데 있다. 근로자는 사용자 측의 사정으로 근로 제공이 불가능해질 경우에도 최소한의 소득을 확보하여 경제적 어려움에 처하는 것을 방지해야 한다. 따라서, 휴업수당은 근로자 보호 강화를 목적으로 하는 강행규정적 성격을 갖는다.

## II. 요건

### 1. 사용자의 귀책사유가 있을 것

- 휴업수당 지급 의무가 발생하기 위해서는 휴업의 원인이 사용자의 귀책사유에 있어야 한다.

#### (1) 귀책사유의 범위

- 여기서 귀책사유는 민법상 고의나 과실을 포함하는 개념을 넘어선다. **판례**는 사용자의 세력 범위 내에서 발생한 모든 경영 상의 장애를 포함하는 광범위한 개념으로 해석한다. 예를 들어 원자재 부족, 시장 불황, 거래처 부도 등 사용자의 경영 사정 변동으로 인한 휴업 모두가 원칙적으로 사용자의 귀책사유에 해당한다. 다만, 천재지변, 전쟁 등 불가항력적인 사유로 인한 휴업은 귀책사유로 보지 않는다.

#### (2) 불가항력의 판단

- 불가항력으로 인정되기 위해서는 ① 원인 사태가 외부로부터 발생하였을 것, ② 사용자가 최선의 노력을 다했음에도 불구하고 피해를 막을 수 없었을 것이라는 두 가지 요건을 충족해야 한다. **판례**는 사용자에게 귀책사유가 없다는 것에 대하여 엄격하게 판단한다.

### 2. 휴업을 할 것

- 휴업수당 지급 요건으로서의 휴업은 근로자가 근로계약에 따라 근로 제공 의사와 능력을 가지고 있음에도 불구하고, 사용자의 귀책사유로 인하여 근로를 제공하지 못하는 상태를 의미한다.

#### (1) 휴업의 개념

- 여기서 휴업은 사업장 전체의 정지를 요구하는 것이 아니라, 개별 근로자가 근로 제공을 하지 못하는 상태도 포함하는 상대적 휴업의 개념이다. 전면적 휴업뿐만 아니라, 부분적 휴업, 즉 근로시간 단축으로 인한 휴업도 이에 해당한다.

#### (2) 근로자 측의 요건

- 휴업 기간 동안 근로자에게 근로 제공의 의사와 능력이 있어야 한다. 근로자 자신의 질병, 부상 등으로 인해 근로 제공이 불가능한 경우에는 휴업수당 지급 요건을 충족하지 못한다.

## III. 휴업수당액

### 1. 휴업수당의 수준

- **근로기준법 제46조 제1항** 본문은 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다고 규정한다.

#### (1) 산정 기준 및 지급 수준

- 휴업수당 산정의 기준이 되는 임금은 평균임금이다. 지급 수준은 평균임금의 100분의 70이 최소한의 하한선이며, 단체협약 등에서 그 이상을 정할 수 있다.

#### (2) 통상임금과의 관계

- **근로기준법 제46조 제1항** 단서에는 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다고 규정한다.

### 2. 휴업기간 중 임금 일부를 지급받은 경우

- 휴업 기간 동안 사용자가 근로자에게 평균임금의 100분의 70에 미달하는 임금 등을 이미 지급한 경우에는, 그 지급액이 법정 휴업수당액에 미달하는 한도 내에서 차액만을 추가로 지급하면 된다. 예를 들어 사용자가 휴업 기간 동안 평균임금의 100분의 50을 지급했다면, 나머지 100분의 20을 추가로 지급해야 휴업수당 지급 의무를 이행한 것이 된다. 이는 법정 최저 수준을 보장하면서 기존 지급액을 유효하게 처리하기 위함이다.

## IV. 휴업수당의 감액

### 1. 의의[근기법 제46조 제2항]

- **근로기준법 제46조 제2항**은 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우에는 기준에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있다.라고 규정한다. 이 규정은 사용자의 책임 범위를 넘어선 부득이한 사유가 발생하여 사용자에게 과도한 부담을 줄 때, 예외적으로 휴업수당 지급 의무를 완화하기 위한 것이다.

### 2. 감액지급의 요건

- 휴업수당을 감액 지급하기 위한 요건은 엄격하다.

#### (1) 부득이한 사유가 있을 것

- 부득이한 사유를 천재지변이나 그 밖에 불가항력적인 사유로 판단하는 견해가 있으나, 해당 사업 외부의 사정에 기인하여 사용자의 세력 범위 내에서 발생한 사유로 판단하는 것이 타당하다. **판례**는 구체적인 사정을 고려하여 감액지급의 요건 충족 여부를 판단하고 있다.

#### (2) 노동위원회의 승인을 받을 것

- 사용자는 휴업수당 감액 또는 면제를 위해 사전에 노동위원회의 승인을 받아야 한다. 노동위원회는 부득이한 사유의 존재 여부, 근로자 생활 보장 필요성 등을 종합적으로 고려하여 승인 여부와 감액 수준을 결정한다. 이러한 승인 절차는 사용자의 일방적인 권리 남용을 방지하기 위함이다.

### 3. 감액의 정도

- 휴업수당의 감액 정도는 노동위원회가 승인 할 때 정한다. 노동위원회는 사용자의 재정 상태, 휴업의 규모, 기간, 근로자의 생활 정도 등을 고려하여 감액 비율을 결정한다. **판례**는 **근로기준법 제46조 제2항**은 사용자의 휴업지불의무의 예외를 정한 것이고, 그러한 예외의 경우에 휴업지불의 하한이 별도로 정해져 있지 않은 이상 사정에 따라서는 사용자가 휴업지불을 전혀 하지 않는 것도 가능하다고 볼 수 있다라고 판시한다.

## V. 기타 관련 문제

### 1. 부분파업과 휴업수당

- 부분파업은 근로자의 쟁의행위 기간이므로, 원칙적으로 휴업수당 지급 요건인 근로 제공 의사 및 능력이 부정되어 휴업수당 지급 의무가 발생하지 않는다. 파업 기간은 근로자 측의 귀책사유로 인한 근로 제공 정지에 해당한다. 다만, 파업 이후 사용자가 경영 상의 이유로 일부 부서 등에 대하여 정상적인 근로 제공을 수령하지 않고 휴업을 시키는 경우에는, 그 부분에 대해서는 사용자의 귀책사유가 인정되어 휴업수당 지급 의무가 발생할 수 있다.

### 2. 직장폐쇄와 휴업수당

- 직장폐쇄는 사용자의 방어적 쟁의행위로서, 적법한 직장폐쇄 기간 동안에는 근로자의 노무에 대한 사용자의 수령 거부가 적법하게 인정되어 사용자의 귀책사유가 부정된다. 따라서, 적법한 직장폐쇄 기간에는 휴업수당 지급 의무가 발생하지 않는다. 그러나, 직장폐쇄가 방어적 수단으로서의 정당성을 잃고 공격적 수단으로 변질되거나 위법한 직장폐쇄로 판단되는 경우에는, 사용자의 귀책사유가 인정되어 휴업수당 지급 의무가 발생할 수 있다.

### 3. 민법상의 임금지급청구와 휴업수당

- 사용자의 귀책사유로 인한 휴업 시, 근로자는 근로기준법상 휴업수당(평균임금의 70%) 외에도 [민법 제538조 제1항](#)의 채권자 지체 책임 규정에 따라 손해 배상으로서 임금 전액(100%)을 청구할 수 있다. 휴업수당은 법정된 최소한의 보상 수준이므로, 근로자가 실질적인 임금 손실(통상 임금 전액 수준)을 입증하여 민법상 채무불이행 책임을 물어 청구하는 것은 가능하다. 다만, 휴업수당 청구권과 민법상 임금 청구권은 경합관계에 있으므로, 휴업수당 지급액을 초과하는 손해(평균임금 70%를 초과하는 부분)에 대하여만 추가로 청구할 수 있다.

### 4. 중간수입과 휴업수당

- 휴업 기간 동안 근로자가 다른 사업장에 취업하여 임금 등 소득(중간수입)을 얻은 경우, 사용자는 그 중간수입 금액을 휴업수당에서 공제할 수 있다. [근로기준법 제46조](#)의 휴업수당 규정에는 중간수입 공제에 대한 명시적 규정이 없으나, 해고예고수당 규정 등 유사 규정의 취지를 유추 적용하여 인정된다. 다만, 공제 가능한 중간수입 금액은 평균임금의 70%를 초과하는 금액에 한정하여 공제하는 것이 타당하다는 것이 다수설의 입장이다. 즉, 휴업수당액은 공제 후에도 최소한 평균임금의 70% 수준을 보장해야 한다.

## VI. 결론

- 휴업수당은 사용자의 귀책사유로 인한 휴업 시 근로자의 생계를 보장하기 위한 법정 수당으로, 평균임금의 100분의 70 이상을 지급해야 한다. 휴업수당 지급 의무를 감액하거나 면제하려면 부득이한 사유 및 노동위원회의 승인이라는 엄격한 요건이 필수적이다. 휴업수당은 민법상 임금 전액 청구권과는 경합 관계에 있으며, 근로자가 휴업 기간 중 얻은 중간수입은 일정 범위 내에서 공제 가능하다.

## <제03장 임금.제06절 임금채권의 우선변제.01>

### I. 의의[근기법 제38조]

- 임금채권의 우선변제란 **근로기준법 제38조**에 규정된 바와 같이, 사용자의 재산이 파산, 경매 등으로 처분되는 경우, 일반 채권자나 다른 담보물권자에 우선하여 근로자의 임금채권을 변제받을 수 있도록 법률이 특별히 인정한 권리를 말한다. 이는 임금이 근로자 및 그 가족의 생계를 유지하는 기초 수단이라는 사회적 중요성을 고려하여, 사용자의 경영난이나 도산 등의 위험으로부터 근로자의 최소한의 생활 안정을 보호하기 위한 제도이다. 임금채권의 우선변제 범위는 일반 우선변제와 최우선변제로 나뉜다.

### II. 임금채권과 사용자 총재산의 개념

#### 1. 임금채권의 개념

- 임금채권은 근로자가 근로 제공에 대한 대가로 사용자에게 지급을 청구할 수 있는 모든 금전적 채권을 의미한다. **근로기준법상 임금**, **근로자퇴직급여 보장법상 퇴직금**, **재해보상금** 등 근로관계에서 발생하는 모든 법정 금품 채권을 포함한다. 이러한 채권은 사용자의 도산 등으로 인해 미지급될 경우 근로자의 생계에 직접적인 타격을 주므로, 법적으로 특별한 보호가 요구된다.

#### 2. 사용자 총재산의 개념

- 사용자의 총재산이란 임금채권의 우선변제가 실현되는 재산의 범위를 말하며, 원칙적으로 사업주가 소유하는 모든 재산을 포괄한다. 이는 부동산 뿐만 아니라 동산, 채권, 지적재산권 등 사업주의 책임재산이 되는 모든 종류의 재산을 포함한다. 다만, **근로기준법 제38조**에 따른 우선변제는 사용자의 총재산에 대하여 효력이 미치므로, 특정 재산에 대하여 저당권 등의 담보물권이 설정되어 있더라도 이러한 담보물권자에게 우선하여 변제받을 수 있는 특별한 효력을 갖는다.

### III. 최우선변제되는 임금채권

- **근로기준법 제38조 제2항**은 근로자의 생계에 가장 긴요한 최소한의 임금채권에 관하여 사용자의 총재산에 대하여 설정된 담보물권이나 조세 등에 의하여 담보된 채권보다 최우선하여 변제받을 수 있는 권리를 인정한다. 이는 일반 임금채권의 우선변제보다 더욱 강력한 보호를 제공한다.

#### 1. 최종 3개월분의 임금채권

- 퇴직한 근로자의 최종 3개월분 임금은 최우선변제 대상이다. 이는 근로자가 직전까지 가장 절실하게 필요로 하는 생계 유지 자금이라는 점을 고려한 것이다. 여기서 임금은 근로기준법상 모든 임금(기본급, 수당, 상여금 등)을 포함하지만, 퇴직금 등 퇴직 후 발생하는 금품은 제외된다. 3개월분 임금은 퇴직 시점을 기준으로 역산하여 계산된다.

#### 2. 최종 3년간의 퇴직급여채권

- **근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항**에 따른 퇴직금 또는 퇴직연금 중 최종 3년간의 퇴직급여 채권은 최우선변제 대상이다. 퇴직급여는 근로자의 노후 생활 보장 등 장래의 생활 안정을 위해 필수적이므로, 최종 3년간의 부분에 대하여 강력한 보호를 제공한다. 이는 퇴직 시점을 기준으로 역산하여 3년 동안 발생한 퇴직급여 부분을 의미하며, 근속기간이 3년 미만인 경우에는 그 전 기간의 퇴직급여 전액이 된다.

#### 3. 재해보상금

- **근로기준법 제78조 이하**에 따른 재해보상금은 금액의 다과나 발생 시기에 관계없이 전액이 최우선변제 대상이다. 재해보상금은 근로자의 업무상 재해로 인한 피해 보상으로서, 근로자의 생명 및 신체 보호라는 최고의 사회적 목적을 갖는다. 따라서, 요양보상, 휴업보상, 장해보상, 유족보상, 장례비 등 모든 재해보상금은 다른 어떤 채권보다 가장 우선하여 변제받을 수 있다.

### IV. 최우선변제 임금채권과 피담보채권의 관계

#### 1. 문제점

- **근로기준법 제38조 제2항**은 다음 각 호(최종 3개월분의 임금, 재해보상금)의 어느 하나에 해당하는 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권·저당권 또는 **동산·채권 등의 담보에 관한 법률**에 따른 담보권에 따라 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다.고 규정한다. 이때 담보물권이 설정된 특정 재산이 경매 등으로 처분될 경우, 이러한 담보물권의 피담보채권(담보된 채권)과 최우선변제 임금채권 간의 우선순위가 문제된다.

#### 2. 판례

- **판례**는 **근로기준법 제38조 제2항**에 따른 최우선변제 임금채권은 담보물권이 설정된 시점과 관계없이 당해 재산에 대하여 설정된 모든 담보물권의 피담보채권보다 우선하여 변제받을 수 있다고 일관되게 판단한다. 즉, 최종 3개월분 임금 등은 사용자의 총재산 뿐만 아니라, 사용자의 특정 재산에 대하여 이미 설정된 저당권 등의 권리보다도 최우선적인 변제 순위를 갖는다. 이는 임금채권의 사회적 보호 필요성을 민법상 담보물권 우선 원칙보다 상위에 두는 특별법적 규정으로 해석한 것이다.

#### 3. 검토

- **근로기준법 제38조 제2항**은 민법상 채권법 원칙에 대한 특별 우선 규정으로서 근로자 보호의 최후의 보루를 마련한 것이다. 이는 사용자가 사업 개시 이전에 재산을 담보로 대출을 받았더라도, 이후 근로자에게 발생하는 최종 생계형 임금채권이 가장 우선적으로 변제되도록 함으로써, 사용자의 도산 시에도 근로자가 길거리로 내몰리는 것을 방지하는 사회보장적 취지를 갖는다. 따라서, 판례의 태도는 법의 취지에 부합하는 타당한 해석이다. 다만, 최우선변제 권리자로서의 지위를 획득하기 위해서는 해당 임금채권이 법이 정한 범위(최종 3개월분 등)에 속하는지 여부를 엄격히 확인해야 한다.

### V. 결론

- 임금채권의 우선변제는 사용자의 도산 등으로부터 근로자의 생계를 보호하기 위한 제도로, **근로기준법 제38조**에 규정되어 있다. 특히, 최종 3개월분 임금, 최종 3년간의 퇴직급여, 재해보상금은 사용자 총재산 전체에 대하여 저당권 등 다른 담보물권자보다 최우선하여 변제받을 수 있는 강력한 지위를 갖는다. 이러한 최우선변제권은 담보물권 설정 시기와 관계없이 우선 적용되며, 이는 근로자의 생존권 보호라는 공익적 목적을 최우선하는 법의 의지를 반영한다.



## I. 의의

- 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약상의 근로를 제공하는 시간을 의미한다. 근로기준법상 근로시간의 개념을 명확하게 정의하고 있지는 않지만, **판례** 및 행정해석은 근로자가 사용자의 지휘·감독에서 벗어나 자유로운 이용이 보장된 시간을 휴게시간으로 보아 근로시간에서 제외하고, 그 외의 시간을 근로시간으로 본다. 따라서 근로시간은 근로자가 실제로 작업을 수행한 실근로시간뿐만 아니라, 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 놓여 있으면서 근로의 제공을 위해 대기하는 대기시간도 포함한다. 근로시간의 판단 기준은 실질적으로 근로자가 사용자의 지휘·명령으로부터 완전히 해방되어 있는지가 핵심이다. 근로기준법은 근로시간을 법정근로시간(1일 8시간, 1주 40시간)과 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등을 규정하며 근로자의 건강권과 휴식권을 보장하는 것을 목적으로 한다.

## II. 근로시간의 인정범위

- 근로시간으로 인정되는지 여부는 그 시간이 근로계약상 근로를 제공하는 시간인지, 또는 사용자의 지휘·감독 아래 놓여 있는지를 기준으로 판단한다. 근로시간 인정과 관련하여 특히 문제가 되는 것은 휴게시간과 대기시간의 구별이다. 휴게시간은 근로자가 사용자로부터 근로 제공 의무에서 완전히 해방되어 자유로운 이용이 보장되는 시간을 말한다. 휴게시간은 근로자의 건강과 휴식을 보장하기 위해 근로시간 도중에 주어져야 하며, 그 처분에 대해서는 근로자에게 전적인 자유가 보장되어야 한다. 만일 근로자가 휴게시간 중에도 사용자의 지휘·명령에 따라 언제든지 근로를 제공할 의무가 있다면, 이는 휴게시간이 아니라 근로시간에 포함된다. 반면, 대기시간은 근로자가 실제 작업은 하고 있지 않지만, 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어난 것은 아니어서 다음 근로를 위해 사업장 내에서 기다리고 있는 시간을 의미한다. 이는 비록 근로 제공을 위한 준비나 휴식의 형태를 취하고 있더라도, 사용자의 구체적이거나 묵시적인 지휘·감독을 받고 있어 자유로운 이용이 제한되는 경우에 해당한다. 대기시간은 근로시간에 포함되어 임금 및 연장근로수당 산정의 기초가 된다. 근로시간으로 인정되는지 여부는 단순히 명칭이나 근로계약서상의 규정에 구애받지 않고, 근로 내용, 장소, 태양, 근로자의 자유로운 이동 및 이용 가능성 등 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다. 예를 들어, 사용자가 근로자에게 의무적으로 참여를 요구하는 교육 시간이나, 근로를 위해 반드시 필요한 준비·정리 시간 등도 근로시간으로 인정될 수 있다.

## III. 근로시간에 대한 구체적 검토(판례)

- 근로시간 인정 여부에 대한 판단은 특히 감시·단속적 근로에 종사하거나 장시간 대기하는 형태의 직종에서 빈번하게 문제되어 왔으며, 이와 관련하여 대법원 판례들은 실질적인 구속의 정도를 중요한 기준으로 제시한다.

### 1. 아파트 경비원의 야간휴게시간

- 아파트 경비원의 경우, 야간 근로 중 일정 시간을 휴게시간으로 정하고 있지만, 해당 시간이 근로시간에 포함되는지가 자주 쟁점이 된다. **판례**는 아파트 경비원이 야간 휴게시간에 형식적으로 수면이나 휴식을 취할 수 있었다고 하더라도, 도난·화재 등 비상상황 발생에 대비하여 취침이 엄격하게 금지되었거나 사실상의 근무가 계속된 경우, 또는 경비실의 실내 공간이 좁아 자유로운 휴식이 불가능했던 경우에는 해당 시간을 근로시간으로 인정한다. 경비원들이 휴게시간 중에도 순찰, 외부인 및 차량 통제, 전화 응대, 비상 대기 등의 업무를 수시로 수행했거나, 사용자의 지휘·감독 아래 놓여 있어 자유로운 처분이 사실상 불가능했던 점을 근거로 해당 야간 휴게시간은 근로자가 사용자의 지휘·명령으로부터 완전히 벗어나 이용할 수 있었던 시간이라고 볼 수 없어 근로시간에 해당한다고 판단한다. 따라서 이는 대기시간의 성격을 갖는다고 본다.

### 2. 초등학교 숙직경비원의 휴게시간

- 초등학교 숙직경비원의 경우도 일반적인 아파트 경비원과 유사하게 숙직 시간 중 일부를 휴게시간으로 정하는 경우가 많다. 이 경우에도 해당 시간이 근로시간인지 여부는 그 시간이 사용자의 지휘·감독으로부터 벗어나 자유롭게 이용될 수 있었는지에 달려있다. **판례**는 숙직 경비원이 비상사태 발생에 대비하여 지정된 장소에서 수면을 취하는 등 휴식을 취하더라도, 화재나 절도 등 비상사태에 대비할 의무가 상존하고, 초등학교 시설 방호 및 순찰, 전화 응대 등의 업무를 수행할 의무가 계속되므로, 해당 시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있는 휴게시간이 아니라 근로 제공을 위한 대기시간 또는 통상적인 근로시간의 연장으로 본다. 특히 숙직 업무의 내용이 통상적인 주간 근무의 연장선에 있거나, 경비 외의 잡무(예: 청소, 시설 점검)까지 포함하는 경우 근로시간성이 강하게 인정된다. 즉, 근로자가 언제든지 업무에 동원될 가능성이 있다면 이는 대기시간으로 근로시간에 포함된다.

### 3. 버스운전기사의 대기시간

- 버스운전기사의 경우, 운행과 운행 사이의 간격 시간, 즉 소위 대기시간 또는 중간 휴식 시간이 근로시간인지 휴게시간인지가 주요 쟁점이 된다. 운전기사들은 해당 시간에 차량 내에서 휴식을 취하거나 식사를 하는 경우가 많다. **판례**는 버스운전기사가 차량 운행을 전·후하여 가지는 대기시간이 근로시간에 해당하는지 여부를 판단함에 있어, 근로자가 그 시간 동안 사용자로부터의 지휘·감독에서 벗어나 자유로이 이용할 수 있었는지 여부를 기준으로 한다. **대법원**은 해당 대기시간 동안 근로자가 사용자의 지휘·명령 아래 놓여 운행 노선 및 운행 시간표에 구속되고, 배차 간격에 따라 언제든지 다음 운행을 위해 대기해야 하며, 차량을 떠나 자유로운 사적 용무를 볼 수 있는 것이 사실상 어려웠다면 이는 휴게시간이 아닌 근로시간(대기시간)으로 인정된다고 본다. 특히, 대기장소가 지정되어 있고 운행 재개를 위한 준비 상태를 유지해야 하는 등 사실상 업무상 제약이 강하게 따르는 경우, 근로자의 자유로운 이용 가능성이 박탈되었다고 보아 대기시간을 근로시간으로 판단한다. 이는 운전기사의 휴식권 보장과 연장근로수당 지급 의무와 직결되는 중요한 판단이다.

## IV. 결론

- 근로시간의 인정 여부를 판단하는 핵심 기준은 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 종속되어 있는 시간인지, 즉 근로자의 처분 하에 자유로운 이용이 보장된 시간인지의 여부이다. 비록 근로계약서나 취업규칙상 휴게시간으로 명시되었다 하더라도, 실질적으로 사용자의 구속을 받고 다음 근로를 위해 대기하는 시간이었다면 이는 근로시간(대기시간)으로 인정된다. 대기시간을 근로시간으로 인정함으로써 연장·야간근로에 대한 가산임금 지급 의무가 발생하며, 이는 근로자의 권익 보호 및 근로기준법 준수를 위한 중요한 법적 바탕이 된다. 따라서 사용자는 근로계약상의 명칭이 아닌, 근로자가 실제 시간을 어떻게 이용할 수 있었는지를 실질적인 관점에서 근로시간을 관리해야 한다.



## I. 서설

- 근로시간 보호는 근로자의 건강권과 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위한 근로기준법의 핵심적인 규율 영역이다. 헌법상 보장되는 근로자의 기본권 실현을 위해, 근로기준법은 근로시간의 최대 상한을 법정하고 이를 강행규정으로 설정하여, 사용자가 근로자에게 과도한 장시간 근로를 요구하는 것을 방지한다. 이러한 근로시간 규제는 근로자의 노동력 재생산을 보장하고, 여가 시간 및 문화적 생활을 영위할 수 있는 시간의 확보를 목적으로 한다. 따라서 근로기준법상의 근로시간 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약이나 취업규칙은 그 부분에 한하여 무효가 되며, 무효로 된 부분은 법정 기준에 따른다. 또한, 기준 시간을 초과하는 근로(연장·야간·휴일근로)에 대해서는 가산임금을 지급하도록 의무화하여, 장시간 노동에 대한 억제력을 확보한다. 근로시간은 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 있는 모든 시간을 의미하며, 이는 근로시간 보호 규정 적용의 전제가 된다.

## II. 일반근로자의 근로시간 보호

### 1. 기준근로시간

- 기준근로시간은 **근로기준법 제50조**에 따라 1일 8시간, 1주 40시간을 초과할 수 없도록 법으로 정한 근로시간의 최대 한도를 의미한다. 이는 모든 일반 근로자에게 적용되는 근로시간의 최소한의 기준이자 계약상의 상한선이다. 이 기준근로시간을 초과하는 근로는 원칙적으로 연장근로에 해당한다. 연장근로는 당사자 간의 합의를 통해 허용되지만, 그 한도는 1주 12시간을 초과할 수 없다. 따라서 일반 근로자가 근로할 수 있는 총 근로시간은 1주 52시간(40시간 + 12시간)으로 제한되며, 이 12시간을 초과하는 연장근로를 합의하더라도 초과 부분은 무효이다. 이러한 연장근로 한도의 설정은 과거의 장시간 근로 관행을 개선하고 근로자의 건강권을 실질적으로 확보하는 데 핵심적인 역할을 한다. 또한, 연장근로에 대해서는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 하며, 이는 사용자의 연장근로 지시를 억제하는 경제적 수단으로 작용한다.

### 2. 소정근로시간

- 소정근로시간은 법정 기준근로시간(1일 8시간, 1주 40시간)의 범위 내에서 근로자와 사용자가 근로하기로 정한 시간을 의미한다. 이는 근로계약의 본질적인 내용 중 하나이며, 법정근로시간이 근로의 상한을 규정하는 반면, 소정근로시간은 근로자가 실제로 근로해야 할 의무 시간을 규정한다. 만일 근로자와 사용자가 1주 30시간을 소정근로시간으로 정했다면, 이 30시간이 근로계약상의 기준이 된다. 이 30시간을 초과하고 법정근로시간(40시간) 이내인 근로(31시간째 근로)는 소정근로시간을 초과한 근로이므로 통상임금의 100%를 지급해야 하지만, **근로기준법 제56조**에 따른 연장근로 가산수당은 발생하지 않는다. 연장근로 가산수당은 법정 기준근로시간(1주 40시간)을 초과하는 근로에 대해서만 지급되기 때문이다. 따라서 소정근로시간은 근로자의 건강권 보호와 더불어 임금 산정의 중요한 기준이 된다.

## III. 연소근로자 및 여성근로자의 근로시간 보호

### 1. 연소근로자의 근로시간 보호[근기법 제69조, 제51조 제3항, 제51조의2 제6항, 제52조 제1항 제1호]

- 연소근로자는 15세 이상 18세 미만인 근로자를 의미하며, 신체적·정신적 발달 과정에 있는 점을 고려하여 일반 근로자에 비해 강화된 특별 보호를 받는다. **근로기준법 제69조**는 연소근로자의 근로시간을 원칙적으로 1일 7시간, 1주 35시간으로 제한한다. 이는 일반 근로자의 기준보다 1일 1시간, 1주 5시간이 단축된 것이다. 연장근로 역시 당사자 합의가 있더라도 1일 1시간, 1주 5시간을 한도로만 허용된다. 이러한 규제들은 연소근로자의 근로시간 변동성을 최소화하고, 사용자의 자의적인 근로시간 운용으로부터 연소근로자의 건강권과 학습권을 보호하기 위함이다.

#### (1) 2주 이내 탄력적 근로시간제 적용 제외

- **근로기준법 제51조 제3항**은 2주 단위의 탄력적 근로시간제를 연소근로자에게 적용하지 못하도록 명시적으로 금지한다.

#### (2) 선택적 근로시간제 적용 제외

- **근로기준법 제51조의2 제6항**은 선택적 근로시간제 역시 연소근로자에게 적용하지 못하도록 규정한다.

#### (3) 사업장 밖 간주근로시간제 적용 제외

- **근로기준법 제52조 제1항 제1호**는 근로시간 산정이 어려운 사업장 밖 근로에 대하여 근로시간을 간주하는 제도의 적용 대상에서도 연소근로자를 제외한다.

### 2. 18세 이상의 여성근로자의 근로시간 보호

- 18세 이상의 여성근로자는 원칙적으로 **근로기준법 제50조**에 따른 일반 근로자로서 1일 8시간, 1주 40시간의 기준근로시간을 적용받는다. 다만, 임신부(임신 중이거나 출산 후 1년이 지나지 않은 여성)에 대해서는 모성 보호를 위한 특별한 제한이 가해진다.

#### (1) 임신 중 여성근로자의 연장근로 금지

- 임신 중인 여성근로자는 **근로기준법 제74조 제5항**에 따라 기준근로시간 외의 연장근로가 절대적으로 금지된다. 이는 태아의 건강과 모체의 안전을 최우선으로 보호하기 위한 강력한 규정으로, 당사자 간의 합의가 있더라도 허용되지 않는다.

#### (2) 산후 1년 미만 여성근로자의 연장근로 제한

- 출산 후 1년이 지나지 않은 여성근로자는 **근로기준법 제71조**에 따라 원칙적으로 연장근로가 금지되지만, 당사자 간의 합의와 노동부장관의 인가를 받은 경우에만 예외적으로 연장근로가 가능하다. 이 경우에도 연장근로 시간은 1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간을 초과할 수 없도록 엄격히 한정된다.

### 3. 연소근로자와 여성근로자의 야간근로 및 휴일근로의 제한

- 연소근로자와 여성근로자의 야간근로 및 휴일근로는 **근로기준법 제70조**에 의해 원칙적으로 금지된다. 야간근로는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지의 근로를 의미한다. 이러한 규제는 야간 및 휴일 근로가 건강에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고, 특히 연소근로자의 성장과 임신부의 모성을 적극적으로 보호하기 위한 사회 정책적 배려를 담고 있다.

#### (1) 원칙적 금지 대상

- 사용자는 18세 미만 연소근로자와 임신부(임신 중 또는 산후 1년 미만 여성)를 원칙적으로 야간근로 및 휴일근로에 종사시키지 못한다.

#### (2) 예외적 허용 요건 (노동부장관 인가)

##### ① 18세 미만 연소근로자

- 본인의 동의가 있고 노동부장관의 인가를 받은 경우에만 예외적으로 허용된다.

##### ② 임신부

- 명시적인 청구가 있고 노동부장관의 인가를 받은 경우에만 예외적으로 허용된다. 명시적인 청구는 근로자 본인의 자발적인 의사를 확인하기 위한 절차이다.

## IV. 결론

- 근로시간 보호 규정은 근로기준법이 추구하는 근로조건 최저 기준 보장이라는 목표를 실현하는 데 있어 가장 중요한 제도적 장치이다. 일반 근로자의 기준근로시간 규제와 더불어, 연소근로자 및 임신부에게 적용되는 특별 보호 규정은 근로자의 취약성과 보호 필요성을 반영한 것이다. 근로기준법상 근로시간 규정의 철저한 준수는 근로자의 건강권과 휴식권을 실질적으로 확보하고, 나아가 기업의 지속 가능한 발전과 사회 전체의 노동 질서 확립에 기여한다.

## I. 시간외근로의 의의

- 시간외근로(Overtime Work)는 근로기준법상 법정근로시간(1일 8시간, 1주 40시간) 또는 근로계약에서 정한 소정근로시간을 초과하여 행하는 근로를 총칭한다. 근로기준법은 근로자의 건강권과 휴식권을 보호하기 위해 기준근로시간을 설정하고 있으나, 사업장의 운영상 필요에 따라 예외적으로 기준근로시간을 초과하는 근로를 허용하고, 이에 대한 보상(가산임금)을 의무화하고 있다. 시간외근로는 통상 연장근로, 야간근로, 휴일근로로 구분된다. 연장근로는 기준근로시간을 초과하는 근로를 의미하며, 야간근로는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지의 근로를 의미하고, 휴일근로는 법정 또는 약정 휴일에 행하는 근로를 의미한다. 이들 시간외근로는 근로자에게 추가적인 피로를 유발하므로, 근로기준법 제56조에 따라 통상임금 외에 가산된 임금을 지급해야 한다.

## II. 시간외근로수당(가산임금)

### 1. 원칙[근기법 제56조]

- 근로기준법 제56조는 연장근로와 야간근로에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하도록 규정하는 시간외근로수당 지급의 기본 원칙이다. 이는 기준근로시간을 초과하는 근로에 대한 보상을 강화하고, 사용자의 장시간 근로 지시를 억제하는 기능을 수행한다. 이러한 가산임금 지급 의무는 강행규정으로, 당사자의 합의나 취업규칙으로 이를 배제하거나 낮출 수 없다.

### 2. 연장근로와 시간외근로수당

- 연장근로는 1주 12시간을 한도로 근로자와 사용자의 합의에 의해 허용된다. 연장근로에 대해서는 통상임금에 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 한다. 연장근로에 해당하는 시간의 산정은 1일 단위 또는 1주 단위로 이루어지며, 1일 8시간을 초과하거나 1주 40시간을 초과하는 근로시간에 대해 각각 가산임금이 적용된다. 다만, 1주 40시간을 초과하는 연장근로에는 1일 8시간을 초과하는 근로시간이 중복되어 계산될 수 없으며, 중복되는 부분은 1주 연장근로 한도(12시간) 범위 내에서 1회의 가산임금만을 지급한다.

### 3. 야간근로와 시간외근로수당

- 야간근로는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이에 행하는 근로를 의미하며, 이는 근로자의 생체리듬에 악영향을 미치므로, 시간과 관계없이 가산임금 지급 대상이 된다. 야간근로에 대해서는 통상임금에 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 한다. 만약 연장근로 시간 중 야간근로가 이루어지는 경우, 연장근로 가산임금(50%)과 야간근로 가산임금(50%)이 중복되어 통상임금의 100분의 100 이상이 가산된 임금을 지급해야 한다.

### 4. 휴일근로와 시간외근로수당

- 휴일근로는 법정휴일(주휴일, 근로자의 날, 공휴일) 또는 약정휴일에 행하는 근로를 의미한다. 휴일근로에 대해서는 근로기준법 제56조 제2항에 따라 다음과 같이 가산임금을 지급해야 한다.

#### (1) 8시간 이내의 휴일근로

- 통상임금의 100분의 50 이상을 가산한다.

#### (2) 8시간을 초과한 휴일근로

- 통상임금의 100분의 100 이상을 가산한다. 휴일근로가 야간에 이루어진 경우(오후 10시부터 다음 날 오전 6시), 휴일근로 가산임금과 야간근로 가산임금이 중복 적용되어 통상임금 외에 추가로 가산된 임금을 지급해야 한다. 예를 들어, 8시간 이내의 휴일 야간근로는 통상임금의 150% 이상(통상임금 + 휴일 50% + 야간 50%)을 지급해야 한다.

## III. 보상휴가제도

### 1. 의의[근기법 제57조]

- 보상휴가제도는 연장근로, 야간근로, 휴일근로에 대하여 근로기준법 제56조에 따라 가산하여 지급해야 할 임금(시간외근로수당)에 갈음하여 휴가를 부여하는 제도이다. 임금 지급 대신 유급 휴가를 부여함으로써 근로자의 휴식권 보장을 강화함과 동시에, 기업에게는 유연한 인력 운영의 기회를 제공한다.

### 2. 목적

- 보상휴가제도의 주된 목적은 근로자의 연장·야간·휴일근로로 인해 발생하는 피로를 해소하고, 충분한 휴식과 여가를 보장받을 수 있도록 유급 휴가의 형태로 보상하는 것이다. 이는 근로기준법의 근로시간 단축 및 휴식권 보장 강화라는 입법 목적에 부합한다. 또한, 사용자 입장에서는 일시적인 임금 지출 부담을 줄이고 인력 운용의 유연성을 확보할 수 있는 장점이 있다.

### 3. 요건

- 보상휴가제를 도입하기 위해서는 다음 요건을 충족해야 한다.

#### (1) 근로자대표와의 서면 합의

- 사용자는 근로자대표와의 서면 합의를 통해 보상휴가제를 도입할 수 있으며, 이 합의에는 임금 지급에 갈음하여 휴가를 부여한다는 내용과 휴가 부여의 기준 및 절차 등이 포함되어야 한다.

#### (2) 가산임금에 상당하는 휴가 부여

- 부여되는 휴가는 가산임금에 상당하는 시간이 되어야 한다. 즉, 연장근로 1시간에 대해서는 1.5시간(1시간 + 가산 0.5시간)의 휴가를 부여해야 하며, 야간근로 1시간에 대해서도 1.5시간의 휴가를 부여해야 한다. 휴일근로의 경우 8시간 이내에는 1.5배, 8시간 초과 시에는 2배의 휴가를 부여해야 한다.

### 4. 임금의 범위

- 보상휴가제는 시간외근로에 대한 가산임금을 포함한 전부에 갈음하여 휴가를 부여하는 것을 의미한다. 따라서 휴가 부여로 인해 시간외근로수당 지급 의무는 소멸하게 된다. 다만, 근로자대표와의 합의를 통해 임금 중 일부는 지급하고 나머지 가산임금 부분에 대해서만 휴가를 부여할 수도 있다. 만일 보상휴가 부여가 불가능한 경우(예 : 퇴직 등으로 휴가를 사용할 수 없는 경우)에는 사용자는 미사용 휴가에 상응하는 가산임금을 포함한 수당을 지급해야 한다.

## IV. 포괄임금약정

### 1. 의의

- 포괄임금약정이란 근로시간, 연장·야간·휴일근로시간 등이 명확하지 않거나 계산하기 어려운 업무의 특성을 고려하여, 실제 근로시간을 일일이 계산하지 않고 연장·야간·휴일근로에 대한 수당 등을 미리 정한 금액(혹은 기본급에 포함)으로 지급하기로 근로자와 사용자 간에 약정하는 것을 의미한다. 이는 주로 감시·단속적 근로 또는 업무의 특성상 근로시간 측정이 곤란한 경우에 활용되었다.

### 2. 문제점

- 포괄임금약정은 근로자의 실제 근로시간과 무관하게 고정된 임금을 지급함으로써, 근로자가 장시간 근로를 하더라도 정당한 보상을 받지 못할 위험을 내포한다. 또한, 사용자가 근로시간의 통제 의무를 소홀히 하거나 장시간 근로를 유도할 수 있어, 근로기준법의 근로시간 규제 및 가산임금 지급 의무를 회피하는 수단으로 악용될 소지가 있다. 대법원은 이러한 문제점을 인식하고 포괄임금약정의 유효 요건을 엄격하게 제한하고 있다.

### 3. 포괄임금에 포함되는 임금의 범위

- 포괄임금약정의 대상이 되는 임금은 통상 연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당 등 시간외근로수당이다. 이 외에 연차유급휴가 미사용수당이나 퇴직금 등은 근로의 대가라기보다는 법적 의무 이행에 따른 것이므로 포괄임금약정의 대상이 될 수 없다.

#### 4. 포괄임금약정의 성립 여부

- 포괄임금약정은 명시적인 약정이 있는 경우뿐만 아니라, 근로계약서, 취업규칙, 급여명세서 등을 통해 묵시적으로 합의되었다고 인정되는 경우에도 성립할 수 있다. 그러나 약정의 성립 여부와 그 유효성은 별개의 문제이며, 성립이 인정되더라도 엄격한 유효 요건을 갖추지 못하면 무효가 될 수 있다.

#### 5. 포괄임금약정의 유효요건

- 대법원은 포괄임금약정이 유효하기 위해서는 다음 요건을 모두 충족해야 한다고 판시하고 있다.

##### (1) 근로시간 산정이 어려운 경우

- 포괄임금약정은 근로시간 산정이 곤란한 업무에 종사하는 등 업무의 특성상 근로시간 측정이 어려운 경우에만 예외적으로 인정된다. 근로시간 측정이 명확한 경우에는 원칙적으로 포괄임금약정은 유효성이 부정된다.

##### (2) 근로자에게 불이익이 없는 경우

- 약정된 임금액이 근로기준법에 정하는 최저 기준(법정 수당)에 미달하지 않아야 한다. 즉, 실제로 발생할 수당의 합계액보다 포괄된 임금액이 적어서는 안 된다.

##### (3) 근로자 동의의 진정성

- 근로자의 동의가 자발적이고 진정해야 하며, 근로자의 계산 착오나 포기 의사가 명확하게 확인되어야 한다.

#### 6. 포괄임금약정의 효과와 차액정산의무

- 유효 요건을 갖추지 못한 포괄임금약정은 무효이다. 무효인 경우, 사용자는 근로자에게 실제 근로시간에 따른 법정 시간외근로수당과의 차액을 정산하여 지급할 의무를 부담한다. 즉, 포괄임금 형태로 지급된 금액을 공제한 후 부족한 금액을 추가로 지급해야 한다. 포괄임금약정이 유효한 경우에도, 약정 시 예상한 근로시간을 대폭적으로 초과하는 근로가 발생했다면, 그 초과분에 대해서는 약정과는 별도로 추가 수당을 지급해야 한다는 것이 판례의 태도이다.

#### 7. 관련 판례

- 대법원은 포괄임금제 관련 판례를 통해 그 유효성을 더욱 엄격하게 판단하고 있다.

##### (1) 근로시간 산정 곤란 원칙 강조

- 대법원은 근로시간 산정이 비교적 명확한 일반 근로자에게 포괄임금약정을 적용하는 것은 근로기준법의 강행규정을 위반하여 원칙적으로 무효라는 입장을 확립하였다.

##### (2) 실제 근로시간 파악 의무

- 설령 포괄임금약정이 유효하더라도, 사용자는 근로자의 실제 근로시간을 파악하고 기록할 의무가 면제되지 않으며, 근로시간을 알 수 없는 경우에는 근로자가 입증하기 곤란하다는 점을 고려하여 합리적인 근로시간을 인정해야 한다고 판시하였다.

##### (3) 실제 근로시간과 임금의 비교

- 포괄임금약정 유효성 판단 시, 약정 금액이 실제 발생한 법정 수당액에 미달하는지 여부가 핵심 판단 기준이 되며, 미달하는 경우 해당 약정은 근로자에게 불리하여 무효로 본다.

## V. 결론

- 시간외근로에 대한 규제 및 보상 제도는 근로자의 건강권 보호와 공정한 노동의 대가 확보라는 근로기준법의 근본 이념을 실현하는 핵심 기둥이다. 시간외근로수당(가산임금) 지급 의무는 장시간 근로에 대한 억제책이며, 보상휴가제도는 금전적 보상 외에 실질적인 휴식의 기회를 제공한다. 특히 포괄임금약정에 대한 대법원의 엄격한 유효성 판단 기준은 근로시간의 명확한 산정과 이에 따른 정당한 임금 지급이라는 원칙을 강조하며, 근로기준법의 강행규정적 성격을 다시 한번 확인시켜 주고 있다. 따라서 사용자는 포괄임금제도의 도입에 신중해야 하며, 모든 근로자에 대해 실제 근로시간을 정확하게 산정하고 법정 수당을 지급할 의무를 충실히 이행해야 한다.

**I. 서설**

- 휴게시간은 근로기준법이 근로자에게 근로시간 도중에 제공하는 휴식의 시간을 의미하며, 근로자의 건강 유지 및 노동력 재생산을 위한 필수적인 제도이다. 근로시간 규제만으로는 장시간 근로로 인한 피로를 충분히 해소할 수 없으므로, 근로의 계속 도중에 휴식을 취하게 함으로써 노동의 강도를 완화하고 산업 재해를 예방하는 사회정책적 기능을 수행한다. 근로기준법은 휴게시간의 최소 길이를 법정하고, 이를 근로자의 자유이용에 맡김으로써 실질적인 휴식권을 보장하고 있다.

**II. 휴게시간의 의의**

- 휴게시간이란 근로시간 도중에 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어나 근로자가 자유롭게 이용할 수 있는 시간을 말한다. 이는 근로시간과 대립되는 개념으로서, 근로자가 사용자의 지휘·명령으로부터 해방되어 사적인 용무를 보거나 휴식을 취할 수 있어야 한다. 휴게시간은 근로시간 중에 배치되며, 근로시간에 포함되지 않으므로, 원칙적으로 임금이 지급되지 않는 무급 시간이다. 다만, 단체협약이나 취업규칙 등으로 휴게시간에 대해서도 임금을 지급하기로 정할 수는 있다. 만일 근로자가 휴게시간 중에도 사용자의 지휘·감독을 받고 있거나 업무 수행을 위한 대기 상태에 있다면, 그 시간은 실질적인 휴게시간이 아닌 근로시간으로 인정되어 임금(수당)이 지급되어야 한다.

**III. 휴게시간의 내용**

**1. 휴게시간의 길이[근기법 제54조 제1항]**

- 근로기준법 제54조 제1항은 근로시간이 일정 기준을 초과할 경우 사용자에게 휴게시간을 부여할 의무를 부과하고 있으며, 그 최소 길이는 다음과 같다. 이 기준은 최소한의 의무이며, 단체협약이나 취업규칙으로 이보다 긴 휴게시간을 부여할 수는 있다. 법정된 휴게시간을 부여하지 않은 사용자에게는 근로기준법 제110조 제1호에 따라 벌칙이 부과된다.

**(1) 4시간 근로**

- 4시간 근로 시 30분 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.

**(2) 8시간 근로**

- 8시간 근로 시 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.

**2. 휴게시간의 부여방법**

**(1) 근로시간 도중의 부여**

- 휴게시간은 근로시간 도중에 주어져야 한다. 근로의 시작 전이나 종료 후에 부여하는 것은 법이 정한 휴게시간 부여의 목적(계속 근로로 인한 피로 해소)에 반하므로 인정되지 않는다.

**(2) 일제 휴식의 원칙과 예외**

- 휴게시간은 원칙적으로 사업장의 모든 근로자에게 동시에 부여되어야 한다(일제 휴식의 원칙). 다만, 다음의 경우에는 일제 휴식을 적용하지 않을 수 있다.

**① 사업 또는 업무의 성격상 일제 휴식을 줄 수 없는 경우**

- 예컨대, 운수업, 판매업,接客업, 보건업 등 공중의 편의를 도모하는 사업으로서 사업의 정상적인 운영을 위해 근로자 전체가 동시에 쉴 수 없는 경우이다.

**② 근로자대표와의 서면 합의가 있는 경우**

- 근로자대표와의 서면 합의를 통해 일제 휴식의 원칙을 적용하지 않을 수 있다.

**(3) 분할 부여의 가능성**

- 법정된 30분 또는 1시간의 휴게시간을 반드시 연속하여 부여해야 하는지에 대해 근로기준법은 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 통상적으로 휴게시간의 목적(피로 해소)을 해치지 않는 범위 내에서 적절히 분할하여 부여하는 것은 가능하다고 해석된다. 다만, 지나치게 짧은 시간(예 : 5분씩 6회)으로 분할하는 것은 근로자의 자유로운 이용을 저해할 수 있으므로 허용되지 않는다.

**IV. 자유이용의 원칙**

**1. 의의**

- 근로기준법 제54조 제2항은 휴게시간을 근로자가 자유롭게 이용할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 휴게시간이 실질적인 휴식 시간으로서의 기능을 할 수 있도록 보장하는 핵심 원칙이다. 근로자는 이 시간 동안 사용자의 구속이나 지휘·감독으로부터 완전히 벗어나 자유로이 활동할 수 있으며, 사적인 용무, 식사, 수면 등 어떠한 행동을 하든 사용자는 이에 간섭할 수 없다.

**2. 자유이용의 한계**

- 휴게시간 중의 자유이용 원칙은 절대적인 것이 아니며, 사업장의 규율과 질서 유지, 안전 확보 등 합리적인 범위 내에서 제한될 수 있다. 판례는 휴게시간을 자유롭게 이용할 수 있도록 보장해야 하지만, 사업장 내에서 질서유지나 안전을 위한 제한은 허용된다고 보고 있다.

**(1) 사업장 내 질서 유지**

- 사용자는 취업규칙 등을 통해 휴게시간 중에도 사업장 내에서 음주, 도박 등 풍기를 문란하게 하거나 다른 근로자에게 피해를 주는 행위를 금지할 수 있다.

**(2) 시설 관리 및 보안**

- 휴게시간 중 사업장 내 시설 이용에 필요한 최소한의 통제(예 : 시설 출입 통제, 안전 관련 지시)는 정당화될 수 있다.

**(3) 근로의무의 불이행**

- 휴게시간에 근로자가 사업장 밖으로 외출하여 근로의무의 이행에 지장을 초래하거나, 다음 근로시간에 복귀하지 못할 정도로 먼 곳으로 이탈하는 행위 등은 징계사유가 될 수 있다.

**3. 휴게시간 중의 조합활동·정치활동**

- 휴게시간은 근로자의 자유로운 시간 이용이 보장되는 만큼, 이 시간에 이루어지는 노동조합 활동이나 정치 활동 등도 원칙적으로 허용된다. 다만, 이러한 활동이 사업장 내의 질서나 시설 관리에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 사용자가 정당한 범위 내에서 이를 제한할 수 있다. 예를 들어, 소음 등으로 다른 근로자들의 휴식을 방해하거나, 업무 시설을 훼손할 위험이 있는 활동 등은 제한 대상이 될 수 있다.

**V. 적용제외[근기법 제63조]**

- 근로기준법 제54조의 휴게시간 규정은 모든 근로자에게 적용되는 것이 원칙이나, 일부 근로자에 대해서는 적용이 제외된다. 이는 이들 근로자의 업무 특성상 근로시간 규정을 그대로 적용하기가 곤란하거나 부적절하기 때문이다.

#### **1. 토지·건물 등의 관리 업무에 종사하는 근로자**

- 사업의 종류에 관계없이 감시·단속적 근로자로서 고용노동부장관의 승인을 받은 자에 대해서는 휴게시간 규정이 적용되지 않는다.

#### **2. 농업 및 축산물 관련 종사자**

- 농림, 축산, 수산 사업에 종사하는 근로자는 업무 특성상 계절적, 시간적 제약이 크므로 휴게시간 규정이 적용되지 않는다. 다만, 이들에게도 근로시간, 휴일, 휴가 등에 관한 다른 규정은 적용될 수 있으며, 이들 제외 대상자라 할지라도 실질적인 휴식 기회가 보장되어야 한다는 원칙은 유지된다.

#### **V. 결론**

- 휴게시간은 근로자의 건강과 안전을 확보하고, 장시간 근로로 인한 피로를 회복하게 하여 생산성을 유지·향상시키는 중요한 법적 장치이다. 근로기준법은 근로시간에 따른 최소 휴게시간을 의무화하고, 자유이용의 원칙을 통해 실질적인 휴식권을 보장한다. 사용자는 휴게시간의 최소 기준을 준수하고, 근로자가 사용자의 지휘·감독에서 벗어나 온전히 자유롭게 시간을 활용할 수 있도록 보장할 의무가 있다. 이러한 휴식권의 보장은 근로조건의 최저 기준을 정립하고 인간다운 노동 환경을 구축하려는 근로기준법의 목적 달성에 기여한다.

## I. 의의

### 1. 개념

- 휴일이란 근로제공 의무가 원래부터 없는 날로서, 법률 또는 당사자의 약정에 의하여 근로의무가 면제되고 근로자가 근로 제공 없이 휴식을 취하도록 보장된 날을 의미한다. 휴일은 근로자의 건강과 문화생활 향유를 위해 근로시간 도중에 부여되는 휴게시간이나, 근로일로 지정될 수 있으나 근로의무를 면제한 날인 휴무일과는 구별된다.

### 2. 입법취지

- 휴일 제도의 입법취지는 다음과 같다.

#### (1) 노동력의 재생산 및 건강권 보호

- 주 1일 이상의 정기적 휴식을 보장함으로써 근로자의 피로를 회복하고 건강을 유지하여 노동력을 재생산하게 한다.

#### (2) 사회·문화적 생활 보장

- 근로자가 가족과의 관계 유지, 취미 활동 등 사회·문화적 생활을 영위할 기회를 부여함으로써 인간다운 생활을 할 권리를 보장한다.

#### (3) 사회적 공익 실현

- 근로자의 날이나 공휴일 등 법정휴일은 사회적·국가적 공익 목적을 달성하기 위한 기능도 수행한다.

## II. 휴일의 특징 및 유형

### 1. 구별개념

#### (1) 휴무일과의 비교

##### ① 휴일(休日)

- 근로의무 자체가 면제되는 날로서, 주로 근로기준법 제55조에 따른 주휴일, 근로자의 날 제정에 관한 법률에 따른 근로자의 날, 유급으로 보장되는 공휴일 등이 해당된다. 유급이 원칙이나, 약정휴일의 경우 무급일 수도 있다.

##### ② 휴무일(休務日)

- 근로의무는 있으나 근로일로 정하지 않은 날(주 5일제 사업장의 토요일)을 의미하며, 근로일이 아니므로 원칙적으로 무급이다.

#### (2) 휴가와와의 비교

##### ① 휴일

- 법령 또는 약정에 의해 모든 근로자에게 일률적으로 부여되는 근로의무의 면제일이다.

##### ② 휴가(休暇)

- 근로자가 신청 등의 절차를 거쳐 근로의무를 면제받는 날(연차 유급휴가, 출산휴가)로서, 근로의무가 발생함을 전제로 한다는 점에서 휴일과 구별된다.

### 2. 휴일의 유형

#### (1) 법정휴일

- 법률에 의해 의무적으로 부여해야 하는 휴일이다.

##### ① 주휴일

- 근로기준법 제55조 제1항에 의해 1주일에 평균 1회 이상, 유급으로 부여하는 휴일이다.

##### ② 근로자의 날

- 근로자의 날 제정에 관한 법률에 따라 유급휴일로 부여된다.

##### ③ 공휴일(관공서의 공휴일에 관한 규정)

- 2022년 1월 1일부터 모든 사업장(상시 5인 이상)에 대해 유급휴일로 적용이 확대되었다.

#### (2) 약정휴일

- 법정휴일 외에 단체협약이나 취업규칙 등 당사자 간의 약정에 의해 부여되는 휴일이다. (회사 창립기념일)

## III. 주휴제의 원칙

### 1. 의의

- 주휴제란 근로기준법 제55조 제1항에 따라 사용자가 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일을 근로자에게 주어야 하는 제도를 말한다. 이는 근로일이 계속될 경우 발생하는 근로자의 피로를 풀어주고 노동력을 회복시켜 생산성을 유지하기 위한 것이다. 주휴일은 통상 일요일로 정하는 것이 일반적이거나, 특정 요일로 지정하지 않아도 무방하며, 반드시 특정되어야 하는 것은 아니다.

### 2. 휴일 부여 대상자

- 주휴일은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 근로자에게 부여되어야 한다. 여기서 소정근로일이란 법정근로시간 범위 내에서 노사 간에 근로하기로 정한 날을 의미하며, 개근은 근로일에 결근하지 않았음을 의미한다.

### 3. 1주 1회 이상의 유급휴일을 가질 수 있는 자

- 주휴일은 근로자가 1주 동안의 소정근로시간 전부를 근로했는지 여부와는 무관하게, 소정근로일을 개근하였다면 발생한다. 따라서 1주 소정근로시간이 40시간 미만인 단시간 근로자라도 소정근로일을 모두 개근했다면, 그 근로시간에 비례하여 유급 주휴일을 부여받을 권리가 있다.

### 4. 1주 평균 1회 이상의 휴일

- 근로기준법은 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 규정하고 있는데, 이는 반드시 일정한 요일에 고정될 필요는 없으며, 7일의 기간을 단위로 하여 최소한 1회의 유급휴일이 확보되도록 운영되어야 함을 의미한다.

### 5. 쟁의행위기간 중 유급휴일에 대한 임금청구권

- 근로자가 적법한 쟁의행위(파업 등)에 참여하는 기간은 근로 제공 의무가 정지되는 기간이며, 이는 소정근로일의 근로를 제공하지 않은 것으로 간주된다. 따라서 쟁의행위로 인해 소정근로일을 개근하지 못한 경우에는 원칙적으로 그 기간 동안의 주휴일에 대한 임금청구권은 발생하지 않는다고 해석하는 것이 일반적이다.

## IV. 휴일근로와 임금[근기법 제56조]

- 휴일근로란 법정휴일 또는 약정휴일에 근로를 제공하는 것을 의미하며, 이는 근로자에게 특별한 피로와 휴식권 침해를 가져오므로, 통상임금 외에 가산임금을 지급해야 한다.

### 1. 8시간 이내의 휴일근로

- 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다(총 150% 이상).

## 2. 8시간을 초과한 휴일근로

- 8시간을 초과하는 근로시간에 대해서는 통상임금의 100분의 100 이상을 가산하여 지급한다(총 200% 이상).

## 3. 휴일 야간근로

- 휴일근로가 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 야간에 이루어진 경우, 휴일근로 가산임금에 야간근로 가산임금 50%가 중복되어 적용된다. 예를 들어 8시간 이내의 휴일 야간근로 시에는 통상임금의 150%에 야간 50%를 더한 총 200% 이상을 지급해야 한다.

## V. 휴일의 대체

### 1. 의의

- 휴일의 대체란 근로기준법 제55조 제2항 단서에 따라 특정 휴일을 다른 근로일과 맞바꾸어 당초의 휴일을 통상의 근로일로 하고 그 대신 다른 날을 휴일로 부여하는 제도이다. 이는 사업 운영상 불가피하게 휴일에 근로가 필요한 경우, 근로자에게 휴식권을 보장하면서도 기업의 업무 연속성을 확보하기 위한 제도이다.

### 2. 요건

- 휴일의 대체가 유효하기 위해서는 다음 요건을 충족해야 한다.

#### (1) 취업규칙 등의 규정

- 휴일대체에 관한 사항이 취업규칙 또는 단체협약에 명시적으로 규정되어 있어야 한다.

#### (2) 근로자대표와의 합의

- 법에는 명시되어 있지 않으나, 판례는 취업규칙에 근거하여 이루어지는 휴일대체는 근로자에게 불리하지 않은 범위에서 가능하다고 본다. 다만, 휴일근로가 빈번할 경우 근로자대표와의 서면 합의를 요구하는 경우가 많다.

#### (3) 사전 통보

- 대체할 휴일을 특정하여 최소 24시간 전에 근로자에게 고지하여 근로자가 휴식을 준비할 수 있도록 해야 한다.

### 3. 효과

- 휴일 대체의 효과는 다음과 같다.

#### (1) 휴일의 성격 상실

- 당초의 휴일은 통상의 근로일이 되므로, 그날 근로를 하더라도 휴일근로에 따른 가산임금(150% 또는 200%)은 발생하지 않는다. 단지 통상임금만 지급하면 된다.

#### (2) 새로운 휴일의 발생

- 대체된 근로일이 법정 유급휴일의 효력을 갖게 된다.

#### (3) 휴일근로수당 지급 의무 면제

- 휴일의 대체를 통해 사용자는 휴일근로수당을 지급할 의무를 면하게 되며, 이는 휴일근로에 대한 가산임금 지급을 대체휴가로 갈음하는 근로기준법 제57조의 보상 휴가제와는 구별된다.

## VI. 결론

- 휴일 및 휴일근로 제도는 근로자의 건강권과 휴식권을 보호하는 근로기준법의 기본적인 제도이며, 주휴일 부여 및 휴일근로에 대한 가산임금 지급은 사용자의 강행적인 의무이다. 특히, 휴일근로에 대한 가산임금은 장시간 근로를 억제하고 근로의 대가를 공정하게 보상하는 수단으로서 기능한다. 휴일대체 제도는 기업 운영의 유연성을 확보함과 동시에 근로자의 휴식권을 보장하기 위한 예외적 수단이므로, 사용자는 법적 요건을 엄격히 준수하여 제도를 운용하여야 한다.



**I. 연차유급휴가의 의의**

**1. 법규정[근기법 제60조]**

- 근로기준법 제60조는 근로자가 일정한 출근율을 충족하거나 계속근로연수가 1년 미만인 경우 법 규정에 의한 유급휴가를 부여받을 권리를 정하고 있다. 이는 근로자의 생리적·문화적 휴식권을 보장하고 노동력의 재생산을 도모하기 위한 강행규정이다.

**2. 취지**

- 연차유급휴가는 근로자에게 장기간의 근로에 따른 피로를 회복하고, 인간다운 생활을 유지하며, 사회적·문화적 활동을 할 기회를 보장하여 노동력을 유지·향상시키는 데 그 취지가 있다. 또한, 근로자로 하여금 휴가를 자유롭게 이용할 수 있게 하여 삶의 질 향상에 기여한다.

**3. 정의**

- 연차유급휴가란 1년간의 소정근로일을 개근하거나 일정 비율 이상 출근한 근로자에게 다음 해에 유급으로 사용할 수 있도록 주어지는 휴가 일수를 의미하며, 이는 근로기준법상 근로자의 권리로 규정된다.

**II. 연차유급휴가권의 법적 성질**

- 연차유급휴가권의 법적 성질에 대해서는 그 발생 시점과 소멸 시점에 따라 학설이 나뉘며, 이는 휴가 사용 시기와 미사용 수당 청구권 발생 시점에 중요한 영향을 미친다.

**1. 학설**

**(1) 형성권설(통설 및 판례의 입장)**

- 휴가청구권은 근로자가 일정 기간의 근로를 완료함으로써 그 이행기에 도달하였을 때 비로소 발생하는 권리라고 본다. 휴가 발생 연도에 근로관계가 종료되더라도, 휴가 사용 기간이 남아있다면 미사용분에 대한 수당 청구권이 발생한다.

**(2) 채권적 성격설**

- 휴가는 전년도 근로의 대가로서 조건부 채권의 성격을 가진다고 보며, 출근율 충족 시점에 권리가 발생하고, 휴가 사용 기간이 시작되는 시점에 확정된다고 본다.

**2. 검토**

- 형성권설이 다수설 및 판례의 확고한 입장이다. 판례는 연차휴가청구권은 1년간 80퍼센트 이상 출근이라는 요건이 충족됨으로써 비로소 발생하는 것이며, 휴가를 사용할 수 있는 시기가 된 때(다음 해)에 그 권리를 행사할 수 있다고 본다. 따라서 1년간의 근로를 마친 다음 날 근로관계가 종료되더라도 이미 연차휴가청구권이 발생하였으므로, 근로자는 미사용 휴가일수에 상응하는 수당을 청구할 수 있다.

**III. 연차유급휴가의 성립요건**

**1. 1년간 80% 이상 출근[근기법 제60조 제1항]**

- 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. 여기서의 1년은 원칙적으로 근로자의 입사일을 기준으로 산정하며(개별 근로자 기준), 노사가 정한 회계연도를 기준으로 할 수도 있다(회계연도 기준).

**2. 계속근로연수가 1년 미만인 근로자에 대하여는 1개월간 개근 시[근기법 제60조 제2항]**

- 계속근로기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년이 되었으나 출근율 80% 미만인 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여해야 한다. 이 휴가는 1년의 근로기간이 끝나기 전까지 사용하여야 하며, 이 휴가를 이미 사용한 경우라도 제1항에 따른 연차휴가일수(15일)에서 공제하지 않는다.

**3. 출근율 산정에 관한 판례의 태도**

- 출근율 산정 시 제외되어야 하는 기간(출근으로 보아야 하는 기간)에 대하여 판례는 다음과 같은 태도를 취한다.

**(1) 업무상 부상 또는 질병으로 휴업한 기간**

- 근로기준법 제60조 제6항에 따라 업무상 부상 또는 질병으로 휴업한 기간은 출근한 것으로 간주된다.

**(2) 출산전후휴가 및 육아휴직 기간**

**① 출산전후휴가 기간**

- 이 기간은 근로기준법 제60조 제6항에 따라 출근한 것으로 간주된다.

**② 육아휴직 기간**

- 육아휴직 기간은 근로제공 의무가 정지되는 기간으로, 소정근로일수 산정에서 제외된다(휴직 기간만큼 총 소정근로일수를 줄여 출근율을 산정).

**(3) 징계, 불법 파업 등으로 인한 정직·결근 기간**

- 이 기간은 근로자에게 책임 있는 사유로 근로를 제공하지 않은 것이므로, 결근으로 처리되어 출근율 산정 시 불이익을 받는다.

**4. 구체적 예시**

**(1) 출근일수에 포함하는 경우 → ⊕ / ○ (분자에 산입)**

- 업무상 재해(질병)로 휴업한 기간, 출산전후휴직기간, 육아휴직기간[근기법 제60조 제6항]
- 부당해고로 근로자가 출근하지 못한 기간(판례)
- 사용자의 위법한 직장폐쇄로 출근하지 못한 기간

**(2) 출근일수에서 제외하는 경우 → ⊖ / ○ (분자에서 제외)**

- 위법한 징의행위 기간(판례)
- 정직, 직위해제 기간(판례)

**(3) 소정근로일수, 출근일수에서 제외하는 경우 → ⊖ / ⊖ (분자, 분모에서 제외)**

- 적법한 징의행위로 근로를 제공하지 않은 기간(판례)
- 적법한 직장폐쇄로 근로를 제공하지 않은 기간(판례)
- 근로의무가 면제된 노조전임기간

**IV. 비례적 삭감설의 법리**

**1. 의의**

- 비례적 삭감설이란 1년간의 소정근로일 전부를 근무하지 못한 경우, 연차휴가일수를 소정근로일수 대비 실제 근로일수의 비율에 따라 비례적으로 삭감하여 부여해야 한다는 법리이다.

**2. 비례적 삭감설을 따른 사례**

- 출근율의 요건이 충족된 경우의 연차휴가일수에 대하여 **종래 판례**는 본래 정상적인 근로관계에서 8할의 출근율을 충족할 경우 산출되었을 연차유급휴가 일수에 대하여 연간 소정근로일수에서 쟁의행위 등 기간이 차지하는 일수를 제외한 나머지 일수를 연간 소정근로일수로 나눈 비율을 곱하여 산출된 연차유급 휴가일수를 근로자에게 부여함이 합리적이라 할 것이라고 판시하였다.

### 3. 비례적 삭감설을 제한한 사례

- **최근 판례**는 연차휴가제도의 취지, 연차휴가가 가지는 1년의 근로에 대한 대가로서의 성질, 연간 소정근로일수에서 제외하지 않고 결근으로 처리할 때 인정되는 연차휴가일수와의 불균형 등을 고려하면, 해당 근로자의 출근일수가 연간 소정근로일수의 8할을 밑도는 경우에 한하여, 본래 정상적인 근로관계에서 8할의 출근율을 충족할 경우 산출되었을 연차휴가일수에 대하여 실질 소정근로일수를 연간 소정근로일수로 나눈 비율을 곱하여 산출된 연차휴가일수를 근로자에게 부여함이 합리적이라고 판시하여, 비례삭감설의 입장을 다소 제한하는 법리를 제시하였다. 즉, 해당 근로자의 출근일수가 연간 소정근로일수의 8할 이상이면 법률에서 정한 연차휴가일수 전부를 부여하고, 8할에 미치지 못하면 이를 비례적으로 삭감하여 부여하는 방식이다.

## V. 연차유급휴가의 내용

### 1. 휴가일수[근기법 제60조 제4항]

#### (1) 기본 일수

- 1년간 80% 이상 출근 시 15일의 유급휴가를 부여한다.

#### (2) 가산 일수

- 계속근로연수가 3년 이상인 근로자에게는 15일에 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 2년마다 1일의 유급휴가를 가산한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다. (예 : 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25...)

### 2. 연차유급휴가수당[근기법 제60조 제5항, 근기법 시행령 제33조]

#### (1) 지급 사유

- 근로자가 발생한 연차유급휴가를 1년의 사용 기간 동안 사용하지 못하고 소멸하였을 때, 그 미사용 일수에 대해 사용자에게 지급 의무가 발생하는 금전 보상을 연차유급휴가미사용수당이라고 한다.

#### (2) 산정 기준

- 휴가 미사용 시 지급해야 할 수당은 휴가 미사용 근로일에 대해 통상임금 또는 평균임금 중 취업규칙 등으로 정한 바에 따라 지급한다. 통상적으로는 통상임금으로 산정하는 것이 일반적이다.

### 3. 휴가부여시기[근기법 제60조 제5항 단서]

#### (1) 휴가 사용의 원칙

- 휴가 발생일로부터 1년간 근로자가 청구한 시기에 주어야 한다.

#### (2) 사용자의 시기변경권

- 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 사용자는 그 시기를 변경할 수 있다.

### 4. 연차유급휴가의 분할사용 및 사용용도

#### (1) 분할사용

- 연차유급휴가는 근로자가 원하는 경우 1일 단위가 아닌 반일(半日) 단위 또는 시간(時間) 단위로 분할하여 사용할 수 있도록 해야 한다. 다만, 시간 단위 사용은 노사 간의 합의를 거쳐야 한다.

#### (2) 사용용도

- 근로자는 휴가를 자유롭게 이용할 수 있으며, 사용자는 그 용도에 대해 관여하거나 제한할 수 없다.

## VI. 연차유급휴가의 소멸

### 1. 연차유급휴가의 소멸[근기법 제60조 제7항]

- 연차유급휴가는 1년간 행사하지 않으면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다. 여기서 1년은 휴가 발생일(휴가 사용 기간의 시점)로부터 1년을 의미한다.

### 2. 연차유급휴가미사용수당

- 휴가가 1년의 사용 기간 만료로 소멸될 경우, 근로자는 미사용 일수에 상응하는 연차유급휴가미사용수당을 사용자에게 청구할 권리가 있다. 이 수당 청구권은 휴가가 소멸된 다음 날 발생하며, 3년간 행사하지 않으면 시효로 소멸한다.

## VI. 연차유급휴가의 사용촉진

### 1. 법규정[근기법 제61조]

- 사용자는 근로자의 휴가 사용을 촉진하기 위하여 일정한 절차와 방법으로 조치를 취할 수 있으며, 이러한 조치에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 않아 소멸된 경우, 그 미사용 휴가에 대한 보상 의무를 면제받는다.

### 2. 취지

- 연차유급휴가 사용 촉진 제도는 근로자의 휴가 사용을 장려하고 휴가 미사용에 따른 사용자 측의 금전 보상 부담을 완화하며, 근로자의 휴식권을 실질적으로 보장하기 위함에 그 취지가 있다.

### 3. 방법

- 사용촉진 제도는 최소 2회에 걸쳐 문서로 근로자에게 통보하여야 한다.

#### (1) 1차 촉진

- 휴가 사용 기간 만료 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 남은 휴가 일수를 통보하고, 근로자에게 사용 시기를 지정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구해야 한다.

#### (2) 2차 촉진

- 1차 촉진에도 불구하고 근로자가 사용 시기를 지정하지 않은 경우, 휴가 사용 기간 만료 2개월 전까지 사용자가 미사용 휴가에 대한 사용 시기를 지정하여 근로자에게 서면으로 통보해야 한다.

### 4. 효과

- 사용자가 위 3.의 방법을 포함하여 **근로기준법 제61조**에 따른 모든 사용 촉진 조치를 이행하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 않아 휴가가 소멸된 경우, 사용자는 그 미사용 휴가에 대한 보상 의무(연차유급휴가미사용수당 지급 의무)를 면제받는다.

### 5. 사용촉진 제도를 배제한 단체협약의 효력

- 근로기준법 제61조는 사용자의 보상 의무 면제 요건을 규정한 임의규정으로 해석되므로, 단체협약 등으로 사용촉진 제도를 배제하고 미사용 휴가에 대해 무조건 수당을 지급하도록 규정하는 것은 가능하다. 이러한 단체협약은 근로기준법에 비해 근로자에게 유리하므로 유효하다.

#### 6. 휴가미사용과 보상의무 유무

- 사용자가 적법한 사용 촉진 조치를 취하지 않았거나, 촉진 조치를 취했으나 근로자의 퇴직 등으로 인해 휴가가 소멸된 경우 등 근로기준법 제61조의 요건을 충족하지 못한 경우에는 사용자는 미사용 휴가에 대한 보상 의무를 부담해야 한다.

### Ⅵ. 연차유급휴가의 대체[근기법 제62조]

- 연차유급휴가의 대체란 근로자대표와의 서면 합의에 따라 법정 연차유급휴가 일수를 갈음하여 특정 근로일을 휴가일로 대체할 수 있는 제도이다.

#### 1. 요건

- 근로자대표와의 서면 합의가 있어야 한다.

#### 2. 효과

- 휴가 일수를 갈음하여 특정 근로일을 휴가일로 정할 경우, 그 날은 근로 의무가 면제되며, 연차휴가 일수가 그만큼 소진된 것으로 본다. 이 경우 근로기준법 제60조에 따른 연차유급휴가를 부여한 것으로 간주되므로, 사용자는 별도의 미사용 수당 지급 의무를 지지 않는다.

### Ⅶ. 결론

- 연차유급휴가 제도는 근로자의 삶의 질 향상과 노동력 보전을 위한 핵심적인 권리이다. 근로자는 1년의 근로를 통해 법정된 휴가를 취득하며, 사용자는 원칙적으로 근로자가 청구한 시기에 이를 부여해야 한다. 특히 연차유급휴가의 사용 촉진 제도는 휴식권 보장과 사용자 부담 완화의 균형을 맞추기 위한 중요한 제도이며, 그 적법한 이행 여부에 따라 미사용 휴가에 대한 사용자의 보상 의무가 결정되므로 법정 절차를 준수하는 것이 중요하다.

## I. 서설

- 취업규칙은 근로기준법이 정하는 근로조건에 최저 기준을 준수하면서, 당해 사업장의 특성에 맞게 구체적인 근로조건과 복무 규율을 통일적으로 규정한 자치 규범이다. 이는 단체협약과 근로계약을 연결하는 중간 단계의 규율로서, 특히 근로자 수가 많은 사업장에서 근로관계를 획일적이고 효율적으로 관리하기 위한 필수적인 법적 도구이다. 취업규칙의 존재는 근로자와 사용자 간의 법률관계를 명확히 하고, 사업장의 질서 유지와 안정적인 경영을 도모하는 중요한 역할을 수행한다. 근로기준법은 일정 규모 이상의 사업장에 대하여 취업규칙의 작성 및 신고 의무를 부과하고 있으며, 이를 위반할 경우 벌칙을 규정함으로써 취업규칙의 공적인 성격을 부여하고 있다.

## II. 취업규칙의 의의

### 1. 개념

- 취업규칙은 **근로기준법 제93조**에 따라 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자가 작성하여 고용노동부 장관에게 신고해야 하는 규정이다. 이 규칙은 사업과 종업 시간, 휴게시간, 휴일, 휴가, 임금의 결정·계산·지급 방법 등 사업장에서 근로자가 지켜야 할 복무 규율과 근로자의 근로조건 전반에 관한 구체적인 기준을 정한다. 취업규칙은 사업장 전체 근로자에게 적용되는 통일적인 규범으로서, 근로자의 개별 근로계약 내용을 일률적으로 규제하는 기능을 가진다.

### 2. 법적 성질

- 취업규칙의 법적 성질에 대해서는 규범설과 계약설이 주요 학설로 대립한다. 계약설은 취업규칙을 근로계약 내용의 일부로 보고, 근로자 집단의 집단적 합의 또는 묵시적인 승인에 의해 효력이 발생한다고 본다. 반면, 규범설은 취업규칙을 사업장 내에서 근로자 집단을 규율하는 법규범 또는 자치법규로 보아, 근로자의 명시적인 동의 없이도 효력을 가진다고 주장한다. **판례**는 취업규칙이 법규범적 성격을 가진다는 입장에 가깝다. 취업규칙은 단순히 근로계약의 내용을 이루는 것을 넘어, 법령 또는 단체협약에 저촉되지 않는 범위 내에서 근로조건을 결정하는 규범으로서의 성격을 가지며, 따라서 근로자들의 동의가 없더라도 취업규칙의 내용이 근로자에게 적용될 수 있다고 해석한다. 다만, 근로자에게 불리하게 변경될 경우에는 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다는 **근로기준법 제94조**의 규정은 취업규칙의 규범적 성격과 근로자 보호의 요청이 조화된 결과로 이해한다. 이처럼 취업규칙은 사업장 내의 집단적인 근로조건을 규율하는 특수한 자치 규범적 성질을 가진다.

## III. 취업규칙의 작성

### 1. 작성·신고의 의무[근기법 제93조]

- 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 **근로기준법 제93조**에서 정한 사항에 관하여 취업규칙을 작성하고 고용노동부 장관에게 신고해야 한다. 여기서 상시 근로자 10명이란 일시적으로 10명을 초과하는 것이 아니라, 일정한 기간 동안 평균적으로 10명 이상의 근로자를 계속적으로 사용하는 상태를 의미한다. 취업규칙의 신고는 그 효력 발생 요건이 아니라, 취업규칙의 법적 강제력을 확보하고 행정 감독을 용이하게 하기 위한 행정상의 의무이다. 사용자가 취업규칙을 작성 또는 변경하였을 때에는 지체 없이 신고해야 하며, 신고 시에는 근로자 과반수의 의견을 들었음을 증명하는 서류(의견서 또는 동의서)를 첨부해야 한다. 이 의무를 위반하여 취업규칙을 작성·신고하지 않거나 허위 신고한 경우에는 **근로기준법**에 따라 벌칙이 부과된다.

### 2. 복수의 취업규칙 작성 가능 여부[근기법 시행령 제9조 제1항 및 (별표 2) 제5호 가목]

- 취업규칙은 원칙적으로 하나의 사업장 전체에 통일적으로 적용되는 것이 바람직하다. 그러나 사업장이 장소적으로 분산되어 있거나, 하나의 사업장 내에 여러 직종이 존재하여 직종별 특성상 등으로 인하여 근로조건을 획일적으로 정하는 것이 불합리한 경우에는 예외적으로 복수의 취업규칙을 작성할 수 있다. **근로기준법 시행령**은 사업 또는 사업장 전체에 적용되는 하나의 취업규칙으로 규율하기 곤란한 경우로서, 지리적으로 분산되어 있는 사업장의 일부에만 적용되는 규칙을 작성하는 경우 또는 직종·직무의 특성상 그 일부 근로자에게만 적용되는 규칙을 작성하는 경우 등을 복수 규칙 작성이 가능한 사례로 규정하고 있다. 복수의 취업규칙을 작성하는 경우에도 각 규칙은 해당 근로자 집단의 근로조건을 규율하는 데 있어 통일성과 합리성을 갖추어야 하며, 복수 규칙 간 근로조건에 차이가 합리적인 이유 없이 발생해서는 안 된다.

## IV. 취업규칙의 기재사항

### 1. 필요적 기재사항과 임의적 기재사항

- 취업규칙의 기재사항은 **근로기준법 제93조**에서 정하는 필요적 기재사항과 사용자가 필요에 따라 정하는 임의적 기재사항으로 구분된다. 필요적 기재사항은 근로자의 근로조건과 밀접하게 관련된 14가지 항목으로서, 사업 및 종업 시간, 휴게시간, 휴일, 휴가에 관한 사항, 임금의 결정·계산·지급 방법 등에 관한 사항, 퇴직에 관한 사항, 표창과 제재에 관한 사항 등이 포함된다. 이러한 사항들은 근로조건의 핵심적인 내용을 구성하므로, 사용자는 취업규칙에 반드시 이 사항들을 구체적으로 명시해야 한다. 임의적 기재사항은 **제93조**에 규정되지 않았더라도 사용자가 사업장 운영의 필요에 따라 설정하는 사항으로, 기숙사 규칙, 안전 보건 등에 관한 세부적인 사항 등이 이에 해당한다.

### 2. 필요적 기재사항이 미비된 경우

- 취업규칙의 일부 내용이 법에서 요구하는 필요적 기재사항을 누락하거나 미비한 경우, 그 취업규칙 전체의 효력에 영향을 미치는지에 대한 문제가 발생한다. 전부 무효설은 일부 미비라도 취업규칙 작성의무 위반으로 보아 전체의 효력이 없다고 주장하나, 이는 법적 안정성을 해칠 우려가 있다. **판례**는 부분 무효설 또는 보충설의 입장을 취한다. 즉, 취업규칙의 일부 조항이 필요적 기재사항을 미비했거나, 법령 또는 단체협약에 위반되어 무효인 경우에도, 그 부분만을 무효로 하고 나머지 부분은 유효하다고 해석한다. 미비된 사항에 대해서는 법령이나 단체협약의 내용, 또는 해당 사업장의 관행 등을 통해 보충적으로 적용될 수 있으며, 취업규칙 자체가 근로조건의 기준을 제시하는 법규범적 성격을 가지므로, 사소한 기재 미비를 이유로 전체의 효력을 부정하기는 어렵다. 다만, 미비된 사항이 근로조건의 핵심적인 내용을 이루는 경우에는 그 미비된 사항을 둘러싼 분쟁이 발생할 여지가 커지므로, 사용자는 필요적 기재사항을 완전하게 갖추어 취업규칙을 작성해야 할 의무를 성실히 이행해야 한다.

## V. 결론

- 취업규칙은 사업장의 질서 유지와 통일적인 근로조건 기준 확립을 위한 자치 규범으로서 중요한 위치를 차지한다. 사용자는 상시 10명 이상의 근로자를 사용할 때 취업규칙의 작성 및 신고 의무를 성실히 이행해야 하며, 이때 **근로기준법 제93조**에서 정한 필요적 기재사항을 누락 없이 포함해야 한다. 또한, 취업규칙의 작성 및 변경 시 근로자 과반수의 의견을 듣거나 동의를 얻는 절차를 준수해야 하며, 법령 또는 단체협약에 반하는 내용을 정할 수 없다는 점에서 엄격한 법적 제약을 받는다. 취업규칙이 근로자와 사용자 간의 안정적인 근로관계를 유지하는 핵심적인 규율이 될 수 있도록, 법적 요건의 충족과 내용의 합리성을 확보하는 것이 중요하다.

## I. 서설

- 취업규칙은 사업장의 자치 규범으로서 근로조건을 획일적으로 규율하지만, 사업 환경이나 경영 상황의 변화에 따라 그 내용을 변경할 필요성이 발생한다. 근로기준법은 취업규칙의 변경이 근로조건에 미치는 중대한 영향을 고려하여, 변경의 내용이 근로자에게 불이익한지 여부에 따라 그 절차적 요건을 엄격하게 구분하여 규정한다. 이는 근로자의 기득권을 보호하고, 사용자에게 일방적인 근로조건 저하를 방지하도록 함으로써 근로자 보호의 요청과 사용자 경영권의 조화를 도모하는 데 그 취지가 있다.

## II. 불이익하지 아니한 취업규칙의 변경

### 1. 의견청취[근기법 제94조 제1항 본문]

- 취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익하지 아니하는 경우에는 사용자는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수를 대표하는 자)의 의견을 들어야 한다. 여기서 의견을 듣는다는 것은 사용자에게 근로자의 의견을 청취하고 이를 존중할 의무를 부과하는 것이지, 근로자 측의 동의를 얻으 필요까지는 없다는 의미이다. 즉, 사용자는 근로자 측이 제시한 의견에 구애받지 않고 자신의 판단에 따라 취업규칙을 변경할 수 있다. 변경 내용이 근로자에게 불이익하지 않으므로, 근로자의 보호 필요성이 낮다고 판단하기 때문이다.

### 2. 의견청취절차 위반의 효력

- 근로기준법 제94조 제1항 본문은 불이익하지 아니한 변경의 경우에도 의견청취 절차를 거치도록 의무화한다. 만약 사용자가 이러한 의견청취 절차를 거치지 않고 취업규칙을 변경한 경우, 그 변경된 취업규칙의 효력에 대해서는 견해가 대립한다. 판례는 근로자에게 불이익하지 않은 변경에 있어서 의견청취는 절차적 요건에 불과하며, 의견청취 절차를 거치지 않았더라도 그 변경된 취업규칙의 사법적 효력에는 영향이 없다고 본다. 다만, 의견청취 의무를 위반한 사용자에게 대해서는 근로기준법 위반에 따른 행정상의 제재(과태료 등)가 부과될 수 있다. 즉, 의견청취는 행정법상 의무이지 취업규칙 변경의 효력 요건은 아니라고 해석한다.

## III. 불이익한 취업규칙의 변경

### 1. 원칙[근기법 제94조 제1항 단서]

- 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 사용자는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 받아야 한다. 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수의 동의를 받아야 한다. 이는 근로조건의 불이익한 변경에 대해 근로자의 집단적 의사를 반영하여 근로자의 기득권을 보호하기 위한 강행규정이다. 만약 취업규칙이 근로자에게 불이익하게 변경되었음에도 불구하고 적법한 동의를 얻지 못했다면, 그 변경은 원칙적으로 효력이 발생하지 않는다.

### 2. 불이익 변경

- 취업규칙의 불이익 변경 여부는 원칙적으로 근로조건의 저하를 가져오는지 여부를 기준으로 판단한다. 구체적인 판단 기준은 다음과 같다.

#### (1) 불이익 변경의 판단 기준

- 불이익 변경 여부는 변경 전후의 취업규칙 내용을 개별 근로자에게 유리한지 불리한지의 관점에서 객관적·합리적으로 평가하여야 한다. 이때 단순히 일부 근로자에게 유리한 부분이 있더라도, 대다수 근로자에게 불리한 영향을 미치는 경우에는 불이익 변경으로 본다. 특히 임금이나 퇴직금 등 근로자에게 중요한 권리나 경제적 이익에 관한 사항이 축소되거나, 근로자의 의무가 가중되는 경우 명백한 불이익 변경으로 취급된다.

#### (2) 사회통념상 합리성에 대한 판례의 태도 변화

- 종전 판례는 취업규칙의 불이익 변경에 대하여 원칙적으로 근로자 과반수의 동의를 요구하면서도, 예외적으로 사회통념상 합리성이 인정되는 경우에는 동의를 받지 않았더라도 그 효력을 인정할 수 있다고 본다. 고 보았으나, 최근 판례는 헌법 제32조 제3항, 근로기준법 제4조, 제94조 제1항의 취지와 관계에 비추어 보면, 취업규칙의 불리한 변경에 대하여 근로자가 가지는 집단적 동의권은 사용자의 일방적 취업규칙의 변경 권한에 한계를 설정하고 헌법 제32조 제3항의 취지와 근로기준법 제4조가 정한 근로조건의 노사대등결정 원칙을 실현하는 데에 중요한 의미를 갖는 절차적 권리로서, 변경되는 취업규칙의 내용이 갖는 타당성이나 합리성으로 대체될 수 있는 것이라고 볼 수 없다. 하여 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 그 유효성을 인정할 수는 없다는 입장이다. (대법원 2023.5.11. 2017다35588, 35595[전합])

### 3. 동의의 주체

- 취업규칙의 불이익 변경에 대한 동의 주체는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합이 되며, 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수이다. 여기서 근로자 과반수란 취업규칙의 적용을 받는 근로자 집단 전체를 기준으로 산정한다. 동의 주체는 근로조건의 통일적 규율이라는 취업규칙의 성격상 해당 사업장 또는 취업규칙이 적용되는 근로자 집단 전체의 의사를 대표하는 주체여야 한다.

### 4. 동의의 방법

- 동의는 근로자집단의 회의 방식에 의한 집단적 의사결정에 따라 이루어져야 한다. 근로자들의 개별적인 동의를 얻는 방식은 집단적 의사결정 방식이 아니므로 원칙적으로 유효한 동의로 인정되지 않는다. 회의 방식에 의한 동의란, 근로자들이 모여 변경안에 대해 충분히 논의하고 찬반투표 등의 민주적인 절차를 거쳐 과반수의 의사로 결정하는 것을 의미한다. 이 과정에서 사용자의 부당한 간섭이나 강요가 있어서는 안 되며, 근로자들에게 변경 내용의 취지와 효과 등에 대해 충분히 설명하여 이해를 구해야 한다.

### 5. 동의를 받지 못한 불이익 변경의 효력

- 근로자에게 불이익한 취업규칙 변경에 대해 적법한 동의를 얻지 못한 경우, 그 변경은 무효이다. 따라서 변경된 취업규칙은 해당 근로자에게 적용되지 않으며, 근로관계는 종전의 취업규칙의 내용을 따르게 된다. 다만, 변경된 취업규칙의 적용에 동의한 근로자에 대해서는 개별 근로계약 체결의 효력으로서 변경된 내용이 적용될 수 있다.

### 6. 관련 논점

#### (1) 기득권이 없는 근로자에 대한 변경의 효력

- 취업규칙이 불이익하게 변경될 당시 입사하여 기존의 취업규칙에 따른 기득권이 없는 신규 근로자에 대해서는, 변경된 취업규칙이 당연히 적용된다. 이들은 변경된 취업규칙을 전제로 근로계약을 체결한 것으로 볼 수 있기 때문이다. 그러나 이는 기존 근로자의 기득권을 보호하는 규정의 취지를 훼손하지 않는 범위 내에서 허용된다.

#### (2) 근로자 일부에게 불이익한 경우의 동의 주체

- 취업규칙의 변경 내용이 적용 대상 근로자 중 일부에게만 불이익한 경우, 원칙적으로 그 불이익을 받는 근로자 집단 전체의 과반수 동의를 얻어야 한다. 다만, 불이익을 받는 근로자 집단이 매우 광범위하거나 불분명한 경우에는 취업규칙의 적용을 받는 근로자 전체의 과반수 동의를 얻어야 한다.

## IV. 고용노동부장관에게의 신고 및 심사·주지의무

### 1. 고용노동부장관에게의 신고[근기법 제93조, 제94조 제2항]

- 사용자는 취업규칙을 작성하거나 변경할 때, 이를 지체 없이 고용노동부 장관에게 신고해야 한다. 변경의 경우에도 신고 의무는 동일하며, 특히 불이익 변경 시에는 근로자 측의 동의를 얻었음을 증명하는 서류(동의서)를 첨부해야 한다. 신고는 취업규칙 변경의 효력 발생 요건이 아니며, 행정 감독상의 의무이다.

## 2. 취업규칙의 심사[근기법 제96조 제2항]

- 고용노동부 장관은 신고된 취업규칙의 내용이 법령이나 단체협약에 위반되는 경우, 시정 명령을 할 수 있다. 이 규정은 취업규칙이 강행 법규나 자치 규범인 단체협약보다 하위 규범으로서의 지위를 가지며, 상위 규범에 위반될 수 없음을 확인한다. 사용자가 시정 명령을 받은 후에도 이를 이행하지 않으면 벌칙이 부과된다.

## 3. 취업규칙의 주지의무[근기법 제14조 제1항]

- 사용자는 취업규칙을 작성하거나 변경할 경우, 이를 해당 사업장의 근로자들이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 비치하여 근로자에게 널리 알려야 할 주지의무를 부담한다. 주지의무를 이행하지 않은 취업규칙은 근로자에게 적용되지 않으며, 변경된 내용 역시 효력이 발생하지 않는다고 보는 것이 판례의 태도이다. 즉, 주지는 취업규칙의 효력 발생 요건이다.

## V. 취업규칙상 징계권의 규제[근기법 제95조]

- 취업규칙에서 근로자에 대한 감금(임금 삭감)의 징계를 규정하는 경우, 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을 초과하지 못하며, 총액이 1임금지급기에 있어서 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다. 이는 사용자의 징계권 행사에 제한을 가하여 근로자의 생계 유지에 필요한 최소한의 임금 수준을 보호하기 위한 강행규정이다. 만약 취업규칙의 감금 규정이 이 한도를 초과하는 경우, 그 초과하는 부분에 한하여 무효가 되며, 사용자는 초과 감액분에 대한 임금 지급 의무를 부담한다.

## VI. 취업규칙의 효력

### 1. 신설 또는 변경된 취업규칙의 효력발생요건

- 신설되거나 변경된 취업규칙이 법적 효력을 갖기 위해서는 두 가지 요건을 모두 충족해야 한다. ❶ 법령 및 단체협약에 위반되지 않아야 한다. ❷ 근로자에게 주지(周知)되어야 한다. 특히 불이익 변경의 경우에는 추가적으로 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다. 이 요건들이 충족된 취업규칙은 사업장 내 근로관계를 규율하는 자치 규범으로서 효력을 발생한다.

### 2. 단체협약과의 관계[근기법 제96조 제1항]

- 취업규칙은 단체협약에 저촉될 수 없다. 즉, 취업규칙은 단체협약보다 하위 규범으로서의 지위를 가지며, 단체협약에 위반되는 취업규칙의 부분은 무효가 된다. 이 경우 무효로 된 부분은 단체협약에서 정한 기준에 따른다. 이는 노동조합이 체결한 단체협약의 규범적 효력을 보장하여 근로자에게 유리한 근로조건을 확보하려는 취지다.

### 3. 근로계약과의 관계[근기법 제97조]

- 근로계약에서 정한 근로조건이 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 경우에는 그 미달하는 부분은 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에서 정한 기준에 따른다. 이는 취업규칙이 근로조건을 최저 기준을 정하는 기능을 수행하며, 근로계약이 취업규칙보다 불리한 내용을 정할 수 없도록 강제함으로써 개별 근로자의 근로조건을 보호하기 위한 것이다. 반대로 근로계약이 취업규칙보다 근로자에게 유리한 근로조건을 정한 경우에는 그 근로계약의 내용은 유효하다.

## VI. 결론

- 취업규칙의 변경은 근로자에게 불이익 여부에 따라 의견청취 또는 동의라는 절차적 요건이 엄격히 적용된다. 특히, 불이익 변경 시에는 근로자 과반수의 집단적 동의가 필수적이며, 동의 없는 변경은 원칙적으로 무효다. 취업규칙은 법령 및 단체협약에 위반될 수 없으며, 근로계약보다 하회하는 근로조건을 정할 수 없다는 점에서 근로자 보호의 기능을 수행한다. 또한, 사용자는 취업규칙의 작성·변경 시 신고 및 주지의무를 성실히 이행해야만 법적 효력을 확보할 수 있다.



## I. 의의

- 인사처분이란 사용자가 근로자에 대하여 근로계약상 제공할 노무의 종류, 장소, 형태 등을 변경시키거나 근로관계를 일시적 또는 최종적으로 종료시키는 일체의 법률행위를 의미한다. 이러한 인사처분 중 인사이동은 근로관계를 유지하면서 근로자의 지위나 근로 제공의 장소 및 내용에 변화를 가져오는 행위로서, 배치전환, 전보, 휴직, 대기발령, 전직, 파견 등이 이에 해당한다. 인사이동은 근로계약의 구체적인 이행을 결정하는 사용자의 경영 활동에 속하며, 조직의 효율성을 증대하고 근로자의 적재적소 배치를 통해 기업 경쟁력을 확보하기 위한 핵심적인 수단으로 기능한다. 그러나 이는 근로자의 직업 생활과 사생활에 직접적인 영향을 미치므로, 법적 정당성 판단에 있어서 엄격한 기준이 요구된다.

## II. 인사권의 법적 근거

### 1. 학설

- 인사권의 법적 근거에 관하여는 전통적으로 세 가지 학설이 대립하고 있다.

#### (1) 계약설

- 인사권은 사용자가 근로계약의 체결을 통해 근로자로부터 부여받은 권한이라는 입장이다. 근로계약을 체결할 때 근로자는 장래의 인사이동에 대한 포괄적인 동의를 하였다고 해석하며, 사용자의 인사이동 명령은 이러한 계약상 권한의 구체적인 행사로 본다. 이 학설은 인사이동의 근거를 사적 자치의 원칙에 둔다.

#### (2) 경영권설(규범설)(판례)

- 인사권은 근로계약의 존부와 무관하게 사용자가 기업의 유지 및 발전을 위해 가지는 고유하고 본질적인 경영 주체로서의 권한이라는 입장이다. 근로계약은 단지 근로자가 조직에 편입되는 계기가 될 뿐이며, 인사이동의 근거는 사용자의 지휘권 및 명령권에 있다는 데 중점을 둔다.

#### (3) 절충설

- 인사권은 근로계약에 내포된 포괄적 동의와 사용자의 경영권에서 비롯된 조직 운영의 필요성이 복합적으로 작용한 결과로 이해하는 입장이다. 이는 근로계약의 테두리 안에서 경영상의 필요에 의해 행사되는 권한으로 보며, 가장 현실적인 접근 방식으로 평가된다.

### 2. 판례

- 우리나라 판례는 대체로 경영권설을 바탕으로 하되, 근로자 보호를 위해 권리남용 금지 원칙을 통해 그 행사를 제한하는 태도를 취한다.

#### (1) 인사권의 인정

- 판례는 인사권은 사용자의 고유 권한에 속하므로, 업무상 필요한 범위 내에서는 근로자에 대하여 상당한 재량을 가진다고 하여 사용자의 인사권을 폭넓게 인정한다. 특히 직무의 내용과 장소에 관하여 근로계약에서 구체적으로 한정하지 않은 경우, 사용자는 인사권을 자유롭게 행사할 수 있다고 본다.

#### (2) 인사권 행사의 제한(정당성 판단 기준)

- 다만, 이러한 인사권의 행사가 정당성을 확보하기 위해서는 ① 업무상 필요성이 있어야 하고, ② 인사이동으로 인해 근로자가 입게 될 생활상의 불이익이 통상 근로자가 감수할 정도를 현저하게 벗어나지 않아야 하며, ③ 근로자와의 협의 등 신의성실의 절차를 거쳤는지 여부를 종합적으로 고려해야 한다고 판시한다. 이 세 가지 요소를 비교형량(비례의 원칙)하여 업무상 필요성이 근로자의 불이익을 압도하거나, 불이익이 최소화되었을 경우에만 정당성을 인정한다.

### 3. 검토

- 인사권의 법적 근거에 대한 판례의 태도(경영권 인정 및 제한)는 타당하다. 현대 기업 경영에서 조직의 효율성 확보는 사용자의 필수적인 권한이지만, 근로자의 직업 생활 안정성 또한 헌법상 보장되는 권리이다. 따라서 사용자의 인사권 행사는 경영상의 합리성을 갖추어야 함과 동시에 근로자의 근로조건과 생활에 대한 배려를 포함해야 한다. 특히 인사이동 명령이 근로자의 동의를 얻지 않은 불이익 변경의 성격을 띠는 경우, 판례가 제시하는 업무상 필요성, 생활상 불이익, 협의 절차라는 3단계 기준에 따라 엄격하게 정당성이 심사되어야 한다.

## III. 인사이동의 주요형태

### 1. 기업 내 인사이동

#### (1) 전직(배치전환)

- 전직(배치전환)은 근로자의 직종 또는 직무 내용에 본질적인 변화를 가져오는 인사이동을 의미한다. 근로계약 체결 시 예정되었던 업무와 전혀 다른 업무를 담당하게 하는 것이 대표적이며, 근로자의 기술이나 경력 활용에 큰 영향을 미치므로 광범위한 인사권 행사로 간주된다. 정당성 판단 기준은 앞서 언급된 판례의 태도를 따르며, 특히 직무 내용이 크게 달라지는 만큼 근로자의 동의 유무와 협의 절차가 중요하게 고려된다.

#### (2) 전보

- 전보는 근로자의 근무 장소 또는 소속 부서를 변경하는 것을 의미하나, 직무 내용의 본질적인 변화를 수반하지 않는 경우가 일반적이다. 예를 들어, 동일 직무를 수행하면서 근무 장소만 서울에서 부산으로 바뀌는 경우이다. 직무 내용의 변화가 크지 않으므로 전직보다는 인사권 행사의 재량 범위가 넓다고 해석된다. 다만, 장거리 전보 등으로 인해 근로자의 주거 생활이나 통근에 현저한 불이익이 발생할 경우에는 역시 권리남용이 될 수 있다.

#### (3) 휴직

- 휴직은 근로자가 사용자 또는 근로자 개인의 사정으로 일정 기간 동안 근로 제공 의무를 면제받는 인사처분이다. 이 기간 동안 근로계약 관계는 유지되지만, 노무 제공 의무와 임금 지급 의무는 정지된다. 휴직의 종류와 요건은 주로 취업규칙이나 단체협약에 의해 정해지며, 법정 휴직(예 : 육아휴직)의 경우 근로기준법 및 관련 법령에 의해 그 요건과 기간이 강제된다.

#### (4) 직위해제(대기발령)

- 직위해제(대기발령)는 근로자에게 일정한 직위를 부여하지 않고 근로 제공 의무를 일시적으로 정지시키는 잠정적인 인사조치이다. 이는 주로 근로자의 능력 부족, 징계 회부, 형사 사건 기소 등 조사가 필요한 경우에 이루어지며, 장래의 본 인사처분(징계 등)을 위한 준비 단계로서의 성격이 강하다. 직위해제(대기발령)가 징계는 아니지만, 근로자에게 사실상의 불이익을 주므로 정당성 판단에 있어서도 일반적인 인사이동과 마찬가지로 업무상 필요성과 생활상 불이익을 비교형량하여 정당성을 심사해야 한다.

### 2. 기업 간 인사이동

#### (1) 근로자 파견

- 근로자 파견은 파견사업주가 근로자를 고용한 후, 근로계약 관계를 유지하면서 사용사업주의 사업장에서 지휘·명령을 받아 근로에 종사하게 하는 것을 의미한다. 파견은 고용주와 사용주가 분리되는 특수한 근로형태이며, 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 의해 파견 대상 업무, 기간 등이 엄격하게 규제된다.

#### (2) 전직

- 전직은 근로자가 기존 사용자와의 근로계약을 합의 해지하고, 새로운 사용자와 근로계약을 체결하여 근로관계를 이전하는 것을 의미한다. 이는 근로계약의 주체가 변경되는 것으로서, 근로자의 근로계약상 상대방을 변경하는 행위이므로 근로자의 개별적이고 명시적인 동의가 반드시 필요하다. 동의를 얻지 못한 전직 명령은 무효이며, 회사가 일방적으로 전직을 강요하는 경우 해고 또는 부당 인사이동으로 해석될 수 있다.



### 3. 사용자의 인사권 제한

- 사용자의 인사권은 다음의 법적 근거에 의해 제한된다.

#### (1) 근로기준법 및 개별 특별법상의 제한

- 근로기준법은 부당 해고의 제한 외에도, 출산휴가나 육아휴직 후 원직 또는 동등한 수준의 업무로 복귀시켜야 할 의무, **남녀고용평등과 일·가정 양립**

**지원에 관한 법률**상 성차별에 기한 배치 금지 등을 통해 인사권을 제한한다.

#### (2) 취업규칙 및 단체협약상의 제한

- 취업규칙이나 단체협약에서 인사이동의 종류, 절차, 요건 등에 대하여 명시적으로 제한 규정을 두고 있는 경우, 사용자는 그 규정에 따라 인사이동을 시행해야 한다. 특히 인사이동 시 근로자대표와의 협의나 동의를 거치도록 규정된 경우에는 이를 위반한 인사이동은 절차적 정당성을 상실하여 무효가 될 수 있다.

#### (3) 권리남용 금지 원칙

- 민법상의 권리남용 금지 원칙은 인사권 행사에도 적용되어, 위에서 언급한 정당성 판단 기준(업무상 필요성 vs. 생활상 불이익)에 미치지 못하는 인사이동은 권리남용으로 보아 그 효력을 부인한다. 이는 인사이동이 보복, 괴롭힘, 또는 근로자에게 퇴직을 강요할 목적으로 이루어지는 등의 자의적인 경우에 주로 적용된다.

## IV. 결론

- 인사이동은 기업의 효율적인 운영을 위한 사용자의 중요한 경영권 행사이지만, 근로자의 직업 생활에 미치는 영향이 지대하므로 법적 규제와 통제를 받는다. 전직, 전보 등 기업 내 인사이동은 업무상 필요성과 생활상 불이익을 비교형량하여 권리남용 여부를 판단하는 판례 법리에 따라 정당성이 확보되어야 한다. 특히 기업 간 인사이동인 전직과 같이 근로계약의 주체가 변경되는 경우에는 근로자의 개별적 동의가 필수적이다. 사용자는 취업규칙이나 단체협약상의 절차적 제한을 준수하고, 인사이동 명령이 근로자의 정당한 기대와 근로 조건의 본질을 침해하지 않도록 할 책임이 있다.

**I. 의의**

- 전직(배치전환)이란 동일한 사용자 내에서 근로자의 직무내용이나 근무지에 변경을 가져오는 인사명령을 의미한다. 이는 사용자의 인사권 행사로서, 기업의 합리적 경영을 위해 필요한 인사 배치의 한 형태이다.

**II. 전직명령의 법적 근거**

**1. 견해의 대립**

- 전직명령의 법적 근거에 대하여는 크게 계약설과 인사권설이 대립하고 있다.

**(1) 계약설**

**① 내용**

- 근로계약 체결 시 근로자가 자신의 직무나 근무지 변경에 동의하였을 때 비로소 전직의 근거가 발생한다고 본다. 근로계약상 직무내용 또는 근무지가 특정되었다면, 근로자의 개별적 동의가 없는 한 전직은 허용되지 않는다.

**② 근거**

- 근로계약의 구속력을 중시하는 견해이다.

**(2) 인사권설**

**① 내용**

- 전직은 기업의 경영 목적 달성 및 인력 운용의 효율성을 위한 사용자의 고유한 인사권에 속하는 사항이므로, 근로계약이나 단체협약 등에 특별한 제한이 없는 한 사용자가 재량으로 할 수 있다고 본다.

**② 근거**

- 사용자의 경영권을 중시하는 견해이다.

**2. 검토**

- 판례는 인사권설의 입장을 취하면서도, 사용자의 전직명령권이 무제한적으로 허용되는 것이 아니라 합리적인 범위 내에서만 인정된다는 제한된 인사권설의 태도를 보이고 있다. 전직명령은 업무상 필요성이 있고, 전직에 따른 근로자의 생활상 불이익이 통상 감수할 수 있는 정도이거나, 불이익이 있더라도 업무상 필요성과 비교하여 근로자가 감수해야 할 정도를 넘지 않는 경우에 한하여 정당성이 인정된다고 본다.

**III. 전직의 제한**

**1. 직무내용·근무지의 약정이 없는 경우**

**(1) 개념**

- 근로계약이나 취업규칙, 단체협약 등에서 근로자의 직무내용이나 근무지에 대하여 구체적인 약정이 없는 경우를 말한다.

**(2) 제한**

- 사용자는 인사권에 기초하여 근로자를 전직시킬 수 있지만, 이 역시 업무상 필요성과 생활상 불이익을 비교 형량하여 재량권의 한계를 준수해야 한다.

**2. 직무내용·근무지의 약정이 있는 경우**

**(1) 개념**

- 근로계약이나 취업규칙, 단체협약 등을 통해 근로자의 직무내용이나 근무지가 특정된 경우를 말한다.

**(2) 제한**

**① 원칙**

- 특정된 직무 또는 근무지에 대한 근로자의 개별적인 동의 없이 전직을 명할 수 없다.

**② 예외**

- 다만, 단체협약이나 취업규칙 등에 포괄적 동의 조항이 있는 경우, 해당 조항에 따라 전직이 가능하며, 이 경우에도 전직명령의 정당성 유무는 위 II. 2.의 검토에서 제시된 판례의 기준에 따라 판단하게 된다.

**IV. 부당전직의 효과**

**1. 부당전직에 대한 구제[근기법 제28조 제1항]**

**(1) 개념**

- 사용자의 전직명령이 재량권을 일탈 또는 남용하여 정당성을 인정받지 못하는 경우를 의미한다.

**(2) 구제 절차**

- 근로자는 부당전직에 대해 근로기준법 제28조 제1항에 따라 그 효력이 발생한 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제신청을 할 수 있다.

**(3) 구제 내용**

- 노동위원회는 부당전직으로 판정할 경우 사용자에게 원직복직 등의 구제명령을 내릴 수 있다.

**2. 부당전직과 징계**

**(1) 징계의 문제**

- 부당전직 명령에 대해 근로자가 이를 거부하였다는 이유로 사용자가 근로자를 징계하는 경우, 이 징계는 정당한 업무명령 거부가 아니므로 그 징계 처분은 무효로 판단된다.

**(2) 근거**

- 정당성을 상실한 전직명령은 효력이 없으므로, 근로자는 이를 따를 의무가 없다. 따라서 그 불이행을 이유로 한 징계는 징계사유의 부존재로 인해 부당하다.

**3. 관련 판례**

- 판례는 전직명령의 정당성 판단 시 전직의 업무상 필요성, 근로자의 생활상 불이익, 근로자 본인과 합의 등 신의칙상 요구되는 절차의 이행 여부 등을 종합적으로 고려한다. 특히, 근로자가 전직을 거부할 만한 합리적인 이유가 있는 경우에는 업무상 필요성이 크더라도 부당하다고 판단할 수 있다.

**V. 결론**

- 전직은 사용자의 인사권에 속하는 사항이나, 이는 무제한적으로 허용되는 것이 아니라 근로기준법 및 판례가 제시하는 정당성 기준, 즉 업무상 필요성, 생활상 불이익과의 비교 형량, 신의칙상 절차 등을 준수하는 범위 내에서만 허용된다. 부당한 전직에 대해서 근로자는 노동위원회를 통한 구제절차를 이용할 수 있다.

## I. 의의

- 전직이란 근로자가 원래의 사용자(구 사용자)와의 근로계약 관계를 종료하고, 새로운 사용자(신 사용자)와 새로운 근로계약 관계를 설정하는 것을 의미한다. 이는 동일한 기업 내에서 직무나 근무지만 바뀌는 전직과 달리, 근로계약의 주체(사용자)가 변경되는 것이 핵심적인 특징이다. 전직은 일반적으로 기업 집단 내 계열사 간 인력 이동이나 사업 부문의 양도 등에 수반하여 이루어진다. 전직은 근로자에게 고용 주체의 변경 및 근로조건의 변화라는 중대한 영향을 미치므로, 법적 규율이 엄격하게 적용된다.

## II. 전직명령의 유효요건

- 전직은 근로계약 관계의 주체인 사용자의 변경을 수반하는 법률행위이므로, 단순한 인사명령을 넘어 근로자의 동의가 필수적으로 요구되며, 통상 3자간의 계약의 형태를 취한다.

### 1. 전직계약

#### (1) 개념

- 전직은 구 사용자와의 근로계약의 합의해지와 신 사용자(전직 대상 회사)와의 근로계약 신규 체결이 결합된 복합적인 법률행위이다. 따라서 전직이 유효하게 성립하기 위해서는 구 사용자, 신 사용자, 근로자 등 최소 3자 간의 합의 또는 계약이 필요하다.

#### (2) 법적 성격

- 전직은 근로관계의 중단과 개시를 동시에 포함하므로, 계약의 자유 원칙에 따라 당사자들의 의사가 전적으로 존중된다. 전직계약에서는 퇴직금 지급, 근무시간 승계, 연차휴가 처리 등 구체적인 근로조건과 관련하여 당사자 간의 명확한 합의가 있어야 한다. 특히, 근로자에게 불리한 근로조건 변경은 그에 상응하는 합의를 요한다.

### 2. 근로자의 동의

#### (1) 원칙

- 전직은 근로자의 고용 주체를 바꾸는 행위로서, 근로자에게 신분상, 재산상, 생활상 중대한 영향을 미치기 때문에, 원칙적으로 근로자의 개별적이고 명시적인 동의가 있어야 유효하다. 근로자의 동의가 없는 전직명령은 무효이다.

#### (2) 포괄적 동의의 유효성

##### ① 단체협약 또는 취업규칙의 규정

- 단체협약이나 취업규칙에 전직에 관한 포괄적 동의 조항이 규정되어 있는 경우, 근로자가 이에 대해 포괄적으로 동의하였다고 볼 수 있는지 여부가 문제된다.

##### ② 판례의 태도

- 판례는 단체협약이나 취업규칙에 포괄적 동의 조항이 있더라도, 그러한 규정만으로 근로자의 개별적인 동의 없이 전직을 명할 수 있다고 단정할 수 없다고 본다.

##### ③ 유효성 인정 요건

- 다만, 예외적으로 포괄적 동의 조항이 유효하기 위해서는 해당 조항이 근로자에게 불리하지 않고 그 적용에 합리성이 있는 경우에 한하며, 개별 전직 시에도 전직의 업무상 필요성 및 근로자 이익과의 비교 형량을 통해 정당성을 갖추어야 한다. 즉, 단체협약 등의 포괄적 동의는 전직의 정당성 판단 시 고려되는 하나의 요소일 뿐, 개별적 동의를 완전히 대체할 수는 없다고 본다.

## III. 전직명령의 정당성

- 설령 근로자의 개별적 동의 또는 포괄적 동의를 얻었더라도, 사용자의 전직명령권은 무제한적으로 허용될 수 없으며, 재량권 일탈·남용 금지의 법리에 따라 객관적인 정당성이 인정되어야 유효하다.

### 1. 업무상 필요성

#### (1) 의의

- 전직을 명할 합리적이고 상당한 수준의 업무상 필요성이 있어야 한다. 이는 기업의 경영 합리화, 계열사 간 인력 운영 효율 증대, 특정 사업 부문의 양도 등 광범위한 사유를 포함할 수 있다.

#### (2) 판단 기준

- 업무상 필요성은 구체적인 전직 상황과 당시의 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단되어야 한다. 단순한 사적 이익이나 보복성 인사는 업무상 필요성을 인정받을 수 없다.

### 2. 근로조건의 불이익 정도

#### (1) 의의

- 전직으로 인해 근로자가 입는 생활상 또는 경제상의 불이익이 어느 정도인지 판단해야 한다. 전직은 고용 주체의 변경 자체로 불이익을 내포하고 있으므로, 특히 종전의 근로조건 유지에 대한 검토가 중요하다.

#### (2) 불이익의 판단 요소

- ① 임금, 퇴직금, 복리후생 등 경제적 근로조건의 불이익 여부. ② 근속기간 승계의 보장 여부 (승계가 이루어지지 않으면 퇴직금, 연차 등에서 불이익 발생). ③ 직무 내용 및 근무 장소의 변경으로 인한 근로자의 생활상 불편 정도. ④ 전직 대상 회사의 재정 상태 및 안정성 등 고용 불안정성 증가 여부

#### (3) 비교 형량

- 전직으로 인한 근로자의 불이익이 업무상 필요성과 비교하여 근로자가 통상적으로 감수해야 할 합리적인 범위를 벗어나서는 안 된다. 만약, 불이익이 과도하다면 정당성이 부정될 수 있다.

### 3. 근로자 본인과 합의 등 절차적 정당성

#### (1) 의의

- 전직명령 과정에서 근로자의 개별적인 동의뿐만 아니라, 신의칙상 요구되는 충분한 합의 절차를 거쳤는지 여부가 정당성 판단에 중요한 요소로 작용한다.

#### (2) 합의 내용

- 전직 대상 회사(신 사용자)의 근로조건, 임금 체계, 복리후생, 고용 보장 등에 대해 근로자에게 충분히 설명하고, 근로자의 의사를 존중하려는 노력을 기울였는지 여부를 본다. 특히, 중대한 불이익이 예상되는 경우에는 더욱 엄격한 합의 노력이 요구된다.

## IV. 부당전직의 효과

### 1. 전직명령의 무효

### (1) 원칙

- 전적명령이 유효요건(개별적 동의)을 갖추지 못했거나, 정당성 기준을 충족하지 못하여 사용자의 재량권을 일탈·남용한 경우, 해당 전적명령은 무효이다.

### (2) 법률관계

- 전적명령이 무효인 경우, 근로자는 원래의 사용자(구 사용자)와의 근로계약 관계가 종료되지 않고 유지되며, 신 사용자에게 근로를 제공할 의무가 없다. 근로자는 구 사용자에게 임금 지급 청구 등 종전의 권리를 행사할 수 있다.

## 2. 근로자의 구제

### (1) 구제 절차의 특수성

- 부당전적은 근로기준법상 해고나 징계에 해당하지 않으므로, **근로기준법 제28조**에 따라 노동위원회에 부당해고등 구제신청을 할 수 있는 직접적인 대상은 아니다.

### (2) 사법적 구제

#### ① 전적 무효 확인 소송

- 근로자는 법원에 전적명령의 무효 확인을 구하는 소송을 제기하여 구 사용자에게 복직을 요구할 수 있다.

#### ② 해고 무효 확인 소송

- 근로자가 부당한 전적명령을 거부하였다는 이유로 구 사용자가 근로자를 해고한 경우, 근로자는 해당 해고의 무효 확인 소송을 제기할 수 있다. 이 경우 법원은 전적명령의 부당성을 판단하여 해고의 정당성 여부를 심리한다. **판례**는 정당성을 잃은 전적명령에 대한 거부를 이유로 한 해고는 부당해고라고 본다.

#### ③ 손해배상 청구

- 부당전적으로 인해 근로자가 손해를 입은 경우, 사용자를 상대로 민법상 채무불이행 또는 불법행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있다.

## V. 전적 후의 근로관계

### 1. 근로계약의 주체 변경

- 전적이 유효하게 이루어진 경우, 근로자는 구 사용자와의 근로관계를 종료하고, 신 사용자에게 고용되어 새로운 근로계약 관계를 맺는다. 근로조건은 원칙적으로 신 사용자와 새롭게 체결한 근로계약의 내용에 따른다.

### 2. 근속기간의 승계

#### (1) 문제점

- 전적은 근로계약의 단절을 전제로 하므로, 근로자의 근속기간이 전적 전후로 통산되는지 여부가 중요하게 다루어진다. 근속기간은 퇴직금, 연차휴가, 승진, 호봉 등의 산정 기초가 되기 때문이다.

#### (2) 판례의 태도 및 판단 기준

- 판례는 전적이 있는 경우 근속기간 통산 여부는 당사자 사이의 합의에 달려있다고 본다.

##### ① 통산 합의가 없는 경우

- 원칙적으로 근속기간은 단절되며, 구 사용자는 근로자에게 퇴직금을 정산하여 지급해야 한다.

##### ② 통산 합의가 있는 경우

- 전적 합의, 단체협약, 취업규칙 등에 근속기간을 통산하기로 하는 명시적인 약정 또는 묵시적인 합의가 있는 경우에만 근속기간이 승계된다.

#### (3) 실무상 유의사항

- 대규모 기업 집단 내의 전적에서는 대부분 근속기간 통산을 명시적으로 약정하며, 통산 합의가 있다면 신 사용자에게 최종 퇴직 시 전 기간에 대한 퇴직금 지급 의무가 발생한다. 다만, 구 사용자가 미리 정산하여 지급한 금액은 신 사용자의 의무에서 공제된다.

## VI. 결론

- 전적은 사용자의 변경이라는 중대한 법률 효과를 수반하므로, 근로자의 개별적이고 명시적인 동의를 얻는 것이 그 유효성의 핵심 요건이다. 설령 동의를 얻었다 하더라도 업무상 필요성과 근로자의 불이익을 비교衡量하여 재량권 남용이 없는 정당성이 인정되어야 한다. 부당전적은 무효이며, 근로자는 사법적 구제 절차를 통해 구 사용자에게 복직을 요구하거나 손해배상을 청구할 수 있다. 전적 후의 근로관계에서는 근속기간의 승계 여부가 당사자 간의 합의에 따라 결정되는 중요한 쟁점임을 유념해야 한다.

**I. 의의**

- 휴직이란 근로계약 관계는 유지되지만, 근로자가 일정 기간 동안 근로의 제공 의무를 면하고 사용자 또한 임금 지급 의무를 면하는 인사처분을 말한다. 휴직은 근로자에게 개인적 사유가 발생하여 장기간 근로를 제공할 수 없거나, 기업의 경영상 필요에 의해 일시적으로 근로를 중단시켜야 할 때 활용된다. 이는 근로자의 신분을 보장하면서 기업의 인력 운용의 탄력성을 확보하는 기능을 한다.

**II. 휴직의 종류**

- 휴직은 그 명령의 근거 및 방식에 따라 직권휴직과 의원휴직으로 구분된다.

**1. 직권휴직**

**(1) 개념**

- 직권휴직이란 근로자에게 휴직 사유가 발생하였을 때, 근로자의 의사나 신청 여부와 관계없이 사용자가 직권으로 명하는 휴직을 말한다. 이는 주로 취업규칙이나 단체협약에 근거하여 이루어지며, 업무 외 부상·질병으로 인한 근로불가, 형사사건으로 인한 구속 등 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 해당한다.

**(2) 법적 성격**

- 직권휴직 명령은 사용자의 인사권에 기초한 일방적인 행위이므로, 정당성 여부가 문제되며, 부당할 경우 부당휴직에 대한 다툼이 발생한다.

**2. 의원휴직**

**(1) 개념**

- 의원휴직이란 근로자가 개인적인 사유(육아, 유학, 개인 사정으로 인한 장기 휴가 등)로 휴직을 신청하고, 사용자가 이를 승인하여 이루어지는 휴직을 말한다.

**(2) 법적 성격**

- 의원휴직은 근로자의 신청과 사용자의 승인이라는 쌍방의 의사 합치에 의해 성립하므로, 그 성격은 휴직에 관한 합의로 볼 수 있다. 따라서 휴직 승인 자체를 취소해 달라고 다투기는 어렵고, 승인 거부나 복직 거부 시에 주로 법적 분쟁이 발생한다. **남녀고용평등법**에 따른 육아휴직은 법적으로 보장된 근로자의 권리이므로, 의원휴직 중에서도 특별한 지위를 갖는다.

**III. 휴직명령의 정당성**

- 휴직명령은 특히 직권휴직의 경우 근로자의 근로 의무를 일방적으로 면제하는 동시에 무노동 무임금 원칙을 적용하여 임금을 상실시키므로, 그 정당성이 엄격하게 요구된다.

**1. 원칙**

- 휴직명령의 정당성은 취업규칙이나 단체협약 등 노사 간에 합의된 규정에 따라 휴직 사유가 발생하는지 여부를 일차적으로 판단한다. 규정에 근거한 휴직이라 하더라도, 휴직명령이 사용자의 인사권 남용에 해당하지 않아야 정당성이 인정된다.

**2. 정당성 판단기준**

- 판례는 휴직명령의 정당성 판단에 대해 해고의 정당성 판단기준을 유추 적용하며 다음과 같은 요소를 종합적으로 고려한다.

**(1) 휴직 사유의 객관적 존재**

- 휴직의 원인이 되는 객관적인 사실이 노사 간 합의된 규정(단체협약, 취업규칙 등)에서 정한 휴직 사유에 해당하는지 여부를 엄격하게 판단한다.

**(2) 휴직 기간의 합리성**

- 휴직을 명한 기간이 해당 사유를 해소하는 데 합리적으로 필요한 최소한의 기간인지 여부를 판단한다.

**(3) 근로자의 불이익 비교**

- 휴직으로 인해 근로자가 입는 생활상의 불이익과 사용자 측의 경영상 필요성을 비교 형량하여, 불이익이 통상적으로 감수해야 할 범위를 초과하는지 여부를 검토한다.

**(4) 복직 가능성 및 노력**

- 휴직 기간이 만료되었을 때 복직의 가능성이 있는지, 근로자의 복직을 위해 사용자가 성실한 노력을 하였는지 여부도 정당성 판단에 영향을 미친다.

**3. 유형별 정당성**

**(1) 업무 외 질병·부상으로 인한 휴직**

**① 판단**

- 근로자의 노무 제공 불능 상태가 상당 기간 지속될 것으로 예상되고, 해당 사유가 취업규칙 등에 휴직 사유로 규정되어 있는 경우에 정당성이 인정된다.

**② 판례**

- 판례는 근로자가 상당한 기간에 걸쳐 노무 제공을 할 수 없는 상태에 있고, 그 회복의 기미도 보이지 않는 상황이라면, 휴직 처리나 근로계약 해지가 정당화될 수 있다고 본다. 다만, 질병의 정도, 예후 등을 종합적으로 고려해야 한다.

**(2) 형사사건으로 인한 구속·기소 휴직**

**① 판단**

- 근로자가 형사사건으로 구속·기소된 경우, 그 구속 상태로 인해 노무 제공이 불가능할 뿐만 아니라 기업의 명예 및 질서 유지에 중대한 영향을 미치는 경우에 정당성이 인정된다.

**② 판례**

- 판례는 기소되었다는 사실만으로 당연히 휴직 사유가 되는 것이 아니라, 업무 관련성이나 구속의 장기화 가능성 등 기업 질서에 미치는 영향을 구체적으로 판단해야 한다고 본다.

**(3) 정리해고 회피 목적의 휴직(일시 휴업)**

- 기업의 경영상 어려움으로 인해 정리해고를 회피하기 위한 수단으로 일시적인 휴업 형태의 휴직을 명하는 경우, 이는 근로기준법상 해고 제한 규정의 회피 수단으로 악용될 수 있으므로, 엄격한 정당성이 요구된다.

**IV. 부당휴직의 효과[근기법 제28조 제1항]**

**1. 부당휴직의 개념**

- 부당휴직이란 사용자의 휴직명령이 정당한 이유 없이 행해져 인사권 남용으로 인정되는 경우를 말한다. 이는 휴직 사유의 부존재나 휴직 기간의 과도한 설정, 절차적 위반 등의 경우에 발생한다.

**2. 부당휴직의 구제**

### (1) 구제 신청의 근거

- 근로기준법 제28조 제1항은 부당해고, 부당정직, 부당감봉, 그 밖의 부당징계를 구제 대상으로 규정하고 있다. 판례는 휴직명령이 근로자의 신분에 중대한 영향을 미치는 징벌적 인사처분이거나, 그 효력이 해고와 유사하게 작용하는 경우, 그 밖의 부당징계에 준하여 부당휴직 역시 노동위원회에 구제 신청을 할 수 있다고 해석한다.

### (2) 노동위원회의 구제 절차

- 근로자는 부당휴직 명령이 있는 날부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 구제 신청을 할 수 있다. 노동위원회가 부당휴직을 인정한 경우, 사용자에게 휴직명령의 취소와 휴직 기간 동안의 임금 상당액을 지급하도록 명하는 구제명령을 내린다.

### (3) 사법적 구제

- 근로자는 휴직명령의 무효 확인 소송을 법원에 제기할 수도 있다.

## V. 휴직과 근로관계

### 1. 휴직 중의 근로관계

#### (1) 근로계약 관계의 유지

- 휴직 기간 동안에도 근로자와 사용자 간의 근로계약 관계는 소멸하지 않고 정지된 상태로 유지된다. 이는 근로자의 신분 보장과 복직의 권리를 확보하는 근거가 된다.

#### (2) 노무 제공 및 임금 지급 의무의 정지

- 휴직의 주된 효과는 근로자의 근로 제공 의무와 사용자의 임금 지급 의무가 정지되는 것이다(무노동 무임금 원칙). 다만, 취업규칙이나 단체협약에 생활 보조적으로 일부 임금이나 휴직 수당을 지급하도록 규정할 수 있다. 육아휴직의 경우 고용보험에서 육아휴직 급여가 지급된다.

### 2. 휴직사유의 소멸과 복직

#### (1) 복직 신청 및 의무

- 휴직 기간 중 휴직 사유가 소멸된 경우, 근로자는 복직을 신청할 수 있으며, 사용자는 휴직 전과 동일하거나 동등한 수준의 직무에 근로자를 복직시켜야 할 의무를 진다.

#### (2) 복직 거부 정당성

- 사용자가 복직을 거부하는 것은 해고에 준하는 행위로 보아 정당성이 요구된다. 판례는 복직 거부가 정당하기 위해서는 휴직자가 복직할 자격이 없거나, 또는 복직할 자리가 없는 경우와 같이 객관적인 사유가 있어야 한다고 본다. 특히 복직할 자리가 없는 경우에도 사용자는 다른 직무에 배치하는 등 복직을 위한 최대한의 노력을 다해야 한다.

### 3. 휴직기간의 만료와 근로관계의 종료

#### (1) 당연 퇴직 규정의 유효성

- 취업규칙 등에 휴직 기간이 만료된 후에도 휴직 사유가 소멸되지 않을 경우 근로관계를 당연 퇴직시키는 규정이 있는 경우가 많다. 판례는 이러한 당연 퇴직 규정이 휴직 기간의 만료와 함께 해고의 효력을 발생시키는 것으로 보고, 그 규정 자체의 유효성 외에 해당 사안에서 당연 퇴직 처리한 것이 객관적·합리적인 이유가 있는지를 해고의 정당성 법리에 따라 판단해야 한다고 본다.

#### (2) 해고의 정당성 판단

- 휴직 기간 만료에 따른 당연 퇴직 처리가 정당하려면, 휴직 사유가 해소될 전망이 없어 근로자가 장기간 노무 제공이 불가능하거나, 회사 측이 복직을 위해 최대한 노력했음에도 적절한 직무를 마련할 수 없는 경우 등 정당한 해고 사유가 인정되어야 한다.

## VI. 결론

- 휴직은 근로관계의 유지와 근로 제공 의무의 일시 정지를 내용으로 하는 인사처분이며, 그 명령의 정당성은 취업규칙에 근거하더라도 해고에 준하는 엄격한 기준에 따라 판단된다. 부당한 휴직명령은 근로기준법 제28조에 따라 부당징계에 준하여 노동위원회에 구제 신청이 가능하며, 휴직 기간 만료 후의 당연 퇴직 처리 역시 해고의 정당성 법리가 적용됨을 유념해야 한다.

**I. 의의**

- 징계란 사용자가 기업 질서 및 근무 기강을 문란하게 한 근로자에 대하여 기업 질서 유지를 목적으로 제재를 가하는 불이익한 인사처분을 말한다. 징계는 정직, 감봉과 같은 근로계약 관계를 유지하면서 근로자에게 불이익을 주는 처분과 징계해고와 같이 근로계약 관계를 종료시키는 처분을 포함하는 광범위한 개념이다. 이는 사용자의 인사권에 속하는 행위이며, 법적 정당성이 요구된다.

**II. 징계권의 법적 성질**

- 징계권의 법적 성질에 대해서는 학설이 대립하며, **판례**는 이를 사용자의 고유한 권한으로 보는 입장을 취한다.

**1. 학설**

- (1) 계약설**
  - 징계권은 근로계약 체결 시 근로자가 취업규칙이나 단체협약에 규정된 징계 사유 및 내용을 수용함으로써 근로계약의 내용으로 편입된 것이라고 본다.
- (2) 징벌권설**
  - 징계권은 사용자가 기업 내의 질서 유지를 위해 법률의 수권에 의하여 특별히 부여받은 공법적 징벌권의 성격을 갖는다고 본다.
- (3) 인사권설**
  - 징계권은 기업의 경영 목적 달성 및 기업 질서 유지를 위한 사용자의 고유한 인사권의 한 내용이라고 본다. 현재 **판례**가 취하는 태도와 유사하다.

**2. 판례**

- **판례**는 징계권 행사를 원칙적으로 사용자의 고유한 권한인 인사권의 행사로 본다. 다만, 징계권의 행사는 무제한적인 것이 아니라 **근로기준법 제23조 제1항**의 정당한 이유와 징계권 남용 금지의 법리에 따라 제한을 받는다고 본다. 즉, 징계 사유가 객관적으로 존재하고, 그 양정이 적정하며, 절차를 준수해야 정당성이 인정된다.

**3. 검토**

- 징계권은 기업 내부의 질서 유지라는 사법적 목적을 가지나, 그 행사가 근로자의 신분에 중대한 영향을 미친다는 점에서 공법적 규율을 받는다. 따라서 인사권설의 입장을 취하면서도, 근로기준법에 의해 엄격하게 정당성이 통제되는 특수한 성격의 권한으로 이해하는 것이 타당하다.

**III. 징계의 종류**

- 징계는 그 제재의 정도에 따라 경징계와 중징계로 나뉘며, 일반적으로 취업규칙이나 단체협약에 그 종류와 내용이 규정된다.

**1. 경고**

- 경고란 근로자의 경미한 비위에 대하여 장래에 동일한 행위를 반복하지 않도록 주의를 촉구하는 조치이다. 이는 보통 징계위원회를 거치지 않거나, 징계로 인한 법적 불이익이 적어 징계성 인사처분으로 보기 어려운 경우가 많다.

**2. 견책**

- 견책이란 근로자의 비위에 대하여 시말서 등을 제출하게 하고 장래를 훈계하는 조치이다. 징계의 가장 낮은 수위에 속하며, 승진, 승급 등에서 일정 기간 불이익을 주는 경우가 많다. 이는 명백한 징계성 인사처분이다.

**3. 감봉[근기법 제95조]**

- 감봉이란 근로자에게 비위가 있을 때 일정 기간 동안 임금을 감액하여 지급하는 징계이다. 이는 근로자의 경제적 생활에 직접적인 영향을 미치는 징계이다. **근로기준법 제95조**는 취업규칙에서 근로자에 대하여 감봉의 제재를 정할 경우에 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.라고 규정한다.

**4. 정직**

- 정직이란 근로자의 신분은 유지하면서 일정 기간 동안 직무 종사를 금지하고, 그 기간 중에는 임금을 지급하지 않는 징계이다. 이는 근로자의 근로 제공 의무와 사용자의 임금 지급 의무가 정지되는 효과를 가져오며, 중징계에 해당한다. 정직 기간은 일반적으로 근로기간에서 제외되거나 승진 등에 불이익을 줄 수 있다.

**5. 징계해고**

- 징계해고란 근로자의 가장 중대한 비위에 대하여 근로관계를 강제로 해지하는 징계이다. 이는 근로자에게 가장 큰 불이익을 주는 징계로서, **근로기준법 제23조 제1항**에 따라 정당한 이유가 있어야 하며, 해고에 관한 엄격한 절차를 준수해야 한다.

**IV. 징계의 정당성**

- 징계 처분이 유효하기 위해서는 사유, 양정, 절차의 세 가지 측면에서 모두 정당성이 인정되어야 한다.

**1. 사유의 정당성**

**(1) 의의**

- 징계 처분의 원인이 된 근로자의 행위가 객관적으로 존재해야 하며, 해당 행위가 취업규칙이나 단체협약에서 정한 징계 사유에 해당해야 한다.

**(2) 판단 기준**

- ① 징계 사유의 객관적 존재**
  - 근로자가 실제로 비위 행위를 저질렀는지에 대한 사실 인정이 정확해야 한다.
- ② 규정의 합리성**
  - 징계 사유를 규정한 취업규칙 등의 내용이 사회통념상 합리성을 갖추어야 한다.
- ③ 기업 질서 침해 정도**
  - 해당 비위 행위가 기업의 경영 목적 달성 및 질서 유지에 실질적인 지장을 초래하는지 여부를 판단한다.

**2. 양정의 정당성**

**(1) 의의**

- 징계의 수위가 근로자의 비위 행위의 정도, 경위, 결과, 평소의 근무 태도 등과 비교하여 균형을 이루어야 한다. 징계권 남용 금지의 핵심적인 내용이다.

**(2) 판단 기준**

- ① 비례의 원칙 준수**
  - 비위의 정도에 비해 징계가 과도해서는 안 된다. **판례**는 사회통념상 고용 관계를 계속할 수 없을 정도의 귀책사유가 있을 때만 징계해고가 정당화된다고 본다.
- ② 평등의 원칙 준수**
  - 유사한 비위를 저지른 다른 근로자와 비교하여 합리적인 이유 없이 차별적으로 중한 징계를 해서는 안 된다.



### ③ 재량권 존중

- 징계 양정은 기본적으로 사용자의 재량 영역이나, 그 재량이 일탈 또는 남용되었다고 판단될 경우 법원 또는 노동위원회가 개입한다.

## 3. 절차의 정당성

### (1) 의의

- 징계 처분 시 취업규칙이나 단체협약에서 정한 징계 절차(징계위원회 개최, 근로자에게 소명의 기회 부여, 징계 의결 통보)를 반드시 준수해야 한다. 절차적 규정은 근로자의 방어권 보장을 위한 강행 규정으로 본다.

### (2) 위반의 효과

- 판례는 취업규칙이나 단체협약상의 징계 절차 규정을 위반한 징계 처분은 내용의 정당성 여부와 관계없이 무효라고 본다.

## V. 징계의 구제

- 부당한 징계 처분을 받은 근로자는 노동위원회 또는 법원을 통해 구제를 받을 수 있다.

### 1. 노동위원회에 대한 구제신청[근기법 제28조]

#### (1) 신청 근거 및 대상

- 근로기준법 제28조 제1항은 사용자의 부당해고, 부당징직, 부당감봉, 그 밖의 부당징계를 받은 근로자가 구제를 신청할 수 있도록 규정하고 있다. 징계 해고뿐만 아니라 정직, 감봉 등 모든 징계 처분이 구제 대상이 된다.

#### (2) 신청 절차

- 근로자는 부당징계가 있는 날부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 구제 신청을 해야 한다.

#### (3) 구제 내용

- 노동위원회는 징계가 부당하다고 판정하면 구제명령을 발하며, 그 내용은 원직 복직 및 징계 기간 중 지급받지 못한 임금 상당액의 지급을 명하는 것이다.

### 2. 이중징계 금지의 원칙

#### (1) 의의

- 하나의 징계 사유에 대하여 두 번 이상 징계를 할 수 없다는 원칙이다. 이는 근로자의 일사부재리(一事不再理) 원칙을 보장하는 것이다.

#### (2) 판단 기준

- 판례는 징계 처분이 이미 행해진 경우, 비록 그 징계가 무효로 되었더라도 동일한 사유에 대하여 다시 징계를 하는 것은 허용되지만, 정당한 징계가 이미 확정된 경우에는 동일 사유로 가중 징계를 할 수 없다고 본다. 다만, 징계 처분 당시 알지 못했던 새로운 비위 사실이 추가로 발견된 경우에는 이중 징계에 해당하지 않는다고 본다.

## VI. 결론

- 징계는 사용자의 인사권 행사에 속하나, 근로자의 신분 및 경제적 생활에 중대한 영향을 미치므로, 사유, 양정, 절차의 세 가지 측면에서 정당성을 갖추어야 한다. 부당한 징계는 근로기준법 제28조에 의거하여 노동위원회를 통해 구제받을 수 있으며, 이는 기업 질서 유지와 근로자 권익 보호의 균형을 이루는 중요한 법적 장치임을 강조한다.

## I. 의의

### 1. 개념

- 직위해제 또는 대기발령이란 근로자가 현재의 직무를 수행하기 곤란하거나 부적합하다고 판단될 때, 사용자(회사)가 근로자에게 일시적으로 직위를 부여하지 않고 대기 상태에 있도록 명하는 인사처분을 말한다. 직위해제는 근로자에게 장래의 징계, 해고, 직권면직의 가능성을 예고하는 잠정적·예비적 조치로서, 기업 질서 유지 및 인사 운용의 효율성을 확보하기 위해 행해진다. 이 기간 동안 근로자는 근로 제공 의무를 면하지만, 임금 지급은 정지되거나 일부만 지급되는 경우가 많아 근로자에게 중대한 불이익을 초래한다.

### 2. 징계와의 구분

#### (1) 목적 및 성격

- 직위해제는 장래의 징계 사유에 대한 조사 또는 근로자의 능력 부족 등으로 인해 직위의 수행을 일시적으로 정지시키는 것을 목적으로 하는 잠정적·예비적 조치이다. 이는 근로자에 대한 제재를 목적으로 하는 것이 아니라, 기업 질서 유지를 위한 인사상 조치의 성격이 강하다. 반면, 징계는 근로자가 이미 행한 비위 행위에 대한 제재를 목적으로 하는 사후적·징벌적 조치이다.

#### (2) 불이익의 정도

- 직위해제는 통상적으로 대기 기간 동안의 임금 지급 정지 또는 감액의 불이익을 주지만, 징계는 확정적인 제재(감봉, 정직)를 가한다. 직위해제가 정당성을 잃고 징계와 동일한 목적으로 사용될 경우 부당징계의 법리가 적용될 수 있다.

## II. 직위해제의 정당성

- 직위해제는 근로자의 직무 수행 권한을 박탈하여 신분상·경제상 불이익을 초래하므로, 사용자의 재량권이 인정되더라도 그 정당성이 엄격하게 심사된다.

### 1. 사용자의 재량권 인정

#### (1) 재량권의 근거

- 직위해제는 사용자의 인사권에 기초한 행위로서, 기업의 경영 목적 달성 및 인사 운용을 위한 합리적 필요성이 인정되는 한, 사용자에게 상당한 재량권이 인정된다. 취업규칙이나 단체협약에 직위해제 규정이 있는 경우, 사용자는 그 규정에 따라 직위해제권을 행사할 수 있다.

#### (2) 재량권 남용의 제한

- 사용자의 직위해제권 역시 무제한적인 것은 아니며, 인사권 남용 금지의 법리에 따라 객관적·합리적인 이유가 있어야 정당성이 인정된다. 재량권을 일탈·남용하여 행해진 직위해제는 무효이다.

### 2. 직위해제의 정당성 기준

- 판례는 직위해제의 정당성 판단 시, 업무상 필요성과 생활상 불이익을 비교 형량하는 전직(轉職) 명령의 정당성 판단 기준과 유사하게 심사한다.

#### (1) 업무상 필요성

- 직위해제를 명할 합리적이고 상당한 업무상 필요성이 있어야 한다. 근로자가 노무를 제공할 능력이 결여되었거나, 비위 사실이 있어 직위 유지가 기업 질서 유지에 현저한 지장을 초래하는 경우 등이 이에 해당한다. 단순히 사용자의 주관적인 판단만으로는 부족하다.

#### (2) 생활상 불이익의 정도

- 직위해제로 인해 근로자가 입는 생활상 불이익(임금 지급 정지 등)이 업무상 필요성과 비교하여 통상적으로 감수해야 할 범위를 넘어서는 안 된다. 특히 직위해제 기간 중 임금을 전혀 지급하지 않는 경우, 그 기간이 합리적이어야 한다.

#### (3) 절차적 정당성

- 취업규칙이나 단체협약에 직위해제에 관한 절차적 규정이 있는 경우, 명령 전에 근로자에게 소명 기회를 부여하는 등 신의칙상 요구되는 절차를 준수해야 한다.

### 3. 정당성이 부정된 사례

- 판례는 징계 사유가 확정되지 않은 상태에서 조사를 위한 대기 발령이 지나치게 장기간 지속되거나, 비위의 정도가 직위 유지가 곤란할 정도에 미치지 못함에도 행해진 직위해제는 재량권을 남용한 것으로 보아 무효라고 판단한다. 객관적인 질병이나 능력 부족 상태가 명확하지 않은 상태에서, 추측만으로 장기간 직위해제를 명한 경우에도 정당성이 부정된다.

## III. 직위해제 후의 당연퇴직(당연면직)

- 직위해제 사유가 해소되지 않고 일정 기간이 경과하거나, 직위해제 사유가 징계(해고 등)나 휴직 사유로 확정될 경우, 취업규칙 등에 따라 당연 퇴직(당연면직) 처리되는 경우가 있다.

### 1. 당연퇴직의 법적 성격

#### (1) 해고와의 구별

- 당연 퇴직은 근로계약이 당연히 종료된다는 점에서, 사용자의 일방적인 의사 표시로 근로계약을 종료시키는 해고(징계해고)와 구별된다. 그러나 판례는 당연 퇴직 규정이 실질적으로 사용자의 퇴직 결정권을 반영하고 있는 경우, 그 당연 퇴직 조치는 근로기준법상 해고에 해당한다고 본다.

#### (2) 규제의 유추 적용

- 직위해제 후의 당연 퇴직은 근로자에게 근로계약 종료라는 중대한 불이익을 주므로, 근로기준법 제23조 제1항에 따른 정당한 이유가 있어야 한다는 해고 제한 규정이 유추 적용된다.

### 2. 당연퇴직의 정당성

#### (1) 휴직과 동일한 판단

- 직위해제 후 당연 퇴직의 정당성은 휴직 기간 만료 후의 당연 퇴직의 정당성 판단과 유사하다. 즉, 당연 퇴직 사유가 객관적으로 존재해야 하며, 특히 근로자의 노무 제공 불능 상태가 장기간 지속되어 더 이상 근로 관계를 유지할 수 없는 경우에 한하여 정당성이 인정된다.

#### (2) 정당성 요건

##### ① 사유의 존속

- 직위해제 사유가 휴직 기간 만료 후에도 해소될 가망 없이 지속되어 근로자가 장기간 노무 제공 불능 상태에 있어야 한다.

##### ② 사용자의 노력

- 사용자가 복직을 위한 노력(다른 직무 배치)을 다했음에도 근로자를 계속 고용하는 것이 불가능하다고 인정되어야 한다.

## IV. 직위해제와 구제이익

### 1. 징계처분으로 인한 직위해제의 효력상실

#### (1) 흡수 소멸

- 직위해제는 잠정적·예비적 조치이므로, 직위해제 기간 중 해당 사유에 기하여 징계(해고 등)가 확정되거나 휴직이 명해지면, 직위해제 처분은 그 목적을 달성하여 자동적으로 효력을 상실하고 징계 또는 휴직에 흡수되어 소멸한다.

**(2) 임금과의 관계**

- 직위해제가 징계 처분에 흡수되어 소멸하는 경우에도, 직위해제 기간 중 임금 미지급의 문제는 별도로 다뤄질 수 있다.

**2. 실효된 직위해제에 대한 구제이익**

**(1) 원칙**

- 구제이익(소의 이익)이란 소송이나 쟁송을 통해 원고의 권리 또는 법률상 이익이 구제될 가능성을 말한다. 직위해제 처분이 징계 처분의 확정으로 인해 이미 효력이 상실되었다면, 원칙적으로 그 실효된 직위해제 처분의 취소를 구하는 구제 신청이나 소송은 소의 이익이 없어 부적법 각하된다.

**(2) 예외적 구제이익 인정**

- 판례는 다음과 같은 경우 예외적으로 소의 이익을 인정한다.

**① 임금 청구권과의 관련성**

- 비록 직위해제 효력이 소멸했다라도, 직위해제가 위법하다는 확인을 받아야 직위해제 기간 동안 미지급된 임금 상당액을 청구할 법률상 이익이 있는 경우에는 구제이익이 인정된다.

**② 불이익의 지속**

- 직위해제 처분의 위법성이 장래의 승진, 보수, 징계 양정 등 근로자의 신분에 불리한 영향을 미치거나, 반복될 위험을 제거하는 데 필요하다고 인정되는 경우에는 구제이익이 인정된다.

**V. 경영상 필요에 의한 대기발령과 휴업수당**

**1. 대기발령의 휴직 해당 여부**

**(1) 경영상 대기발령**

- 근로자의 귀책 사유 없이 단지 경영상 필요(부서 폐지, 직제 개편)에 의해 일시적으로 직무를 부여하지 않고 대기 상태에 두는 발령을 말한다.

**(2) 휴직과의 구별**

- 이러한 경영상 대기발령은 근로자의 노무 제공 능력 결여 등을 이유로 하는 직권휴직과는 구별되나, 근로의 의사가 있음에도 사용자의 귀책 사유로 인해 근로자가 노무를 제공하지 못한 기간으로 해석될 수 있다.

**2. 사용자의 휴업수당 지급의무**

**(1) 지급 의무의 근거**

- 근로기준법 제46조 제1항에 따르면, 사용자의 귀책 사유로 인해 근로자가 휴업하는 경우 사용자는 휴업 기간 동안 평균 임금의 100분의 70 이상을 휴업수당으로 지급해야 한다.

**(2) 판례의 태도**

- 판례는 근로자의 귀책 사유가 아닌 경영상 이유에 의한 대기발령은 실질적으로 사용자의 귀책 사유로 인한 휴업에 해당한다고 본다. 따라서 근로자가 근로의 의사가 있음에도 불구하고 대기발령으로 인해 노무를 제공하지 못했다면, 사용자는 그 기간 동안 근로기준법 제46조에 따른 휴업수당 지급 의무를 부담한다.

**V. 결론**

- 직위해제(대기발령)는 사용자의 잠정적 인사처분으로서, 그 정당성은 업무상 필요성과 재량권 남용 금지의 법리에 따라 엄격히 심사된다. 직위해제 후의 당연 퇴직은 해고 제한 법리가 유추 적용되며, 실효된 직위해제 처분도 임금 청구 등 법률상 이익이 남아있는 경우 예외적으로 구제이익이 인정된다. 또한, 경영상 필요에 의한 대기발령 시에는 사용자의 휴업수당 지급 의무가 발생한다.

**I. 영업양도 의의**

- 영업양도란 일정한 영업 목적에 의해 조직화된 물적·인적 조직 및 영업 활동 그 자체가 동일성을 유지하면서 포괄적으로 이전되는 것을 의미한다. 이는 상법상 개념이나, 근로관계에 중대한 영향을 미치므로 노동법적으로도 중요한 의미를 갖는다. 영업의 동일성을 유지한 채 새로운 경영 주체에게 이전된다는 점이 단순한 자산 매각이나 주식 양도와 구별되는 핵심적인 특징이다. 여기서 영업의 동일성이란 종래의 영업 조직이 그 기능적 재산과 인적 구성을 유지하면서 일체로서 이전되어, 양수인이 양도인의 영업 활동을 그대로 영위할 수 있는 상태를 의미한다.

**II. 영업양도와 근로관계의 승계**

**1. 근로관계의 당연승계 여부**

**(1) 원칙**

- 판례는 영업이 양도되는 경우, 종래의 근로관계는 양도인의 근로자 전원에 대하여 양수인에게 포괄적이고 당연히 승계된다고 본다. 이는 영업의 동일성 유지라는 영업양도의 본질에 따라, 근로관계 역시 영업 조직의 인적 구성으로서 일체로 이전되어야 한다는 데 근거한다. 근로계약 관계의 당사자인 사용자 지위가 법률적으로 양수인에게 이전되는 것이다.

**(2) 근로자 보호**

- 근로관계의 당연 승계는 근로자의 고용 안정을 보호하기 위한 법리로서, 양도인의 근로자들은 양수인의 새로운 근로자가 되며, 종전의 근로 조건이 그대로 유지되는 것을 원칙으로 한다.

**2. 근로자의 승계거부권**

**(1) 의의**

- 영업양도는 사용자의 변경을 초래하여 근로자의 고용 안정에 중대한 영향을 미치므로, 근로자는 원칙적으로 자신의 근로관계가 양수인에게 승계되는 것을 거부할 수 있는 권리를 가진다. 판례는 근로계약 관계는 계약 당사자의 인격을 전제로 하므로, 양도인의 사업장 근로자는 근로관계의 승계를 원하지 않는 경우에는 거부할 수 있다고 본다.

**(2) 승계 거부의 효과**

- 근로자가 승계를 거부하는 경우, 해당 근로자와 양도인 사이의 종전 근로계약 관계는 영업양도를 이유로 해지된다. 이는 근로자의 자발적인 의사에 따른 것이므로, 원칙적으로 근로기준법상 해고로 보지 않고, 근로자는 양도인에게 퇴직금 등 법정 수당을 청구하고 근로관계를 종료한다.

**3. 근로관계 승계배제 특약의 효과**

**(1) 원칙**

- 영업양도 계약 시 양도인과 양수인이 특정 근로자의 근로관계 승계를 배제하기로 하는 특약을 맺는 경우가 있다. 판례는 원칙적으로 근로관계는 당연 승계되므로, 양도인과 양수인 사이의 승계 배제 특약은 해당 근로자의 동의가 없는 한 효력이 없다고 본다.

**(2) 예외와 효과**

**① 특약의 유효성**

- 근로자의 동의가 있거나, 고용 승계 배제가 객관적·합리적인 이유에 기초하는 경우에는 예외적으로 특약이 유효할 수 있다.

**② 특약에 따른 해고**

- 특약이 근로자에게 일방적인 불이익을 주는 경우, 양도인의 해당 근로자에 대한 해고는 영업양도를 해고의 정당한 이유로 삼을 수 없으므로 부당해고에 해당한다. 이는 근로자가 승계를 거부한 경우와 달리, 사용자의 일방적 의사에 의한 근로관계 단절이기 때문이다.

**③ 대응 방안**

- 양도인이 특약에 따라 근로자를 해고할 경우, 양도인과 양수인 중 누가 해고 책임을 지는지가 문제될 수 있다. 판례는 특약의 내용에 따라 책임을 부담할 주체를 판단하나, 부당해고 구제신청의 피신청인은 원칙적으로 해고를 한 당사자인 양도인이 된다.

**4. 관련 판례(승계되는 근로관계의 범위)**

- 판례는 영업양도로 승계되는 근로관계의 범위에 대하여 다음과 같이 정리한다.

**(1) 단체협약의 승계**

- 단체협약은 노동조합과 사용자 간의 관계를 규율하는 것이므로, 영업양도와 동시에 양수인에게 자동적으로 승계되는 것은 아니다. 다만, 양수인이 단체협약의 적용을 받고자 할 경우, 노동조합과 새로운 합의를 통해 단체협약의 효력을 승계할 수 있다.

**(2) 취업규칙의 승계**

- 취업규칙은 근로계약 내용의 일부로 보며, 근로관계가 포괄적으로 승계되는 한도 내에서 종전의 취업규칙 내용 역시 근로 조건으로 승계된다고 본다. 이는 근로자의 기득권 및 고용 안정을 보호하기 위함이다.

**(3) 근속기간 및 퇴직금**

- 근로관계가 승계되면, 종전의 근속기간은 양수인에게 포괄적으로 승계된다. 따라서 퇴직금 산정의 기초가 되는 계속 근로 기간은 양도인 영업 조직의 근무 기간을 합산하여야 한다. 다만, 영업양도 계약 시 양도인이 근로자에게 퇴직금을 정산하여 지급하고 근속 기간을 단절하기로 하는 특약을 맺고 근로자가 이에 명시적으로 동의한 경우에는 예외적으로 단절될 수 있다.

**III. 영업양도 후 근로관계 변동**

**1. 영업양도와 개별적 근로관계**

**(1) 근로조건의 변경 제한**

- 영업양도로 인해 근로관계가 양수인에게 승계된 후, 양수인이 일방적으로 승계된 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 승계된 근로조건을 변경하기 위해서는 근로기준법 및 근로계약이 정하는 절차를 따라야 한다(예 : 취업규칙 불이익 변경 시 근로자의 동의 등).

**(2) 징계 및 해고**

- 양수인에게 승계된 근로자에 대하여 징계나 해고를 하는 경우, 이는 근로기준법상 해고 제한 법리에 따라 정당한 이유가 있어야 한다. 이때 징계 사유에 해당하는 비위 행위가 양도인 재직 시에 발생한 경우라도, 양수인은 승계된 근로관계에 따라 이를 이유로 징계를 명할 수 있다.

**2. 영업양도와 집단적 근로관계**

**(1) 노동조합의 승계**

- 영업양도는 사용자의 변경을 초래하지만, 노동조합은 조직의 동일성을 유지한 채 존속한다. 양수인은 승계된 근로자들의 노동조합에 대하여 사용자 지위를 승계하며, 부당노동행위 등 노동법상의 의무 역시 부담한다.

**(2) 단체교섭 의무의 승계**

- 양수인은 노동조합의 단체교섭 상대방이 되며, 성실교섭 의무를 부담한다. 다만, 단체협약은 자동 승계되지 않으므로 양수인은 새로운 단체협약 체결을 위해 노동조합과 교섭할 의무를 진다.

#### **IV. 결론**

- 영업양도는 영업의 동일성 유지를 전제로 하며, 근로자의 고용 안정을 보호하기 위해 근로관계는 양수인에게 포괄적으로 당연 승계된다. 다만, 근로자는 승계를 거부할 수 있는 권리를 가지며, 양도인과 양수인 간의 승계 배제 특약은 근로자의 동의가 없는 한 효력이 없다. 양수인은 승계 후에도 종전의 근로조건을 유지해야 하며, 노동조합에 대한 사용자 지위와 단체교섭 의무를 부담한다.

**I. 합병과 근로관계의 승계**

- 합병이란 둘 이상의 회사가 청산 절차 없이 하나의 회사로 통합되는 것을 의미하며, 상법상 합병은 포괄적인 권리·의무의 이전을 수반하는 법적 사실이다. 근로관계의 승계는 합병의 포괄적 승계라는 법적 성격에 따라 자동적으로 이루어지는 것을 원칙으로 한다.

**1. 당사자의 합의와 근로관계의 승계**

**(1) 근로관계의 당연 승계**

- 합병은 상법상 포괄적 승계의 효력을 가지므로, 피합병회사의 모든 권리·의무는 합병 후 존속하거나 신설된 회사(합병회사)에 당연히 이전된다. 따라서 피합병회사의 근로자들이 가지는 근로계약상 지위 또한 합병회사에 포괄적으로 승계되며, 이는 당사자들의 별도 합의 없이 법률의 규정에 따라 자동적으로 이루어진다.

**(2) 승계 배제 특약의 효력**

- 합병 당사자인 회사들이 합병 계약을 통해 특정 근로자의 근로관계 승계를 배제하기로 하는 특약을 맺더라도, 이러한 특약은 근로자의 동의가 없는 한 근로자에게 대항할 수 없다. 이는 근로기준법상 근로자의 고용 안정을 보호하기 위한 법리이며, 판례 역시 합병 당사자 사이의 근로관계 승계 배제 합의가 근로자에게 당연히 효력이 미치는 것은 아니라고 본다.

**(3) 승계 배제 목적의 해고**

- 합병회사가 근로관계 승계 배제 특약을 근거로 근로자를 해고하는 경우, 이는 정당한 이유 없는 해고로 인정되어 부당해고가 된다. 합병 자체는 근로기준법상 해고의 정당한 이유가 될 수 없다.

**2. 근로자의 승계거부권**

**(1) 근로자의 승계거부권 인정 여부**

- 판례는 합병의 경우에도 영업양도와 마찬가지로 근로자는 근로관계의 승계를 원하지 않을 때에는 거부할 수 있는 권리를 가진다고 본다. 이는 근로계약이 계약 당사자의 인격을 전제로 하는 계약이므로, 근로자에게 사용자 변경을 수용할지 여부에 대한 선택의 자유를 부여하기 위함이다.

**(2) 승계 거부의 효과**

- 근로자가 승계를 거부하는 경우, 이는 근로자의 의사에 따라 근로계약 관계를 해지하는 것이 되므로, 합병일을 기준으로 피합병회사와의 근로관계가 종료된다. 이 경우 근로자는 피합병회사를 상대로 퇴직금 등 법정 수당을 청구하고 근로관계를 종료한다.

**II. 근로관계 승계의 구체적 검토**

**1. 합병과 개별적 근로관계**

**(1) 근로조건의 유지**

- 합병회사는 승계된 근로자에 대하여 피합병회사와의 종전 근로계약 내용에 따른 근로조건을 그대로 유지하여야 한다. 합병을 이유로 근로자에게 불리하게 근로조건을 변경하기 위해서는 근로기준법에 따른 취업규칙 불이익 변경 절차 등 정당한 절차를 거치거나 근로자의 동의를 얻어야 한다.

**(2) 근속기간의 통산**

- 합병은 포괄적 승계이므로, 승계된 근로자의 피합병회사 재직 기간은 합병회사에서의 근속기간에 합산되어야 한다. 이는 퇴직금 산정, 연차 유급휴가 부여, 승진, 호봉 산정 등 근속기간을 기준으로 하는 모든 근로조건에 적용된다.

**(3) 징계 사유의 승계**

- 근로자가 피합병회사 재직 당시에 발생시킨 징계 사유는 합병회사에 승계되며, 합병회사는 이를 이유로 해당 근로자에게 징계를 명할 수 있다. 이때 징계의 정당성은 합병회사의 취업규칙 및 징계 양정 기준을 적용하여 판단한다.

**2. 합병과 집단적 근로관계**

**(1) 노동조합의 존속**

- 합병으로 인해 사용자의 지위는 변경되지만, 피합병회사 소속 근로자들의 노동조합은 조직의 동일성을 유지하며 존속한다. 합병회사는 해당 노동조합에 대한 사용자 지위를 승계한다.

**(2) 단체협약의 효력**

**① 원칙**

- 판례는 합병으로 인해 피합병회사가 체결한 단체협약이 합병회사에게 자동적으로 승계되는 것은 아니라고 본다. 이는 단체협약이 사용자와 노동조합이라는 당사자 간의 신뢰를 기초로 체결된 규범적·채무적 효력을 갖기 때문이다.

**② 예외**

- 합병회사가 피합병회사의 단체협약이 정한 근로조건을 새로운 근로계약의 내용으로 수용하거나, 새로운 단체협약을 통해 그 효력을 승계하기로 합의한 경우에는 해당 단체협약의 효력이 합병회사에 미친다.

**③ 단체교섭 의무**

- 합병회사는 승계된 근로자들을 구성원으로 하는 노동조합과 새로운 단체협약 체결을 위해 성실하게 교섭할 의무를 부담한다.

**(3) 부당노동행위 책임의 승계**

- 합병은 포괄 승계이므로, 피합병회사가 행한 부당노동행위에 대한 사용자의 책임 역시 합병회사에 포괄적으로 승계된다. 합병회사는 피합병회사의 부당노동행위에 대한 구제명령을 이행할 의무를 진다.

**III. 결론**

- 합병은 상법상 포괄적 승계의 법리에 따라 피합병회사의 근로관계가 합병회사에 당연히 승계되는 것이 원칙이다. 근로자에게는 승계 거부권이 인정되며, 합병회사는 근속기간 통산 및 종전 근로조건 유지 의무를 부담한다. 집단적 근로관계에 있어서는 노동조합은 존속하나 단체협약은 자동 승계되지 않는 점이 영업양도와 유사한 쟁점이다.

**I. 의의**

- 분할이란 하나의 회사가 그 영업 부문 전부 또는 일부를 떼어내어 새로운 회사를 설립하거나 다른 회사가 이를 인수하는 상법상의 조직 변경 행위를 의미한다. 이는 상법상 회사 분할(신설 분할) 및 분할 합병(흡수 분할)의 형태로 이루어지며, 피분할회사의 권리·의무가 포괄적으로 분할된 회사 또는 존속 회사에 이전된다는 점에서 영업양도 및 합병과 유사한 성격을 갖는다. 분할은 주로 기업의 구조 조정, 핵심 역량 집중, 경영 효율화 등을 목적으로 하며, 필연적으로 근로관계의 이전 문제를 야기한다. 특히 분할은 기업의 영업 부문 중 특정 부분만 이전되므로, 근로관계의 승계 문제가 더욱 복잡하게 다루어진다.

**II. 분할과 근로관계의 승계**

**1. 근로관계의 승계 여부**

**(1) 승계의 원칙**

- 상법상 분할은 포괄적 승계의 법리에 따르며, 이는 분할되는 영업 부문에 속하는 권리·의무 일체가 분할 신설 회사 또는 분할 합병 상대 회사에 이전됨을 의미한다. 판례는 이 포괄적 승계의 효력에 따라, 분할되는 영업 부문에서 근무하던 근로자들의 근로관계 역시 분할의 효력 발생과 동시에 해당 분할 회사에 당연히 승계된다고 본다.

**(2) 승계의 범위**

**① 원칙**

- 근로관계는 분할되는 특정 영업 부문에 소속되어 있던 근로자들에 한하여 승계된다.

**② 소속 근로자의 판단 기준**

- 근로자가 분할되는 영업 부문에 속하는지 여부는 원칙적으로 근로계약이나 취업규칙, 인사 발령 등을 통해 객관적으로 결정된 주된 업무의 내용을 기준으로 판단해야 한다. 단순히 형식상의 소속 부서뿐만 아니라 실질적으로 어떤 업무를 수행하였는지가 중요하다.

**③ 분할계획서의 역할**

- 분할계획서나 분할 합병계약서에 근로관계 승계 대상이 명시되어 있다 하더라도, 이는 경영 내부의 기준일 뿐이며, 근로자들의 반대 의사나 실질적인 업무 내용을 무시하고 일방적으로 근로자를 승계 대상에서 제외할 수는 없다.

**(3) 승계 배제 특약의 효력**

- 분할 계획 또는 계약에 특정 근로자의 근로관계 승계를 배제하는 특약이 포함된 경우에도, 이는 근로자의 고용 안정을 침해하므로, 근로자의 동의가 없는 한 효력이 없다고 본다. 특약을 근거로 근로자를 승계 대상에서 제외하고 피분할회사가 해고하는 경우, 이는 정당한 이유 없는 해고로 간주된다.

**2. 근로자의 승계거부권**

**(1) 근로자의 승계거부권 인정 여부**

**① 원칙적 부정**

- 판례에 의하면 둘 이상의 사업을 영위하던 회사의 분할에 따라 일부 사업부문이 신설회사에 승계되는 경우, 분할하는 회사가 분할계획서에 대한 주주 총회의 승인을 얻기 전에 미리 노동조합과 근로자들에게 회사분할의 배경, 목적 및 시기, 승계되는 근로관계의 범위와 내용, 신설회사의 개요 및 업무 내용 등을 설명하고 이해와 협력을 구하는 절차를 거쳤다면 그 승계되는 사업에 관한 근로관계는 해당 근로자의 동의를 받지 못한 경우라도 신설회사에 승계되는 것이 원칙이라고 한다.

**② 예외적 인정**

- 다만, 회사의 분할이 근로기준법상 해고의 제한을 회피하면서 해당 근로자를 해고하기 위한 방편으로 이용되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 해당 근로자는 근로관계의 승계를 통지받거나 이를 알게된 때부터 사회통념상 상당한 기간 내에 반대의사를 표시함으로써 근로관계의 승계를 거부하고 분할하는 회사에 잔류할 수 있다.

**(2) 검토**

- 영업양도의 경우와는 달리 분할의 경우에는 원칙적으로 근로자의 승계거부권을 인정하고 있지 아니한 것은 민법 제657조 제1항의 적용을 배제하여 근로자의 선택권보다 기업조직의 재편 필요성이라는 사용자의 이익을 우선한 판결이라고 판단된다.

**III. 결론**

- 분할은 상법상 포괄적 승계의 법리에 따라 분할되는 영업 부문에 속하는 근로자들의 근로관계가 분할 회사에 당연히 승계된다. 근로관계의 승계 범위는 실질적인 업무의 내용을 기준으로 객관적으로 판단해야 하며, 근로자는 사용자 변경을 이유로 승계를 거부할 수 있는 권리를 가질 수 없다는 것이 판례의 입장이 다.



<제08장 근로관계의 종료.제01절 근로관계 종료의 유형.01>

**I. 당연종료**

**1. 의의**

- 당연종료란 근로계약 당사자의 별도의 의사 표시(해고, 사직, 합의해지 등) 없이, 법률의 규정 또는 사전에 정해진 근로계약 조건의 달성 등 객관적 사실의 발생만으로 근로관계가 자동적으로 소멸하는 것을 의미한다. 이는 근로기준법상 해고 제한 규정의 적용을 받지 않는 것이 원칙이며, 근로관계 종료의 유형 중 가장 명확하게 법률관계가 정리되는 형태이다. 다만, 당연 종료 규정이 실질적으로 해고와 동일한 효과를 발생시키는 경우에는 해고 제한 법리가 유추 적용될 수 있다.

**2. 근로계약 기간 만료**

**(1) 개념**

- 기간을 정한 근로계약에서 그 정해진 기간이 도래함으로써 근로관계가 종료되는 것을 말한다. 이는 근로계약 체결 시부터 종료 시점이 확정되어 있었으므로, 해지 또는 해고가 아니라 기간 도래라는 객관적 사실에 의한 당연 종료이다.

**(2) 계약 갱신의 기대권**

- 판례는 기간제 근로계약이라 하더라도, 계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 형성된 경우에는 기간 만료를 이유로 한 근로관계 종료를 실질적 해고로 본다.

**① 정당한 기대권의 요건**

- 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 갱신 규정이 있거나, 계약이 반복되어 온 사실 등 객관적 사정에 비추어 근로자에게 계약이 갱신될 것이라는 합리적인 기대가 형성된 경우에 해당한다.

**② 갱신 거절의 정당성**

- 정당한 기대권이 인정되는 경우, 사용자의 갱신 거절은 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유가 있어야만 유효하다. 이 경우 갱신 거절의 사유, 절차, 양정 등의 정당성이 해고의 정당성 법리에 따라 심사된다.

**3. 정년퇴직**

**(1) 개념**

- 정년퇴직이란 근로자가 일정 연령에 도달하면 근로관계를 자동적으로 종료시키기로 사전에 정한 제도를 말한다. 정년퇴직은 사전에 확정된 조건(연령 도달)의 성취에 의한 당연 종료이며, 해고에 해당하지 않는다.

**(2) 정년 연장 또는 재고용 기대권**

- 판례는 정년에 도달했다라도, 단체협약이나 취업규칙에 정년 연장 또는 재고용에 관한 규정이 있고 그 규정이 적용될 기대가 형성된 경우에는, 사용자의 재고용 거절을 해고에 준하여 정당성을 심사해야 한다고 본다.

**(3) 정년의 연령**

- 고령자고용촉진법은 사업주에게 60세 이상으로 정년을 정하도록 노력할 의무를 부과하고 있으며, 정년이 60세 미만일 경우 60세로 간주된다.

**4. 당사자 소멸**

**(1) 근로자의 사망**

- 근로계약은 근로자의 노무 제공을 본질로 하므로, 근로자가 사망하는 경우 근로계약은 자동적으로 종료된다. 이는 근로관계가 인격적 신뢰를 기초로 하는 계약이므로 상속될 수 없기 때문이다.

**(2) 사용자의 소멸(법인 해산 등)**

- 사용자가 개인 사업주인 경우, 그가 사망하거나 영업을 폐지하는 때 근로관계는 종료된다. 법인인 경우, 합병, 분할, 해산 등으로 법인격이 소멸할 때 근로관계가 종료되는 것이 원칙이다. 다만, 합병 또는 분할의 경우에는 포괄적 승계 법리에 따라 근로관계는 존속하는 것이 원칙이다.

**5. 취업규칙상 규정**

**(1) 당연 퇴직 규정의 유효성**

- 취업규칙 등에 휴직 기간 만료, 징계 사유의 확정 등 특정 사유 발생 시 별도의 의사 표시 없이 근로관계를 당연히 종료시키는 당연 퇴직(당연 면직) 규정이 있는 경우가 있다.

**(2) 해고 제한 법리의 유추 적용**

- 판례는 이러한 당연 퇴직 규정이 실질적으로 사용자의 퇴직 결정권을 반영하는 경우, 이는 근로기준법상 해고에 해당한다고 본다. 따라서 이러한 규정에 따른 당연 퇴직 처리가 유효하기 위해서는 취업규칙상 규정이 합리적이어야 할 뿐만 아니라, 해당 사안에서 정당한 이유(해고의 정당성)가 있어야 한다. 즉, 근로기준법 제23조 제1항이 유추 적용된다.

**II. 당사자 의사표시에 의한 종료**

- 당사자 일방 또는 쌍방의 의사 표시에 의해 근로관계가 종료되는 유형이다.

**1. 사직**

**(1) 개념**

- 사직이란 근로자가 일방적인 의사 표시로 장래에 근로관계를 종료시키고자 하는 행위를 말한다. 이는 근로자 자신의 자유로운 의사에 의한 근로계약 해지이며, 사용자의 승낙 여부에 따라 그 효력 발생 시기가 달라진다.

**(2) 사직의 효력 발생 시기**

**① 사용자의 승낙이 있는 경우**

- 사직 의사 표시에 대해 사용자가 승낙한 경우, 근로관계는 승낙 시점 또는 승낙 시에 정한 날에 종료된다. 이는 합의해지와 유사하게 해석될 여지가 있다.

**② 사용자의 승낙이 없는 경우**

- 근로자가 사직을 통고하였으나 사용자가 승낙하지 않는 경우, 민법 제660조에 따라 기간의 약정이 없는 근로계약의 경우 사직 통고일로부터 1임금 지급기가 지난 후의 다음 기에 근로계약 해지의 효력이 발생한다.

**2. 합의해지**

**(1) 개념**

- 합의해지란 근로계약의 당사자 쌍방(근로자와 사용자)이 근로관계를 종료시키기로 합의하는 것을 말한다. 이는 근로계약의 내용 변경 또는 종료에 관한 계약으로서, 근로자의 사직 제의(청약)와 사용자의 수락(승낙) 또는 그 반대의 경우로 이루어진다.

**(2) 법적 성격 및 제한**

- 합의해지는 당사자의 자유로운 의사에 기반하므로, 원칙적으로 근로기준법상 해고 제한 규정의 적용을 받지 않는다. 다만, 근로자가 사용자의 강요나 기망 등에 의해 자의적이지 않은 의사로 합의해지에 응한 경우, 이는 합의해지가 아닌 실질적 해고로 인정되어 부당해고 법리가 적용될 수 있다.

### **(3) 정년 전의 합의 퇴직**

- **판례**는 근로자가 정년 잔여 기간이 있음에도 회사의 권유를 받아 퇴직 위로금을 받고 합의 퇴직한 경우, 그 합의 퇴직은 유효하다고 본다. 이는 근로자에게 퇴직의 자유가 있으므로, 자발적인 의사로 퇴직을 결정한 이상 해고로 볼 수 없다고 판단하기 때문이다.

### **Ⅲ. 결론**

- 근로관계의 종료는 당연종료와 당사자 의사표시에 의한 종료로 크게 구분된다. 당연종료는 기간 만료나 정년 등 객관적 사실에 의해 이루어지나, 갱신기대권이 인정되는 경우 실질적 해고로 간주되어 정당성 심사를 받는다. 사직이나 합의해지는 당사자의 자유로운 의사에 기반하지만, 자의적이지 않은 경우에는 부당해고 법리가 적용될 수 있다.

## I. 해고의 의의

- 해고란 사용자가 일방적인 의사 표시로 장래에 대하여 근로계약 관계를 종료시키는 행위를 말한다. **근로기준법 제23조 제1항**은 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못한다고 규정하여, 해고에 대한 정당성을 요구함으로써 근로자의 고용 안정을 강력하게 보호하고 있다. 해고는 그 성격상 근로자에게 가장 큰 불이익을 주는 인사 처분이므로, 그 실제적 정당성과 절차적 정당성이 모두 엄격하게 심사된다.

## II. 해고의 정당성 판단

### 1. 정당한 이유[근기법 제23조 제1항]

#### (1) 의의

- **근로기준법 제23조 제1항**에서 말하는 정당한 이유란 사회통념상 고용 관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있거나, 부득이한 경영상의 필요가 있는 경우를 의미한다. 정당한 이유의 존재 여부는 구체적인 사안에 따라 징계 사유, 해고의 필요성, 근로자의 불이익 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단되어야 한다.

#### (2) 판단 요소

- **판례**는 해고의 정당성 판단 시, 해고 사유의 존재 여부뿐만 아니라 해고를 통해 달성하려는 공익적 목적과 근로자가 입는 불이익의 비교 형량을 통해 징계 양정의 적정성까지 심사한다. 즉, 정당한 이유가 인정되려면 ① 사유의 정당성, ② 양정의 정당성(비례성), ③ 절차의 정당성이 모두 충족되어야 한다.

### 2. 근로자 측의 해고사유

#### (1) 개념

- 근로자 측의 해고사유란 근로자의 능력 부족, 근무 태만, 비위 행위 등 근로자에게 책임 있는 사유로 인해 근로계약을 지속하기 어려운 경우를 말한다. 이는 주로 징계 해고의 형태로 나타나며, 해고의 정당성 판단 시 징계 양정의 적정성이 특히 강조된다.

#### (2) 해고의 정당성 판단 기준

##### ① 능력 부족·근무 성적 부진

- 근로자의 직무 능력이 현저히 부족하여 개선 가능성이 없고, 성실한 노력을 기울였음에도 노무 제공 불능 상태가 지속되어 회사 경영에 지장을 초래하는 경우에 한하여 정당성이 인정된다. **판례**는 근로자가 노력을 기울였거나, 일정한 기간 동안 교육 및 시정의 기회를 주었는지 여부를 중요하게 판단한다.

##### ② 비위 행위(징계 해고)

- 근로자의 비위 행위가 사회통념상 고용 관계를 계속할 수 없을 정도로 중대해야 한다. 판례는 징계 해고의 경우, 비위 행위의 내용 및 정도, 고의성 여부, 회사의 손해 정도, 근로자의 근무 태도 및 경력 등을 종합적으로 고려하여 해고 처분이 비례 원칙에 위배되지 않아야 정당하다고 본다.

##### ③ 정당한 이유 없는 결근·지각

- 근로자의 무단결근 등이 취업규칙상 해고 사유에 해당하더라도, 결근 기간, 회사에 미친 영향, 사전 경고 유무 등을 고려하여 해고는 최후의 수단으로 사용되어야 정당성이 인정된다.

### 3. 사용자 측의 해고사유 : 경영해고(정리해고)

#### (1) 개념 및 근거

- 사용자 측의 해고사유(경영 해고 또는 정리해고)란 사용자 측의 경영상 필요에 의해 근로자의 귀책 사유 없이 근로관계를 종료시키는 해고를 말한다. 이는 **근로기준법 제24조**에 별도로 규정되어 있으며, 일반 해고보다 더욱 엄격한 요건을 요구한다.

#### (2) 경영해고의 4대 요건[근기법 제24조]

- 경영 해고가 정당성을 갖기 위해서는 다음의 4가지 요건을 모두 충족해야 한다.

##### ① 긴박한 경영상의 필요

- 사업의 양도·인수·합병을 포함하여 사업 부문의 폐지 또는 경영 악화 등 기업의 존립 및 유지에 긴박한 필요가 있어야 한다. **판례**는 반드시 도산 직전일 필요는 없으며, 장래의 위기에 대처하기 위한 객관적인 합리성이 인정되는 경우에도 해당한다고 본다.

##### ② 해고 회피 노력

- 사용자는 해고를 회피하기 위한 최대한의 노력을 다해야 한다. **판례**는 배치 전환, 희망퇴직 실시, 신규 채용 중단, 노동시간 단축 등 경영 위기 극복을 위한 모든 조치를 취했는지 여부를 본다.

##### ③ 합리적이고 공정한 기준

- 해고 대상자를 선정함에 있어 객관적이고 합리적이고 공정한 기준을 설정하고 이에 따라 공정하게 대상자를 선정해야 한다. **판례**는 징계 기록, 근무 성적, 부양 가족 수 등을 고려한 기준이 합리적이어야 함을 강조한다.

##### ④ 근로자 대표와의 성실한 협의

- 사용자는 해고를 피하기 위한 방법, 해고의 기준 및 대상, 해고 시기 등에 관하여 근로자 대표에게 50일 전에 통보하고 성실하게 협의해야 한다. 이는 절차적 정당성의 핵심이다.

### 4. 단체협약·취업규칙상 해고사유

#### (1) 법적 성격

- 단체협약이나 취업규칙에 해고 사유가 규정되어 있는 경우, 이는 근로계약의 내용으로 편입되어 해고의 실제적 정당성을 판단하는 일차적인 기준이 된다.

#### (2) 법령과의 관계

##### ① 불리한 규정의 무효

- 단체협약이나 취업규칙상의 해고 사유가 **근로기준법 제23조 제1항**이 요구하는 정당한 이유보다 근로자에게 불리하게 규정되어 있다면, 해당 규정은 무효이다.

##### ② 보충적 효력

- 법령에서 정한 해고 사유 외에 단체협약이나 취업규칙이 합리적으로 해고 사유를 추가 규정하는 것은 유효하다.

#### (3) 당연 퇴직 규정의 해고 해석

- 단체협약이나 취업규칙에 휴직 기간 만료 시 당연 퇴직 등 당연 종료를 규정한 경우, **판례**는 이 규정이 실질적으로 사용자의 의사에 의한 근로관계 종료를 의미하는 때에는 해고로 해석하고 **근로기준법 제23조 제1항**의 정당성을 요구한다.

## III. 결론

- 해고는 근로자의 고용 안정에 미치는 중대한 영향으로 인해 근로기준법 제23조 제1항에 따라 정당한 이유가 있어야만 유효하다. 근로자 측 사유에 의한 해고는 징계 양정의 적정성을 중심으로, 사용자 측 사유에 의한 경영 해고는 긴박한 경영상의 필요 및 해고 회피 노력 등 4대 요건의 충족 여부를 중심으로 실체적 정당성이 엄격하게 심사된다.

## I. 서설

- 해고는 근로자의 신분을 박탈하는 중대한 인사 처분이므로, 근로기준법은 해고의 실체적 정당성 외에도 절차적 정당성을 엄격하게 요구하여 근로자의 방어권을 보장하고 사용자의 자의적인 해고를 방지한다. 해고의 절차적 정당성이란 해고 처분을 함에 있어 법령 또는 노사 간의 자치규범(단체협약, 취업규칙)에서 정한 특정 절차를 준수해야 함을 의미한다. **판례**는 절차적 정당성의 준수 여부가 해고의 유효 요건이라고 보며, 절차적 위반이 있을 경우 해고는 실체적 정당성 유무와 관계없이 무효가 된다고 판단한다.

## II. 법령상 해고의 제한

### 1. 해고의 예고[근기법 제26조]

#### (1) 해고예고의 의의

- **근로기준법 제26조 본문**은 사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다.고 규정한다. 이는 근로자가 해고에 대비하여 새로운 직장을 구할 수 있도록 시간적 여유를 주거나, 그에 상응하는 경제적 보상을 제공함으로써 근로자의 생활 안정을 도모하기 위함이다.

#### (2) 해고예고의 예외

- **근로기준법 제26조 단서**는 다음과 같은 경우 해고예고 의무를 면제한다. ① 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우 ② 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우 ③ 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령(**근로기준법 시행규칙 제4조 별표1**)으로 정하는 사유에 해당하는 경우.

### 2. 해고의 서면통지[근기법 제27조]

#### (1) 의의

- **근로기준법 제27조 제1항**은 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.고 규정한다. 이는 해고 사유 등의 내용을 명확하게 하여 근로자의 방어권 행사를 용이하게 하고, 해고를 둘러싼 분쟁을 사전에 예방하며, 해고의 존재 및 범위를 명확히 하기 위함이다.

#### (2) 통지의 방식 및 효과

##### ① 서면 통지 의무

- 해고 통지는 원칙적으로 구두나 단순한 문자 메시지가 아닌 서면(문서)으로 이루어져야 한다. 다만, 예외적으로 서면에 의한 해고통지의 역할과 기능을 충분히 수행하고 있는 이메일이나 문자 메시지라면 인정이 될 수 있다.

##### ② 위반의 효과

- **근로기준법 제27조 제2항**은 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.고 명시하고 있다. 따라서 서면 통지 의무를 위반한 해고는 실체적 정당성 유무와 관계없이 무효가 된다.

### 3. 해고시기의 제한[근로기준법 제23조 제2항]

- **근로기준법 제23조 제2항**은 근로자의 생활 보호 및 근로자에게 불리한 시기에 해고하는 것을 방지하기 위해 해고 시기에 대한 제한을 규정한다.

#### (1) 업무상 재해·질병 기간

- 근로자가 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일간은 해고할 수 없다.

#### (2) 산전후 휴가 기간

- 출산 전후 휴가 기간과 그 후 30일간은 해고할 수 없다.

#### (3) 예외

- 위 기간 동안에도 사용자가 일시보상을 하거나, 사업을 계속하는 것이 불가능하다고 인정된 경우에는 해고가 가능하다.

### 4. 관련 판례(해고가 무효인 경우에 해고예고수당의 반환청구 거부)

#### (1) 문제의 소재

- 사용자가 해고예고 없이 해고예고수당을 지급하였으나, 해당 해고가 부당해고로 판정되어 무효가 된 경우, 사용자가 근로자에게 이미 지급한 해고예고수당을 부당이득으로 반환 청구할 수 있는지 문제된다.

#### (2) 판례의 태도

- **판례**는 해고예고수당의 지급 의무는 해고의 효력 유무와 관계없이 해고 예고 의무 위반에 따른 법적 의무 이행으로 발생한 것이라고 본다. 따라서 해고가 무효가 되어 근로자가 복직하고 해고 기간 동안의 임금(백 पेи)을 지급받게 되더라도, 이는 근로계약의 존속에 따른 임금 채권의 이행일 뿐, 해고예고수당과는 성격이 다르다고 본다.

#### (3) 결론

- 사용자는 해고가 무효로 된 경우에도 이미 지급한 해고예고수당을 원칙적으로 반환 청구할 수 없다. 다만, 지급된 해고예고수당이 백 पेи와 중복되는 경우에는 임금에서 상계될 수 있을 뿐이다. 즉, 해고예고수당은 예고를 하지 않은 것에 대한 제재적 성격을 갖는다고 이해한다.

## III. 자치규범에서 정한 해고사유의 절차적 정당성

### 1. 해고의 절차적 정당성

#### (1) 의의

- 단체협약이나 취업규칙 등 노사 간의 자치규범에서 해고에 관한 특정 절차를 규정하고 있는 경우, 사용자는 비록 법령에 명시되지 않은 절차라 하더라도 이를 반드시 준수해야 한다. 이러한 절차는 주로 징계위원회 개최, 근로자의 소명(변명) 기회 부여, 노동조합과의 사전 협의 등의 형태를 취한다.

#### (2) 위반의 효과

- **판례**는 단체협약이나 취업규칙에 정한 해고 절차 규정은 근로자의 방어권 보장이라는 강행적 의미를 가지므로, 이러한 절차 규정을 위반하여 행해진 해고는 실체적 사유가 인정되더라도 무효가 된다고 일관되게 판시한다.

### 2. 징계해고사유와 통상해고사유에 모두 해당하는 경우

#### (1) 문제의 소재

- 근로자의 행위가 징계해고사유(비위 행위)와 통상해고사유(능력 부족 등)에 동시에 해당하는 경우, 사용자가 징계 절차를 회피하기 위해 통상 해고의 형식을 취한 경우, 절차적 정당성 위반 여부가 문제된다. 징계 해고는 통상 징계위원회 회부, 소명 기회 부여 등 엄격한 절차를 요구하는 경우가 많다.

#### (2) 판례의 태도

- **판례**는 근로자의 비위 행위에 대해 징계 해고 절차가 규정되어 있음에도 불구하고, 사용자가 이를 회피할 목적으로 통상 해고의 형식을 취하여 징계 절차를 거치지 않았다면, 이는 절차적 정당성을 위반한 것으로 보아 무효라고 판단한다. 이는 실질적으로 징계의 목적을 가진 해고라면 징계 절차를 준수해야 근

로자의 방어권이 보장될 수 있기 때문이다.

#### **IV. 결론**

- 해고의 절차적 정당성은 실체적 정당성과 더불어 해고의 유효 요건을 구성한다. 사용자는 근로기준법이 정한 해고예고(또는 수당 지급), 서면 통지, 해고시기 제한을 준수해야 하며, 단체협약이나 취업규칙에서 정한 징계위원회 회부 및 소명 기회 부여 등 자치 규범상의 절차도 강행적으로 준수해야 한다. 이러한 절차적 정당성의 결여는 해고를 무효로 만드는 결정적인 사유가 된다.

## I. 의의

- 부당해고의 구제란 사용자의 해고 처분이 **근로기준법 제23조 제1항** 등 법령 또는 자치규범(단체협약, 취업규칙)에서 정한 정당한 이유나 절차적 요건을 갖추지 못하여 무효인 경우, 해당 근로자의 근로자 지위를 회복시키고 경제적 손해를 보전해 주는 법적 절차 및 수단을 의미한다. 부당해고 구제 제도는 행정 구제 절차(노동위원회)와 사법 구제 절차(법원)의 이원적 구제 시스템으로 이루어져 있다. 이는 근로자가 신속하고 간편하게 구제를 받을 수 있도록 행정적 절차를 마련함과 동시에, 최종적으로 사법적 심사를 받을 수 있도록 보장함으로써 근로자의 고용 안정과 생존권을 실질적으로 보호하는 데 목적이 있다.

## II. 노동위원회에 의한 구제[근기법 제28조 제1항]

- 노동위원회에 의한 구제는 **근로기준법 제28조**에 근거한 행정적 구제 절차이다. 이는 신속성, 간편성, 비전문성을 특징으로 하며, 근로자가 법률 지식 없이도 쉽게 이용할 수 있도록 고안된 특수 행정심판 절차의 성격을 갖는다.

### 1. 당사자

#### (1) 신청인 (근로자)

- 노동위원회에 부당해고 구제를 신청할 수 있는 신청인은 부당해고, 부당정직, 부당감봉 및 그 밖의 부당징벌을 받은 근로자이다. 이는 해고뿐만 아니라 근로자에게 불이익을 주는 모든 징계 처분을 포함한다. 근로자는 해고가 있는 날부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 구제 신청을 하여야 한다.

#### (2) 피신청인 (사용자)

- 구제 명령을 이행할 의무가 있는 피신청인은 해고 처분을 한 사용자이다. 법인격 없는 사업의 경우, 사업주 개인이 피신청인이 되며, 법인인 경우 법인 자체가 피신청인이 된다.

### 2. 초심

#### (1) 관할 및 구성

- 초심은 근로자의 사업장 소재지를 관할하는 지방노동위원회에서 담당한다. 노동위원회는 공익위원, 사용자위원, 근로자위원의 3자 합의체로 구성되며, 이 중 공익위원이 주도적으로 심문과 판정을 진행한다.

#### (2) 심문 및 판정

- 지방노동위원회는 구제 신청을 접수하면 심문 회의를 열어 당사자들의 주장을 듣고 증거를 조사한다. 심문 결과 부당해고로 판정하면 사용자에게 구제 명령을 발하고, 부당해고가 아니라고 판정하면 기각 결정을 내린다.

#### (3) 구제명령의 내용

- **근로기준법 제30조 제1항**에 따른 구제명령의 내용은 다음과 같다.

##### ① 원직 복직 명령

- 사용자에게 근로자를 종전의 직위 또는 그에 상응하는 직무에 복직시키도록 명한다.

##### ② 임금 상당액 지급 명령

- 사용자가 해고 기간 동안 근로자에게 지급했어야 할 임금 상당액을 지급하도록 명한다(백페이(back pay)).

### 3. 재심[근기법 제31조 제1항]

#### (1) 재심의 신청

- **근로기준법 제31조 제1항**은 초심의 구제명령 또는 기각결정에 불복하는 당사자는 그 통보를 받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다고 규정한다. 재심 절차는 초심과 마찬가지로 3자 합의체로 구성되어 심문 및 판정을 진행하며, 초심 판정의 당부를 심사하는 행정심판의 성격을 갖는다.

#### (2) 중앙노동위원회의 재심 판정

- 중앙노동위원회는 재심 심문 결과 초심 판정의 위법·부당이 있다고 인정하면 구제명령 또는 기각 결정을 내리며, 초심 판정이 정당하다고 인정하면 재심 신청을 기각한다. 중앙노동위원회의 재심 판정은 행정 처분으로서, 이에 불복하는 당사자는 행정소송을 제기할 수 있다.

### 4. 행정소송[근기법 제31조 제2항·제3항, 제32조]

#### (1) 행정소송의 제기

- **근로기준법 제31조 제2항**은 중앙노동위원회의 재심 판정에 불복하는 당사자는 재심 판정서의 송달을 받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다고 규정한다. 행정소송의 피고는 중앙노동위원회 위원장이 되며, 법원은 서울행정법원을 관할 법원으로 한다.

#### (2) 행정소송의 심리 대상

- 행정소송의 심리 대상은 중앙노동위원회의 재심 판정 자체의 위법성이다. 법원은 해고의 실체적·절차적 정당성 여부를 포함하여 중앙노동위원회 재심 판정에 법리 오해, 사실 오인, 재량권 일탈·남용 등의 위법 사유가 있는지 심리한다.

#### (3) 구제명령 등의 확정력 및 강제

##### ① 확정력

- **근로기준법 제31조 제3항**은 재심 판정이 있은 후 15일 이내에 행정소송을 제기하지 않거나, 법원의 확정 판결이 있는 경우 그 재심 판정 또는 법원의 판결이 확정된다고 규정한다.

##### ② 이행강제금

- **근로기준법 제33조**는 확정된 구제명령을 이행하지 않는 사용자에게 이행강제금을 부과하여 구제명령의 실효성을 확보하고 있다.

## III. 법원에 의한 구제

### 1. 의의

- 법원에 의한 구제는 근로자가 노동위원회 절차를 거치지 않고 직접 법원에 소송을 제기하여 해고의 무효 확인 또는 임금 청구 등을 통해 구제를 받는 방법이다. 이는 민사소송 절차를 따르며, 근로자는 노동위원회의 신속한 구제를 포기하는 대신 최종적인 사법적 판단을 받고자 할 때 선택할 수 있다.

### 2. 임금 상당액의 청구

#### (1) 청구의 근거

- 근로자는 해고가 무효임을 전제로 **민법 제538조 제1항**에 따른 채권자 지체 법리를 원용하여 해고 기간 동안 근로를 제공하지 못한 것에 대한 임금 상당액(해고가 없었더라면 받았을 임금)의 지급을 사용자에게 청구할 수 있다. 이는 근로관계가 존속하고 있음을 전제로 한다.

#### (2) 중간 수입의 공제

- **민법 제538조 제2항** 및 판례에 따라, 근로자가 해고 기간 동안 다른 직장에서 얻은 수입(중간 수입)은 사용자가 지급해야 할 임금에서 공제되어야 한다. 다만, 중간 수입이 평균 임금의 100분의 60을 초과하는 경우에 한하여 그 초과액만 공제된다.



### 3. 불법행위에 기한 손해배상청구

#### (1) 청구의 근거

- 사용자의 해고가 정당한 이유 없이 행해져 무효인 경우, 이는 근로자의 근로계약상 지위를 침해하는 행위이자 **민법 제750조**의 불법행위에 해당한다고 볼 수 있다. 근로자는 부당해고로 인해 입은 정신적 · 재산적 손해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

#### (2) 손해배상의 범위

- 손해배상은 해고 기간 동안의 임금 손실뿐만 아니라, 해고로 인해 입은 정신적 고통에 대한 위자료도 포함될 수 있다. 다만, 위자료 청구는 해고가 명백히 위법하고 사용자의 고의 · 악의가 인정되는 등 특별한 사정이 있는 경우에만 제한적으로 인정된다.

### 4. 해고의 정당성에 관한 입증책임

#### (1) 입증 책임의 원칙

- 민사소송에서 해고의 정당성에 관한 입증 책임은 사용자에게 있다. **판례**는 해고는 근로자에게 중대한 불이익을 주는 행위이므로, 해고 처분의 유효성을 주장하는 사용자가 해고의 실체적 · 절차적 정당성을 모두 입증해야 한다고 일관되게 판시한다.

#### (2) 근로자 측의 역할

- 근로자는 자신이 해고되었고, 그 해고가 부당하다는 주장을 입증하면 된다. 이후 사용자가 해고의 정당성을 입증하지 못하면, 법원은 해당 해고를 무효로 판단한다.

### V. 결론

- 부당해고의 구제는 노동위원회에 의한 신속한 행정 구제와 법원에 의한 최종적인 사법 구제라는 이원적 체계로 근로자의 권익을 보호한다. 근로자는 해고가 있는 날부터 3개월 이내에 지방노동위원회에 구제 신청을 할 수 있으며, 중앙노동위원회의 재심 판정에 불복할 경우 15일 이내에 행정소송을 제기해야 한다. 법원에 의한 구제는 해고 무효 확인 및 임금 상당액 청구를 주요 내용으로 하며, 해고의 정당성 입증책임은 오직 사용자에게 있다는 점이 핵심이다.

## I. 의의[기단법 제2조 제1호]

- 기간제근로자란 **기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기단법')** 제2조 제1호에 따라 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자를 의미한다. 기간제 근로계약은 근로계약의 존속 기간이 사전에 확정되어 있으며, 그 기간이 만료되면 근로관계가 자동적으로 종료되는 것을 원칙으로 한다. 그러나 이러한 기간제 근로계약이 남용될 경우 근로자의 고용 불안정을 초래하고, 차별적인 처우를 받을 가능성이 높으므로, 기단법은 기간제근로자에 대한 사용 기간을 제한하고 불합리한 차별을 금지하여 근로조건을 보호하고 있다.

## II. 기단법상 사용기간의 제한[기단법 제4조]

- **기단법 제4조**는 기간제근로자에 대한 사용 기간을 원칙적으로 2년으로 제한함으로써, 장기간의 기간제 근로계약 사용을 억제하고 고용의 안정성을 도모하고 있다.

### 1. 원칙

- 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 기간제근로자를 사용할 수 있다. 다만, 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약(무기계약)을 체결한 근로자로 본다.

### 2. 예외

- 다음과 같은 예외적인 사유에 해당하는 경우, 사용자는 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용할 수 있으며, 이 경우에도 무기계약 근로자로는 간주되지 않는다. ❶ 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우. ❷ 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 업무를 대체할 필요가 있는 경우. ❸ 근로자가 학업, 직업 훈련 등을 목적으로 기간제 근로계약을 체결한 경우. ❹ 고령자(55세 이상)와 근로계약을 체결하는 경우. ❺ 전문적인 지식·기술의 활용이 필요한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우.

## III. 기간제근로자의 사용

### 1. 사용기간

#### (1) 2년 초과 효과

- **기단법 제4조 제2항**에 따라 사용자가 기간제근로자를 2년을 초과하여 사용하는 경우, 해당 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 간주된다. 이를 기간의 정함이 없는 근로계약으로의 간주라고 한다. 간주된 시점부터 해당 근로자는 무기계약 근로자로서 근로기준법상 정당한 이유 없는 해고 금지 등 고용 안정의 보호를 받게 된다.

#### (2) 2년 산정 시점

- 기간 산정은 해당 사업 또는 사업장에서 기간제근로자로 사용된 총 기간을 기준으로 한다. **판례**는 근로계약이 일시적으로 단절된 경우라도, 그 단절 기간이 매우 짧고 근로계약이 반복된 경우라면 전체 기간을 합산하여 2년 초과 여부를 판단해야 한다고 본다.

### 2. 관련 판례

#### (1) 기간제근로자의 2년 제한에 관한 판례

- **판례**는 사용자가 기단법 시행일(2007. 7. 1) 이전에 체결한 기간제 근로계약 기간은 2년 산정 기간에 포함되지 않는다고 본다. 기단법 시행일 이후에 체결되거나 갱신된 기간부터 2년의 산정이 시작된다.

#### (2) 예외 사유의 엄격한 해석에 관한 판례

- **판례**는 **기단법 제4조 제1항** 단서의 예외 사유에 해당하는지 여부는 근로자의 고용 안정이라는 기단법의 입법 취지를 고려하여 엄격하게 해석되어야 한다고 본다. 특히 예외 사유가 형식적으로만 충족될 뿐 실질적인 필요성이 없는 경우에는 예외를 인정할 수 없다고 판단한다.

### 3. 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환노력[기단법 제5조]

- **기단법 제5조**는 기간제근로자의 고용 안정을 위한 사용자의 노력 의무를 규정하고 있다. 사용자는 기간제근로자를 사용하는 경우 해당 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 전환하도록 노력하여야 하며, 이를 위해 합리적인 계획 및 기준을 마련하고 직업 능력 개발 등에 노력하여야 한다고 규정한다. 이는 강제적인 의무는 아니나, 국가의 정책적 방향을 제시하는 규정이다.

## IV. 기간을 정한 근로계약의 근로기간 만료에 따른 법률관계

### 1. 기간제근로자에 대한 갱신거절

#### (1) 기간 만료의 원칙

- 기간제 근로계약은 원칙적으로 기간의 만료로 자동 종료된다. 이 경우 사용자의 갱신 거절은 해고가 아니므로 **근로기준법 제23조 제1항**의 정당한 이유를 요하지 않는다.

#### (2) 갱신 기대권의 법리

- 다만, 기간제근로자라 하더라도 근로계약이 반복되거나 갱신 요건에 대한 규정이 있는 등 객관적 사정에 비추어 근로계약이 갱신될 것이라는 정당한 기대권이 형성된 경우, 기간 만료를 이유로 한 갱신 거절은 실질적으로 해고와 동일하게 취급된다. 따라서 이러한 경우, 사용자의 갱신 거절은 근로기준법상 해고에 준하여 정당한 이유가 있어야만 유효하다.

### 2. 기단법 시행과 종전 법리와와의 관계

#### (1) 기단법의 적용

- 기단법의 시행(2007. 7. 1) 이후에는 2년 초과 사용 금지 및 무기계약직 간주라는 강행규정이 적용되므로, 2년 제한에 해당되는 근로자는 정당한 기대권의 유무와 관계없이 법률에 의해 무기계약 근로자로 간주된다.

#### (2) 갱신 기대권의 역할

- 갱신 기대권 법리는 주로 다음과 같은 경우에 여전히 중요한 역할을 한다. ❶ **기단법 제4조 제1항**의 예외 사유에 해당하는 근로자(2년 제한을 받지 않는 경우)가 갱신 거절을 당했을 때. ❷ 근로계약의 총 기간이 2년 미만인 상태에서 갱신이 거절된 경우. 즉, 기단법은 무기계약 간주라는 강력한 규제를 도입하였으나, 2년 미만 또는 예외 사유에 해당하는 근로자에 대해서는 갱신 기대권 법리가 고용 안정의 중요한 법적 근거가 된다.

### 3. 기간제근로자에 대한 최근 판례의 법리

- **최근 판례**는 기간제근로자의 정당한 갱신 기대권 성립 여부를 판단할 때, 취업규칙이나 단체협약에 갱신 요건이나 절차가 규정되어 있는지 여부, 그리고 사용자가 그러한 절차를 성실하게 준수했는지 여부를 중요하게 심사한다. **판례**는 갱신 기대권이 인정되는 경우, 사용자의 갱신 거절은 합리적이고 객관적인 사유가 존재하고 사회 통념상 상당성이 인정되는 경우에만 정당성이 인정된다고 보며, 이는 사실상 해고의 정당성 판단과 동일한 수준의 엄격성을 요구한다.

## V. 결론

- 기간제근로자는 기단법에 따라 원칙적으로 2년을 초과하여 사용할 수 없으며, 이를 위반하면 기간의 정함이 없는 근로자로 간주된다. 2년 미만 근로자 또는 예외 사유에 해당하는 근로자에 대해서는 갱신 기대권 법리가 여전히 중요한 역할을 하며, 정당한 기대권이 형성된 경우 갱신 거절은 근로기준법상 해고에 준하는 정당한 이유와 절차를 갖추어야만 유효하다.

<제09장 비정규근로자:제02절 단시간근로자:01>

**I. 의의[기단법 제2조 제2호, 근기법 제2조 제1항 제9호]**

- 단시간근로자란 **기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기단법')** 제2조 제2호 및 **근로기준법 제2조 제1항 제9호**에 따라 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 의미한다. 단시간근로자는 노동 시간이 짧다는 점을 제외하고는 통상근로자와 동일한 근로자로 취급되나, 근로 시간이 짧다는 이유만으로 불합리한 차별을 받기 쉽다. 따라서 **기단법** 및 **근로기준법**은 단시간근로자의 근로조건을 명확히 규정하고 비례의 원칙에 따라 통상근로자와 균형 있게 보호하는 것을 목표로 한다.

**II. 단시간근로자의 근로조건[근기법 시행령(별표 2), 근기법 제18조 제1항]**

- **근로기준법 제18조 제1항**은 단시간근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 한다고 규정한다. **근로기준법 시행령 제9조 제1항의 [별표 2]**는 단시간근로자의 근로조건 결정 기준을 구체적으로 명시한다.

**1. 근로계약의 체결**

**(1) 근로조건 명시**

- 사용자는 단시간근로자와 근로계약을 체결할 때, 통상근로자와 마찬가지로 **근로기준법 제17조**에 따라 임금, 소정근로시간, 휴일, 휴가 등의 근로조건을 명시해야 한다.

**(2) 단시간근로자의 특수성 명시**

- 특히 단시간근로자의 경우, 근로계약서에 근로일 및 근로일별 근로시간을 반드시 구체적으로 명시해야 한다.

**2. 임금의 계산**

**(1) 차별 금지**

- 단시간근로자에게는 같은 사업장의 통상근로자에게 적용되는 시간당 임금액을 기준으로 산정하여 지급해야 하며, 근로시간이 짧다는 이유만으로 시간당 임금액에서 불합리하게 차별해서는 안 된다.

**(2) 비례 원칙 적용**

- 임금은 시간급으로 산정하는 것이 원칙이며, 월급 또는 연봉으로 정할 때에는 통상근로자의 임금총액을 소정근로시간 수로 나눈 금액을 기준으로 단시간근로자의 소정근로시간 수에 비례하여 산정해야 한다.

**3. 초과근로**

- 단시간근로자가 당사자 간에 정한 근로시간을 초과하여 근로하는 경우, 그 초과된 근로에 대해서는 통상근로자와 마찬가지로 가산임금(통상임금의 100분의 50 이상)을 지급해야 한다. 다만, 단시간근로자는 소정근로시간을 초과하여 근로하는 경우에도 연장근로에 해당한다.

**4. 휴가·휴일의 적용**

**(1) 유급휴일**

- 주휴일은 통상근로자와 마찬가지로 보장되며, 단시간근로자의 1주 소정근로시간에 비례하여 유급으로 부여해야 한다.

**(2) 연차 유급휴가**

- 단시간근로자의 연차 유급휴가는 통상근로자의 연차휴가 일수에 단시간근로자의 소정근로시간 비율을 곱하여 산정하며, **근로기준법 시행령 제9조 제1항의 [별표 2]**의 계산 방식에 따라 부여한다.

- (1년의 총소정근로시간수 / 통상근로자의 1년 총소정근로시간수) × 통상근로자의 연차휴가일수

**5. 취업규칙의 작성 및 변경**

- 단시간근로자에게 적용될 취업규칙은 통상근로자의 취업규칙을 준용하되, 단시간근로자의 특성을 고려하여 별도의 규정을 두거나 변경할 수 있다. 이 경우에도 **근로기준법 제94조**에 따라 근로자의 과반수로 조직된 노동조합 또는 근로자 과반수의 의견 청취 또는 동의 절차를 거쳐야 한다.

**III. 단시간근로자의 초과근로 제한[기단법 제6조]**

**1. 원칙**

- **기단법 제6조**는 단시간근로자의 동의가 있는 경우에 한하여 소정근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다고 규정하여 초과근로에 대한 제한을 명시한 다.

**2. 초과근로의 상한**

- 단시간근로자는 당사자 간의 합의가 있더라도 1주간에 12시간을 초과하여 근로하게 할 수 없다고 규정하여, 건강권 및 근로 조건을 보호한다.

**3. 위반의 효과**

- 사용자가 단시간근로자의 동의 없이 초과근로를 시키거나 1주 12시간의 상한을 위반하여 근로하게 한 경우, **기단법 제22조**에 따라 벌칙(1천만원 이하의 벌금)의 대상이 된다.

**IV. 통상근로자로의 전환 등[기단법 제7조]**

- **기단법 제7조**는 단시간근로자의 고용 안정 및 근로 조건 개선을 위해 사용자의 전환 노력 의무를 규정한다.

**1. 전환 노력 의무**

- 사용자는 단시간근로자를 통상근로자로 전환하거나, 근로 시간을 늘릴 수 있도록 노력해야 하며, 이를 위한 합리적인 기준 등을 마련해야 한다.

**2. 차별 금지**

- 사용자는 단시간근로자라는 이유만으로 당해 사업 또는 사업장의 동종·유사 업무에 종사하는 통상근로자에 비하여 불합리하게 차별적 처우를 해서는 안 되며, 이는 **기단법 제8조 제2항**의 차별 시정 제도를 통해 구제받을 수 있다.

**V. 적용 배제[근기법 제18조 제3항]**

- **근로기준법 제18조 제3항**은 4주 동안을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자(초단시간근로자)에 대하여 근로기준법의 일부 규정 적용을 배제한다.

**1. 적용 배제 규정**

- ❶ 퇴직금 제도. ❷ 연차 유급휴가 및 유급 주휴일 규정. ❸ 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률의 일부 규정 (퇴직급여 등).

**2. 입법 취지**

- 이는 근로 시간이 극히 짧은 근로자의 경우, 위와 같은 장기적인 근로를 전제로 한 규정들을 적용하기 어렵다는 특수성을 고려한 것이나, 단시간근로자의 차별 및 열악한 근로조건을 방지하기 위해 최소한의 근로조건은 보장되어야 한다.

## **V. 결론**

- 단시간근로자는 통상근로자에 비하여 근로 시간이 짧다는 점을 제외하고는 근로기준법과 기단법에 의해 비례 보호의 원칙에 따라 근로조건이 보장된다. 특히 임금, 휴가 등은 통상근로자의 소정근로시간 비율에 따라 산정되며, 1주 12시간을 초과하는 초과근로는 엄격히 제한되고, 초단시간근로자(15시간 미만)에 대해서는 일부 규정의 적용이 배제된다.

**I. 의의**

- 근로자파견이란 파견사업주가 근로자를 고용한 후, 그 고용 관계를 유지하면서 사용사업주에게 근로를 제공하게 하고, 사용사업주가 해당 근로자의 지휘·명령권을 행사하는 형태의 고용 관계를 의미한다. 이는 파견사업주, 사용사업주, 파견근로자의 삼자 관계로 이루어지며, **파견근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '파견법')**에 의해 규율된다.

**II. 근로자파견과 도급의 구별**

**1. 의의**

**(1) 근로자파견**

- 근로자파견은 근로자가 파견사업주와 근로계약을 맺고, 사용사업주의 사업장에서 사용사업주의 지휘·명령을 받아 근로를 제공하는 것이 본질이다.

**(2) 도급**

- 도급은 당사자 일방(수급인)이 어떤 일의 완성을 약정하고, 상대방(도급인)이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약이다. **(민법 제664조)** 수급인이 자신의 책임과 자체적인 인사 관리에 따라 근로자를 지휘·명령하여 업무를 수행한다.

**2. 구별**

- 근로자파견과 도급은 법적 규제와 근로자의 고용 안정에 미치는 영향이 극히 달라 그 구별이 매우 중요하다.

**(1) 지휘·명령권의 행사 주체**

- 근로자파견의 경우, 근로자에 대한 실질적인 지휘·명령권은 사용사업주에게 있다. 도급의 경우, 근로자에 대한 지휘·명령권은 수급인(하청업체)에게 있다.

**(2) 계약의 대상**

- 파견계약은 노동력 제공 자체를 목적으로 한다. 도급계약은 일의 완성이라는 결과를 목적으로 한다.

**3. 판단기준**

- **대법원**은 계약의 형식이 도급 또는 위탁으로 되어 있더라도, 그 실질이 근로자파견에 해당하는지 여부를 종속적 관계 유무를 기준으로 판단하며, 여러 요소를 종합적으로 고려한다.

**(1) 업무 지시 및 통제**

- ❶ 도급인이 작업 배치, 업무 지시, 근로 시간 결정 등 근로자에 대한 구체적이고 직접적인 지휘·감독을 하는지 여부. ❷ 작업 도구, 시설 등의 소유 관계 및 관리 책임이 어느 당사자에게 있는지 여부.

**(2) 업무의 독립성 및 전문성**

- ❶ 수급인이 업무 수행을 위한 독자적인 조직을 갖추고 있는지 여부. ❷ 업무 수행을 위해 도급인과 독립된 전문적인 기술이나 경영 노하우를 가지고 있는지 여부.

**III. 근로자파견의 규제**

- 파견법은 근로자파견의 남용을 막고 파견근로자의 근로조건을 보호하기 위해 사업의 허가 및 대상 업무와 기간에 엄격한 규제를 가한다.

**1. 근로자파견사업의 허가[파견법 제7조 제1항, 제10조 제1항]**

**(1) 허가제 원칙**

- 파견법 제7조 제1항은 근로자파견사업을 하려는 자는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 고용노동부령으로 정하는 중요사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.라고 규정한다.

**(2) 유효기간**

- 파견법 제10조 제1항은 근로자파견사업 허가의 유효기간은 3년으로 한다.라고 규정한다.

**2. 근로자파견사업의 대상업무 및 파견기간**

**(1) 파견 대상 업무의 제한**

- 파견법은 원칙적으로 근로자파견 대상 업무를 제한하며, 제외된 업무(금지 업무)에 대해서는 파견을 허용하지 않는다.

**(2) 파견 기간의 제한**

- 근로자파견의 기간은 1년을 초과할 수 없다. 다만, 당사자 간의 합의에 따라 1회에 한하여 추가로 1년의 범위 안에서 연장할 수 있다. 즉, 총 파견 기간은 최대 2년을 초과할 수 없다.

**IV. 직접고용의무[파견법 제6조의2]**

- 파견법 제6조의2는 사용사업주가 파견법을 위반하여 근로자를 사용하는 경우, 해당 근로자를 보호하기 위해 사용사업주에게 직접 고용 의무를 부과한다.

**1. 직접고용의무의 인정[파견법 제6조의2 제1항]**

**(1) 직접고용의무 발생 사유**

- 사용사업주에게 직접고용의무가 발생하는 경우는 다음과 같다. ❶ 파견 대상 업무가 아닌 업무에 근로자를 사용한 경우. ❷ 파견 기간 제한을 위반하여 2년을 초과하여 계속적으로 파견근로자를 사용한 경우. ❸ 허가를 받지 아니한 파견사업주로부터 근로자를 파견받은 경우.

**(2) 의무의 내용**

- 사용사업주는 위반 사유가 발생한 시점에 해당 파견근로자를 직접 고용하여야 한다.

**2. 직접고용의무의 적용제외[파견법 제6조의2 제2항]**

- 직접고용의무는 근로자 보호를 위한 규정이므로, 파견근로자가 다음의 사유에 해당하는 경우 직접고용의무가 적용되지 않는다. ❶ 파견근로자가 명시적으로 반대 의사를 표시하는 경우. ❷ 파견근로자가 합리적인 이유 없이 채용 제의에 응하지 아니한 경우.

**3. 직접고용 시 근로조건[파견법 제6조의2 제3항]**

**(1) 근로조건 원칙**

- 사용사업주가 파견근로자를 직접 고용하는 경우, 해당 근로자의 종전 근로조건보다 낮은 근로조건을 적용해서는 안 된다.

**(2) 근로조건 결정**

- 근로조건은 당사자 간의 합의에 따라 결정하되, 합의가 이루어지지 아니하는 경우에는 파견 전의 근로조건과 같은 수준 이상으로 정해야 한다.

**4. 직접고용의무의 발생과 근로계약**

**(1) 법적 성격**

- 직접고용의무는 강행규정으로서, 의무 발생 시점에 근로자에게는 사용사업주를 대상으로 고용 관계의 설정을 청구할 수 있는 권리가 발생한다.

## (2) 계약의 형성

- 판례는 파견법상 직접고용의무의 발생은 근로자에게 청약 또는 청약의 승낙을 간주하는 효과가 발생하여, 사용사업주와 파견근로자 간에 직접 고용 계약이 성립되는 것으로 해석한다.

## V. 결론

- 파견근로자 제도는 파견법에 의해 허가제, 대상 업무 및 기간 제한이라는 강력한 규제를 받는다. 위법한 파견이 발생하는 경우, 사용사업주에게 직접고용의 무가 부과되며, 이는 근로자의 명시적 거부 등 예외 사유가 없는 한 법률상 직접 고용 관계의 성립을 강제하는 효과를 가진다. 또한, 형식상 도급이라 하더라도 그 실질이 사용사업주의 지휘·명령에 따르는 파견에 해당하면 파견법이 적용되어 근로자를 보호한다.



## I. 의의

- 차별시정 제도란 기간제근로자 및 단시간근로자를 보호하는 **기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기단법')**과 파견근로자를 보호하는 **파견근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '파견법')**에 근거하여, 비정규직 근로자들이 근로 조건 등에서 불합리한 차별적 처우를 받았을 때 이를 구제하고 시정할 수 있도록 마련된 행정 구제 절차를 의미한다. 이 제도는 비정규직 근로자들의 균등한 대우를 보장하고, 노동시장의 양극화를 해소하며, 고용 형태의 합리적 운영을 유도하는 것을 목적으로 한다.

## II. 차별적 처우

### 1. 차별적 처우의 의의

#### (1) 개념

- 차별적 처우란 사용자가 기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자 등 비정규직 근로자에게 근로 조건 등에서 합리적인 이유 없이 해당 사업 또는 사업장의 동종·유사 업무에 종사하는 통상 근로자에 비하여 불리하게 대우하는 것을 의미한다.

#### (2) 합리적인 이유

- 차별적 처우가 인정되려면 그 차별에 합리적인 이유가 있어야 한다. **판례**는 합리적인 이유의 존재 여부를 판단할 때, 차별의 목적 및 의도, 업무의 내용 및 범위, 권한과 책임의 정도, 학력·경력 및 근속년수, 노력의 정도 등 객관적 사정을 종합적으로 고려하여 해당 차별적 처우가 고용 형태의 차이를 넘어서 불합리한 것인지 여부를 심사한다.

### 2. 차별적 처우의 금지

- **기단법 제8조** 및 **파견법 제21조 제1항**은 사용자 또는 사용사업주가 기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자라는 이유만으로 합리적인 이유 없이 불리한 차별적 처우를 하는 것을 금지하고, 이를 위반할 경우 노동위원회의 시정 명령 대상이 되도록 규정한다.

## III. 차별시정의 요건

### 1. 차별시정신청권자

#### (1) 기간제 및 단시간근로자

- **기단법 제9조 제1항**에 따라 기간제근로자 또는 단시간근로자는 사용자가 자신에게 차별적 처우를 한 경우 노동위원회에 그 시정을 신청할 수 있다.

#### (2) 파견근로자

- **파견법 제21조 제3항**이 준용하는 **기단법 제9조 제1항**에 따라 파견근로자는 사용사업주가 자신에게 차별적 처우를 한 경우 노동위원회에 시정을 신청할 수 있다. 다만, 이 경우 파견근로자는 파견사업주와 사용사업주를 모두 피신청인으로 하여 신청하는 것이 일반적이다.

### 2. 비교대상근로자

#### (1) 개념

- 비교대상근로자란 차별적 처우를 주장하는 비정규직 근로자가 근로 조건 등에서 비교의 기준으로 삼는 해당 사업장의 기간의 정함이 없는 근로자 또는 통상근로자를 의미한다.

#### (2) 요건

##### ① 동종 또는 유사 업무

- 비교대상근로자는 차별 시정을 신청한 근로자와 동종 또는 유사한 업무에 종사해야 한다. 이는 업무의 내용 및 성격이 유사한지 여부를 실질적으로 판단한다.

##### ② 기간의 정함이 없는 근로자 또는 통상근로자

- 기간제근로자의 비교대상은 기간의 정함이 없는 근로자이며, 단시간근로자의 비교대상은 통상근로자이다.

### 3. 차별금지영역[기단법 제2조 제3호, 파견법 제2조 제7호]

- 차별적 처우가 금지되는 영역, 즉 근로조건 등의 범위는 **기단법 제2조 제3호** 및 **파견법 제2조 제7호**에 규정되어 있다.

#### (1) 임금

- 정기 상여금, 성과급 등 임금 전반

#### (2) 그 밖의 근로조건

- 복리후생, 근로 시간, 휴일·휴가 등

#### (3) 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

- 교육, 배치, 승진 등

### 4. 시정신청의 이익

- 차별시정의 신청은 차별적 처우가 있는 날(계속되는 차별은 그 종료일)부터 6개월 이내에 하여야 한다(**기단법 제9조 제1항**, **파견법 제21조 제3항**). 이 기간을 도과하면 시정 신청의 이익이 없어져 각하된다.

## IV. 차별시정의 절차

### 1. 차별적 처우의 시정신청[기단법 제9조 제1항, 파견법 제21조 제3항]

#### (1) 관할

- 차별 시정 신청은 근로자가 근무하는 사업장 소재지를 관할하는 지방노동위원회에 서면으로 제기한다.

#### (2) 신청 주체

- 근로자뿐만 아니라 노동조합도 근로자를 대리하여 시정 신청을 할 수 있다.

### 2. 조사·심문 등[기단법 제10조, 파견법 제21조 제3항]

#### (1) 조사

- 신청을 받은 지방노동위원회는 즉시 필요한 조사를 해야 한다. 이 때 신청인(근로자) 및 피신청인(사용자 또는 사용사업주)에게 증거 자료 제출 등을 요구할 수 있다.

#### (2) 심문

- 노동위원회는 당사자에게 심문 기일을 통보하고, 심문 회의를 열어 당사자의 주장을 청취하고 증거를 조사한다. 심문은 공익위원, 근로자위원, 사용자위원의 3자 합의체로 진행된다.

### 3. 조정·중재[기단법 제11조, 파견법 제21조 제3항]

#### (1) 조정 및 중재의 권고

- 노동위원회는 차별적 처우에 대한 신속하고 자율적인 해결을 위하여 당사자의 합의에 따라 조정 또는 중재를 할 수 있다.

## **[2] 중재 제정**

- 당사자가 조정 성립에 동의하지 않고 중재 신청에 동의하는 경우, 노동위원회는 사안에 따라 직권 또는 당사자 신청에 의해 중재 제정을 할 수 있다.

## **V. 노동위원회의 판정**

### **1. 시정명령 등[기단법 제12조, 파견법 제21조 제3항]**

#### **(1) 판정의 종류**

- 지방노동위원회는 심문 결과 차별적 처우가 인정되면 시정명령을, 차별적 처우가 인정되지 않거나 시정 신청 요건을 갖추지 못한 경우 기각결정을 한다.

#### **(2) 판정 기준**

- 차별적 처우 여부는 동종·유사 업무 종사자 간의 근로조건을 비교하여 합리적인 이유 없는 차별이 있었는지 여부를 종합적으로 판단한다.

### **2. 조정·중재 또는 시정명령의 내용[기단법 제13조, 파견법 제21조 제3항]**

- 노동위원회의 시정명령의 내용은 다음과 같다.

#### **(1) 차별적 행위의 중지**

- 현재 지속되고 있는 차별 행위를 즉시 중단하도록 명한다.

#### **(2) 근로조건 개선**

- 차별받은 근로자에게 합당한 근로조건을 적용하도록 명한다.

#### **(3) 금전 보상**

- 차별적 처우로 인해 발생한 손해를 배상하도록 명할 수 있다. 이 때 차별 금액 상당액 및 추가적인 손해배상액을 포함한다.

#### **(4) 손해액 가산**

- 노동위원회는 차별적 처우가 고의적이거나 반복적인 경우, 손해액의 3배 이하의 범위에서 배상금을 추가로 지급하도록 명할 수 있다(징벌적 손해배상 성격).

## **VI. 시정명령 등의 확정[기단법 제14조, 파견법 제21조 제3항]**

### **1. 재심 신청**

- 지방노동위원회의 시정명령 또는 기각결정에 불복하는 당사자는 통보를 받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다.

### **2. 행정소송**

- 중앙노동위원회의 재심 판정에 불복하는 당사자는 재심 판정서의 송달을 받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다.

### **3. 확정 및 효력**

- 시정명령 등은 행정소송의 제기 기간이 만료되거나 법원의 확정 판결이 있는 경우 확정된다. 확정된 시정명령은 법적인 효력을 가지며, 사용자업주 등은 이를 성실하게 이행할 의무를 진다.

## **VI. 시정명령이행상황의 제출요구 등[기단법 제15조, 제21조, 제24조]**

### **1. 이행상황 제출 요구**

- 고용노동부장관은 기단법 제15조에 따라 확정된 시정명령의 성실한 이행을 확보하기 위해 사용자에게 시정명령 이행 상황을 제출하도록 요구할 수 있다.

### **2. 과태료 부과**

- 사용자가 확정된 시정명령을 정당한 이유 없이 이행하지 아니한 경우, 기단법 제24조에 따라 1억원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

### **3. 벌칙과의 관계**

- 기단법 제21조는 차별적 처우의 금지 관련 규정을 위반한 사용자에게 벌칙을 부과할 수 있도록 규정하고 있으며, 이는 시정명령의 불이행에 대한 과태료와 별개로 적용될 수 있다.

## **VI. 결론**

- 차별시정 제도는 기단법과 파견법의 핵심 내용으로서, 비정규직 근로자가 합리적인 이유 없는 차별적 처우를 받았을 때 노동위원회의 신속한 행정 구제 절차를 통해 구제받을 수 있도록 보장한다. 노동위원회는 시정명령, 금전 보상 등을 통해 실질적인 구제를 제공하며, 시정명령의 불이행에 대해서는 과태료를 부과하여 제도의 실효성을 확보하고 있다.

**I. 의의**

- 업무상 재해란 근로자가 업무상의 사유에 의하여 부상, 질병, 장해 또는 사망에 이르는 것을 의미하며, **산업재해보상보험법(이하 '산재법')**의 적용 대상이 된다. 산재보험은 근로자의 업무상 재해를 신속하고 공정하게 보상하고, 근로자 재활 및 복지 증진에 기여하는 사회보험이다. 업무상 재해 인정은 사용자의 과실 유무와 관계없이 이루어지며, 이는 사용자의 무과실 책임주의를 기초로 한다.

**II. 업무상 재해의 성립요건**

- 업무상 재해가 성립하기 위해서는 원칙적으로 업무수행성과 업무기인성(인과관계)이 인정되어야 하며, 근로자에게 고의 또는 자해 행위와 같은 귀책사유가 없어야 한다.

**1. 업무수행성과 업무기인성**

**(1) 업무수행성**

- 업무수행성이란 근로자가 근로계약에 따른 업무를 수행하는 중에 발생했거나, 업무에 따르는 위험 범위 내에서 발생한 재해여야 한다는 요건을 의미한다.

**① 업무수행 중의 재해**

- 근로시간 중 근로계약에 따른 본래 업무를 수행하던 중에 발생한 재해.

**② 사업주의 지배·관리 하에 있는 재해**

- 휴게시간 중 사업주가 제공한 시설물 이용 중 발생한 재해, 사업주 지시나 승인을 받은 행사 중의 재해 등.

**(2) 업무기인성**

- 업무기인성이란 재해를 발생시킨 원인이 업무의 수행과 상당인과관계를 가져야 한다는 요건을 의미한다. **판례**는 업무기인성을 판단할 때, 업무가 재해 발생의 유일한 원인일 필요는 없으며, 업무가 재해 발생에 상당한 기여를 했거나 주된 원인이 되었다고 인정되는 경우에도 인과관계를 인정한다.

**2. 근로자의 귀책사유 부존재**

- 업무상 재해는 원칙적으로 근로자가 고의 또는 자해 행위 등으로 재해를 일으킨 경우에는 인정되지 않는다.

**(1) 고의적 사고의 제외**

- 근로자에게 업무 외의 사유로 재해를 유발하려는 고의가 있었던 경우에는 업무상 재해로 보지 않는다.

**(2) 자해 행위의 제외**

- 근로자의 자해 행위로 인한 재해 역시 원칙적으로 업무상 재해로 인정되지 않는다. 다만, 정신질환으로 인하여 정상적인 인식 능력이나 행위 통제 능력을 상실한 상태에서 자해 행위를 한 경우 등 예외적 사정이 있는 경우에는 업무상 재해로 인정될 수 있다.

**III. 업무상 재해의 인정기준**

**1. 업무상 사고나 질병 또는 출퇴근 재해로 인한 재해[산재법 제37조]**

- **산재법 제37조**는 업무상 재해를 그 유형에 따라 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해로 구분하고 각각의 인정 기준을 규정한다.

**(1) 업무상 사고**

- 근로자가 업무를 수행하는 과정에서 발생한 사고, 시설물 등의 결함으로 발생한 사고, 행사 중 발생한 사고 등을 의미한다.

**(2) 업무상 질병**

- 업무상 유해 인자 노출로 인한 질병, 업무상 과로 및 스트레스로 인한 질병 등 업무와 상당인과관계가 인정되는 질병을 의미한다.

**(3) 출퇴근 재해**

- 사업주 지배·관리 하에서의 출퇴근 중 발생한 사고, 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중에 발생한 사고 등을 의미한다.

**2. 고의·자해행위나 범죄행위로 인한 재해**

**(1) 고의·자해 행위의 제외**

- 근로자의 고의나 자해 행위로 인한 재해는 원칙적으로 업무상 재해로 인정되지 않는다.

**(2) 범죄 행위의 제외**

- 근로자가 고의로 행한 범죄 행위가 원인이 되어 발생한 재해는 업무상 재해로 인정되지 않는다. 이는 근로자가 자신에게 책임 있는 위법 행위로 인해 재해를 유발한 경우를 산재보험으로 보상하지 않는다는 원칙에 따른다.

**IV. 결론**

- 업무상 재해는 근로자의 업무수행성과 업무기인성을 핵심 성립 요건으로 하며, 산재법 제37조에 따라 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해 세 가지 유형으로 인정된다. 근로자의 고의나 자해 행위로 인한 재해는 원칙적으로 인정되지 않으며, 산재보험은 이러한 규정을 통해 근로자의 고용 안정과 사회 안전망을 확보하는 데 기여한다.

<제10장 업무상 재해 등 제02절 업무상 사고.01>

**I. 업무수행 중의 사고[산재법 시행령 제27조]**

- 업무수행 중의 사고는 근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 수반되는 행위를 하던 중 발생한 사고를 의미한다. 이는 업무상 재해 인정의 가장 기본적인 유형이다.

**1. 근로계약에 따른 업무 중에 발생한 사고**

**(1) 개념**

- 근로자가 근로 시간과 장소에서 사업주의 지배·관리 하에 근로계약에 따른 본래의 업무를 수행하던 중에 발생한 사고는 업무수행성이 가장 명확하게 인정되어 업무상 사고로 본다.

**(2) 업무 관련 행위**

- 업무를 준비하거나 마무리하는 행위, 업무에 필수적으로 수반되는 생리적 행위, 업무를 위한 비품의 정리 행위 등 업무와 밀접하게 관련된 행위를 하던 중 발생한 사고도 업무수행 중의 사고로 인정한다.

**2. 출장업무 중의 사고**

**(1) 개념**

- 근로자가 사업주의 지시를 받아 사업장 밖에서 업무를 수행하는 출장 중에 발생한 사고를 의미한다. 출장 중에는 근로자가 사업주의 구체적인 지휘·감독을 받는 것이 곤란하므로, 출장 경로 및 출장 목적과 관련된 행위는 사업주의 지배·관리 하에 있는 것으로 추정한다.

**(2) 인정 범위**

- 출장 업무를 위해 합리적이라고 인정되는 범위 내의 행위, 출장지에서 출장 목적을 달성하기 위한 이동 중에 발생한 사고는 업무상 사고로 본다.

**3. 업무수행장소 비지정 근로자**

**(1) 개념**

- 사업주의 구체적인 지휘·관리가 미치지 않는 장소에서 정보통신 수단 등을 이용하여 근로를 수행하는 재택근무자나 특정 장소가 정해지지 않은 근로자를 의미한다.

**(2) 인정 기준**

- 이러한 근로자가 근로계약에 따른 업무를 수행하는 과정에서 발생한 사고는 업무상 사고로 본다. 사고의 인정 여부는 업무 시간 중에 업무와 관련된 행위를 하였는지 여부를 근로자의 주된 업무 내용과 상황을 종합하여 판단한다.

**II. 시설물 등의 결함 등에 따른 사고[산재법 시행령 제28조]**

- 산재법 시행령 제28조는 근로자가 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설물, 장비, 차량 등을 사용하던 중 결함이나 관리 소홀로 인해 발생한 사고를 업무상 사고로 인정한다.

**1. 적용 범위**

- 사업장 내의 건물, 통로, 화장실 등 근로자가 일상적으로 이용하는 모든 시설물과 업무에 사용되는 기계, 장비, 차량 등이 모두 포함된다.

**2. 업무수행과의 관계**

- 근로자가 근로계약에 따른 업무를 수행하던 중이 아니더라도, 근로자의 지위에서 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설물 등을 이용하던 중에 발생한 사고라면 업무수행성이 인정된다.

**III. 행사 중의 사고[산재법 시행령 제30조]**

**1. 유형**

- 산재법 시행령 제30조는 근로자가 운동경기, 야유회, 등산대회 등 각종 행사에 참여하여 발생한 사고를 업무상 사고로 인정한다.

**(1) 사업주의 지배·관리**

- 해당 행사가 사업주의 지배·관리 하에 있었는지가 핵심이다. 행사가 사업주의 주도적 역할로 이루어지고, 근로자의 참가가 강제적이거나 반강제적으로 이루어진 경우 지배·관리 하에 있는 것으로 본다.

**(2) 업무 관련성**

- 행사의 목적이 친목 도모 등 사적인 것이라도, 사업주가 인사과과에 반영하거나 참가 경비를 전액 부담하는 등 업무와 밀접한 관련이 있는 경우에는 업무수행성이 인정될 수 있다.

**2. 판례**

- 판례는 행사의 업무 관련성을 판단할 때, 행사의 목적, 내용, 참가 인원 및 비율, 사업주의 기여도 등을 종합적으로 고려한다. 근로자들의 자발적인 모임에 사업주가 단순히 금을 지급한 정도에 불과한 경우, 원칙적으로 업무수행성을 부정한다. 그러나 행사가 사업주의 지시나 계획에 따라 이루어졌고, 근로자들이 사실상 참가할 의무가 있었다고 인정되면 업무상 사고로 인정한다.

**IV. 휴게시간 중의 사고[산재법 제37조 제1항 제1호 마목]**

- 산재법 제37조 제1항 제1호 마목은 근로자가 휴게시간 중에 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설의 이용 또는 관리 소홀로 발생한 사고는 업무상 사고로 본다고 규정한다.

**1. 인정 요건**

- ❶ 사고가 휴게시간 중에 발생했을 것. ❷ 사고가 발생한 장소가 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설물 등일 것. ❸ 사고의 원인이 해당 시설물의 이용 또는 관리의 소홀일 것.

**2. 판례의 태도**

- 판례는 휴게 장소가 사업주의 지배·관리 영역 내에 있고, 사고가 그 시설물의 결함이나 관리 부실에 기인한 경우에는 업무상 재해로 인정하여 근로자를 보호한다.

**V. 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 사고**

**1. 유형**

- 산재법 시행령 제33조는 위에 열거된 사고 외에도 사업주가 주관하거나 근로자의 근로 조건에 영향을 미치는 교육, 훈련, 각종 모임 등에 근로자가 참여하여 발생한 사고 등, 그 밖의 업무와 관련하여 발생한 사고로서 업무와 사고 사이에 상당인과관계가 인정되는 재해를 업무상 사고로 본다.

**2. 판례**

- 판례는 업무상 사고의 범위를 판단할 때 업무수행성과 업무기인성이라는 기본 원칙을 적용하며, 근로자의 사적 행위와 업무상 행위가 결합된 경우(사적 행위 병행 사고)에는 사적 행위가 업무상 행위를 수행하는 과정에서 필연적으로 수반되는 등 업무 관련성이 높을 때에만 업무상 재해를 인정한다.

## **V. 결론**

- 업무상 사고는 근로계약에 따른 본래의 업무를 수행하는 중의 사고 외에도, 출장 중, 사업주가 제공한 시설물 이용 중, 사업주 주관 행사 중, 휴게시간 중 등 사업주의 지배·관리 하에 있거나 업무와 상당한 관련성이 인정되는 모든 과정에서 발생한 사고를 포함한다. 업무상 사고의 인정은 산재보험법과 관련 시행령 및 판례를 통해 그 범위가 구체화되며, 근로자 보호의 범위를 확대한다.

## I. 의의

- 업무상 질병이란 근로자가 업무 수행 과정에서 유해 인자에 노출되거나 업무의 과중성 등으로 인하여 발생하거나 악화된 질환을 의미하며, **산업재해보상보험법**(이하 '산재법') 제37조 제1항 제2호에 따라 업무상 재해로 인정된다. 업무상 질병은 그 발생 과정이 점진적이고 복합적인 요인이 작용하는 경우가 많아, 질병 발생과 업무 사이의 상당인과관계를 입증하는 것이 핵심적인 쟁점이 된다.

## II. 업무상 질병의 유형

- 산재법 제37조 제1항 제2호는 업무상 질병을 그 원인과 종류에 따라 여러 유형으로 분류한다.

### 1. 직업성 질병[산재법 제37조 제1항 제2호 가목]

#### (1) 개념

- 업무 수행 과정에서 노출되는 화학적 인자(유해 물질), 물리적 인자(소음, 진동, 고열 등), 생물학적 인자 또는 신체에 부담을 주는 작업 등으로 인하여 발생하는 질병을 의미한다. 이는 주로 직업환경 자체가 원인이 되어 발생하는 질병이며, 업무와 질병 사이에 직접적인 관계가 인정된다.

#### (2) 인정 기준

- 산재법 시행령 [별표 3]에서 정하는 업무상 질병의 인정 기준에 해당하여야 한다.

### 2. 재해성 질병[산재법 제37조 제1항 제2호 나목]

#### (1) 개념

- 업무상 사고나 부상이 원인이 되어 발생하거나 악화된 질병을 의미한다. 즉, 선행 사고(재해)가 질병 발생의 직접적 원인이 되는 경우이다.

#### (2) 인정 기준

- 업무상 사고로 인한 부상이 원인이 되어 합병증이 생겼거나, 치료 과정에서 발생한 후유증이 기존 질병을 악화시켰다고 의학적으로 인정되어야 한다.

### 3. 스트레스로 인한 질병[산재법 제1항 제2호 다목]

#### (1) 개념

- 업무와 관련된 정신적 스트레스를 유발하는 사건, 상황 등으로 인하여 발생한 뇌심혈관 질병 또는 정신 질환을 의미한다.

#### (2) 유형

##### ① 뇌심혈관 질병

- 업무상 코로나 스트레스가 원인이 되어 발병하거나 악화된 질환.

##### ② 정신 질환

- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등 업무와 관련된 스트레스로 인한 우울증, 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등.

### 4. 고의에 의한 사고

- 업무상 재해는 원칙적으로 근로자가 고의 또는 자해 행위 등으로 재해를 일으킨 경우에는 인정되지 않는다. 다만, 정신 질환 등으로 인하여 정상적인 인식 능력이나 행위 통제 능력을 상실한 상태에서 자해 행위를 한 경우에는 예외적으로 업무상 재해로 인정된다.

## III. 업무상 질병의 판단기준

### 1. 인과관계의 입증책임

#### (1) 입증책임자

- 업무상 재해의 인정을 구하는 근로자(신청인)에게 원칙적으로 업무와 질병 사이의 상당인과관계를 입증할 책임이 있다.

#### (2) 입증의 정도 경감

- 판례는 질병 발생의 원인이 의학적으로 불분명하거나 복합적인 경우가 많음을 고려하여, 근로자에게 엄격한 입증 책임보다 그 정도를 완화하여 요구한다.

### 2. 인과관계 입증의 방법 및 정도

#### (1) 인과관계의 추정

- 질병이 산재법 시행령 [별표 3]의 인정 기준을 충족하는 경우, 업무상 질병으로 추정된다.

#### (2) 간접적 입증

- 판례는 인과관계가 의학적으로 명확히 입증되지 않더라도, 취업 당시의 건강 상태, 질병의 발병 및 경과, 업무의 내용 및 부담 등을 종합적으로 고려하여, 업무가 질병의 발생 또는 악화에 상당한 기여를 했다고 추단되면 인과관계를 인정한다.

## IV. 판례

### 1. 과로사

#### (1) 개념

- 업무상 코로나 스트레스가 주원인이 되어 발생하는 뇌심혈관 질병으로 인한 사망을 통칭한다.

#### (2) 판례의 법리

- 판례는 과로 여부를 판단할 때 만성적인 과로뿐만 아니라, 발병 전 24시간 이내의 급격한 업무 환경 변화나 돌발적인 사건으로 인한 단기적 과로도 인정한다. 근로자에게 기초 질환이 있었다라도, 업무상의 과로가 질병을 자연적인 진행 속도보다 빠르게 악화시켜 사망에 이르게 한 경우 인과관계를 인정한다.

### 2. 직업병

#### (1) 개념

- 특정 유해 인자 노출로 인한 질병(진폐증, 난청 등)이다.

#### (2) 판례의 법리

- 판례는 유해 인자의 노출 수준, 노출 기간 등을 의학적, 역학적 기준에 따라 엄격하게 판단하며, 산재법 시행령 [별표 3]에 명시되지 않은 질병이라도 업무 관련성이 높으면 인과관계를 인정한다.

### 3. 우울증

#### (1) 개념

- 업무와 관련된 정신적 스트레스로 인하여 발생한 우울증 등 정신 질환이다.

#### (2) 판례의 법리

- 판례는 직장 내 괴롭힘, 인사상 불이익, 과중한 업무 부담 등이 근로자에게 정상적인 적응 능력을 벗어날 정도의 극심한 정신적 고통을 유발하여 우울증을 발생시키거나 악화시킨 경우, 업무상 질병으로 인정한다.

#### 4. 태아의 건강손상

##### (1) 개념

- 모성 근로자가 업무 수행 중 유해 인자에 노출되어 태아에게 건강 손상이 발생한 경우이다.

##### (2) 판례의 법리

- 산재법 제37조 제1항 제2호 라목은 모성 근로자의 업무 수행 중 유해 인자 노출로 인한 태아의 건강 손상을 업무상 질병으로 인정한다. 이는 출산 후 태아에게 발생한 손상을 근로자 본인의 업무상 재해로 보아 보상하는 규정이다.

#### V. 결론

- 업무상 질병은 직업성 질병, 재해성 질병, 스트레스로 인한 질병 등 다양한 유형으로 인정되며, 그 성립을 위해서는 업무와 질병 사이의 상당인과관계가 입증되어야 한다. 판례는 근로자의 입증 부담을 완화하고 개연성에 기반하여 인과관계를 인정하는 방향으로 근로자를 보호하며, 과로사 및 직장 내 스트레스로 인한 정신 질환에 대해서도 적극적으로 업무상 재해를 인정한다.

**I. 사업주의 지배·관리하에서 출퇴근하는 중에 발생한 사고[산재법 제37조 제1항 제3호 가목, 동법 시행령 제35조]**

- 출퇴근 재해는 산재보험법 개정(2017. 10. 19. 시행) 이전의 사업주 지배·관리 하에서의 출퇴근 사고와, 개정 이후 통상적인 경로와 방법에 따른 출퇴근 사고로 구분된다. 산재법 제37조 제1항 제3호 가목 및 동법 시행령 제35조는 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 사업주 지배·관리 하의 교통수단을 이용하여 출퇴근하던 중 근로자에게 발생한 사고를 업무상 재해로 인정한다.

**1. 사업주 제공 교통수단**

- 사업주가 출퇴근용으로 근로자에게 제공한 교통수단을 이용하던 중 발생한 사고는 사업주의 지배·관리가 인정되어 업무상 재해로 본다. 이는 교통수단의 운영에 대한 책임이 사업주에게 있기 때문이다.

**2. 교통수단 이용 중 사고**

- 교통수단을 이용하는 과정이나, 사업주의 지배·관리 하에 있는 교통수단을 이용하기 위해 승·하차하던 중에 발생한 사고 등도 포함된다.

**II. 그 밖에 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중에 발생한 사고[산재법 제37조 제1항 제3호 나목, 동법 시행령 제35조, 제35조의2, 산재법 제37조 제3항]**

- 산재법 제37조 제1항 제3호 나목은 근로자의 주거와 취업 장소 사이를 통상적인 경로와 방법으로 이동하는 중에 발생한 사고를 업무상 재해로 인정한다. 이는 근로자에게 책임 없는 통상의 위험으로부터 근로자를 보호하기 위한 것이다.

**1. 출퇴근 재해에 해당하는 경우**

**(1) 통상적인 경로와 방법**

**① 통상적인 경로**

- 사회 통념상 해당 출퇴근 시점에 일반적으로 이용할 수 있다고 인정되는 가장 합리적인 경로를 의미한다. 이는 반드시 최단 경로일 필요는 없다.

**② 통상적인 방법**

- 대중교통, 자가용, 자전거, 도보 등 일반적으로 이용하는 교통수단이나 이동 방법을 의미한다.

**(2) 경로의 이탈 또는 중단**

- 산재법 제37조 제3항은 출퇴근 경로를 이탈하거나 중단한 경우 해당 이탈 또는 중단 중의 사고는 원칙적으로 출퇴근 재해로 보지 않는다고 규정한다. 다만, 이탈 또는 중단이 일상생활에 필요한 행위로서 동법 시행령 제35조의2에서 정하는 사유에 해당하고, 그 행위로 인해 발생한 사고가 아닌 원래의 경로로 돌아와 이동하던 중 발생한 사고는 출퇴근 재해로 본다.

**(3) 일상생활에 필요한 행위(예외)**

- 동법 시행령 제35조의2가 정하는 일상생활에 필요한 행위는 다음과 같다.

**① 생필품 구입**

- 일상생활에 필요한 용품을 구입하는 행위.

**② 병원 진료**

- 근로자 또는 동거 가족의 질병 치료나 예방을 위한 병원 진료.

**③ 직무 관련 교육**

- 직무 능력 향상을 위한 교육·훈련 수강.

**④ 자녀 등학교**

- 미성년 자녀 또는 장애인 등 동거 친족의 등학교·보육.

**⑤ 선거권 행사**

- 선거권이나 그 밖에 준하는 권리 행사.

**2. 출퇴근 재해에 해당하지 아니하는 경우**

**(1) 경로의 이탈·중단 시 사고**

- 일상생활에 필요한 행위 등 정당한 사유 없이 출퇴근 경로를 이탈하거나 중단한 때에 발생한 사고는 출퇴근 재해로 인정되지 않는다.

**(2) 사적 행위**

- 출퇴근 경로에 있더라도 사적인 목적이 강한 행위(예 : 유희, 사적인 모임)로 인해 발생한 사고는 업무 관련성이 부정되어 출퇴근 재해에 해당하지 아니한다.

**(3) 이동과 무관한 사고**

- 이동 중이 아닌, 주거 또는 취업 장소 내에서 발생한 사고는 출퇴근 재해의 범주에 해당하지 아니한다.

**3. 출퇴근 재해 적용제외직종[산재법 제37조 제4항, 동법 시행령 제35조의2]**

- 산재법 제37조 제4항은 출퇴근 재해 규정의 적용이 제외되는 직종에 관하여 규정한다.

**(1) 개념**

- 출퇴근 과정의 위험을 근로자에게 전적으로 부담시키는 것이 합리적이지 않은 일부 직종의 경우, 출퇴근 재해 규정의 적용이 제외된다.

**(2) 적용제외직종**

- 산재법 시행령 제35조의2에 따라 출퇴근 경로와 방법이 일정하지 아니한 직종으로 여객자동차 운수사업법에 따른 여객자동차 운송사업, 여객자동차 운수사업법 시행령에 따른 개인택시 운송사업, 퀵서비스업에 종사하는 사람이 본인의 주거지에 차고지를 보유하고 있는 경우는 출퇴근 재해를 적용하지 아니한다.

**III. 결론**

- 출퇴근 재해는 사업주 지배·관리 하에서의 출퇴근 사고뿐만 아니라, 통상적인 경로와 방법으로 이동하는 중에 발생한 사고까지 그 범위가 확대되었다. 통상적인 경로의 이탈 또는 중단은 원칙적으로 재해를 부정하나, 일상생활에 필요한 행위에 해당하는 경우에 한하여 예외적으로 인정된다. 출퇴근 재해는 근로자의 생활 영역의 위험을 업무상의 위험으로 편입함으로써 산재보험의 보장성을 크게 강화하였다.